

문제는 상속인의 상속포기를 사해행위라는 이유로 채권자취소권의 대상이 되는가에 대해서 견해가 대립되나, 상속의 포기는 일신 전속적 권리로서 상속인의 전속적 권리이기 때문에 채권자취소권의 대상이 되지 않는다고 보는 것이 다수견해의 입장이다.

(3) 포기자의 상속재산 관리의무

상속을 포기한 상속인은 그 포기로 인하여 상속인이 된 자가 상속 재산을 관리할 수 있을 때까지 그 재산의 관리를 계속하여야 한다(민법 제1044조제1항). 이때 포기한 자는 자기의 고유재산에 대하는 것과 동일한 주의로 관리하여야 한다(민법 제1044조제2항, 제1022조).

제5장 상속인에 의한 소유권보존등기

제 1 절 | 총 설

1. 의 의

일반적으로 소유권보존등기는 아직 소유권의 등기가 되지 아니한 특정 부동산에 대하여 등기의 대상인 부동산의 표시 및 소유권에 관한 사항을 등기기록이라는 공적 장부에 최초로 등기하여 등기기록을 개설하는 것을 말한다. 이때 등기부를 편성할 때에는 1필의 토지 또는 1개의 건물에 대하여 1개의 등기기록을 둔다(부동산 1등기기록의 원칙, 법 제15조제1항 본문). 다만 1동의 건물을 구분한 건물에 있어서는 1동의 건물에 속하는 전부에 대하여 1개의 등기기록을 사용한다.

소유권보존등기에 대해서는 「부동산등기실무」 해당 부분에서 상세히 설명하고 있어, 이하에서는 상속인에 의한 소유권보존등기절차에 관해서만 설명하기로 한다.

2. 소유권보존등기를 신청할 수 있는 자

미등기의 토지 또는 건물에 관한 소유권보존등기는 ① 토지대장, 임야대장 또는 건축물대장에 최초의 소유자로 등록되어 있는 자 또는 그 상속인, 그 밖의 포괄승계인, ② 확정판결에 의하여 자기의 소유권을 증명하는 자, ③ 수용(收用)으로 인하여 소유권을 취득하였

음을 증명하는 자, ④ 특별자치도지사, 시장, 군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다)의 확인에 의하여 자기의 소유권을 증명하는 자(건물의 경우로 한정한다)가 신청할 수 있다(법 제65조).

구법 제130조 및 제131조에서는 포괄승계 중 상속만을 예시하였으나, 개정법에서는 토지대장 등에 소유자로 등록된 자의 포괄승계인 모두가 소유권보존등기를 신청할 수 있도록 개정하였다. 예를 들어, 지적공부상 소유자로 등록된 회사가 분할된 경우, 분할 후 회사는 분할계획서 등에 의하여 미등기 토지를 승계하였음을 증명하여 바로 자기 명의로 소유권보존등기를 신청할 수 있게 된다.

제 2 절 | 상속인에 의한 소유권보존등기절차

1. 신청인

토지대장, 임야대장 또는 건축물대장에 최초로 소유자로 등록되어 있는 자는 물론 그자의 상속인도 미등기부동산에 대한 소유권보존등기를 신청할 수 있다(법 제65조제1호). 사망으로 인해 권리능력을 상실한 피상속인은 그의 명의로 소유권보존등기를 신청할 수 없을 뿐만 아니라, 피상속인의 사망으로 상속인이 소유권을 취득한 사실이 가족관계등록에 관한 증명서나 제적등본 등에 의해 공적으로 확인될 수 있기 때문이다.

상속인이 여러 명일 경우, 그 전원이 공동상속에 의해 상속재산을 공유로 취득한 자로서 소유권보존등기를 신청할 수 있으며, 이 경우 민법 제265조 단서의 보존행위로서 상속인 중 1인이 전원을 위해

소유권보존등기를 신청할 수도 있다. 또한, 상속인이 여러 명 있다가 상속포기나 상속재산 분할협약에 의하여 상속인 중 한 사람이 미등기부동산을 상속한 경우에는 그 상속인이 소유권보존등기를 신청할 수 있다.

여기에서 말하는 피상속인에는 신청인인 상속인의 직접적인 피상속인뿐만 아니라 피상속인의 피상속인도 포함한다. 즉 대장상 최초 소유자로 등록된 소유자로부터 여러 차례에 걸쳐 상속이 이루어진 경우에는, 최후의 상속인이 등기신청 당시 소유권자에 해당하므로 직접 자기 명의로 소유권보존등기를 신청할 수 있다. 예를 들어 대장상 최초 소유자 갑이 사망하여 그 상속인 을이 당해 부동산을 상속에 의해 취득했지만, 소유권보존등기를 하지 않은 상태에서 을도 사망한 경우, 을의 상속인 병이 직접 자기 명의로 소유권보존등기를 신청할 수 있다.

미등기부동산의 대장상 소유자가 포괄유증을 한 경우 포괄유증을 받은 자가 직접 자기 명의로 소유권보존등기를 신청할 수 있을지가 문제 된다. 이에 대해 부동산등기법 개정 전의 등기실무에서는 포괄수증자가 직접 자기 명의로 소유권보존등기를 신청할 수는 없고, 상속인 명의로 소유권보존등기를 한 다음 소유권이전등기를 하도록 하였다. 하지만 개정법에서 상속 이외의 모든 포괄승계에 대해서도 직접 소유권보존등기를 할 수 있도록 개정하였으므로 포괄유증을 받은 자도 직접 자기 명의로 소유권보존등기를 신청할 수 있다.

2. 등기신청절차

가. 단독신청

미등기부동산에 대한 소유권보존등기에 있어서는 등기의무자가 있을 수 없으므로 등기명의인이 될 자인 상속인이 단독으로 신청하여야 한다(법 제23조제2항).

나. 신청정보

(1) 일반적으로 등기를 신청하는 경우에는 부동산등기규칙 제43조에 규정된 일반적 사항으로 부동산표시에 관한 사항, 신청인의 성명 또는 명칭과 주소 및 주민등록번호, 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 성명과 주소, 대리인에 의하여 등기를 신청하는 경우에는 그 성명과 주소, 등기원인과 그 연월일, 등기의 목적, 등기필정보, 등기소의 표시, 등기신청연월일 등을 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 한다.

(2) 소유권보존등기를 신청하는 경우에는 일반적인 기재사항 이외에 법 제65조 각 호의 어느 하나에 따라 등기를 신청한다는 뜻을 신청정보의 내용으로 제공하여야 한다. 이 경우 규칙 제43조제1항제5호에도 불구하고 등기원인과 그 연월일은 신청정보의 내용으로 제공할 필요가 없다(규칙 제121조제1항).

따라서 상속인이 소유권보존등기를 신청하는 경우에는, 등기신청서에 등기의 목적은 “소유권보존”, 신청근거규정은 “부동산등기법 제65조제1호”를 기재하여야 한다.

다. 첨부정보

소유권보존등기를 신청하는 경우에는, ① 소유자임을 증명하는 정보, ② 부동산을 표시를 증명하는 정보 외에 통상의 권리취득 등기신

청과 마찬가지로 일반적인 첨부정보를 그 신청정보와 함께 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다. 즉 대리인에 의하여 등기를 신청하는 경우에는 대리권한을 증명하는 정보(규칙 제46조제1항제5호), 등기명의인의 주소를 증명하는 정보 및 부동산등기용등록번호를 증명하는 정보(규칙 제46조제1항제6호) 등을 첨부정보로서 제공하여야 한다. 여기에서는 상속인에 의한 소유권보존등기신청 시의 특수한 첨부정보를 설명하기로 한다.

(1) 소유자임을 증명하는 정보

토지대장, 임야대장 또는 건축물대장에 자기 또는 피상속인이 소유자로 등록되어 있는 자가 보존등기를 신청하는 경우에는 그 토지대장 정보, 임야대장 정보, 건축물대장 정보를 첨부정보로서 제공하여야 한다.

토지대장, 임야대장 또는 건축물대장에 최초의 소유자로 등록된 자가 사망하여 상속이 개시된 경우에는, 그 상속인이 등기명의인으로서 소유권보존등기를 신청하고, 이때에는 상속인임을 증명하는 정보를 제공하여야 한다. 즉 상속인임을 증명하는 정보로 피상속인과 상속인의 가족관계등록에 관한 증명서 및 제적등본 등을 제공하여야 하고, 경우에 따라서는 상속재산협의분할서, 상속재산포기심판서 등을 제공하여야 한다. 이 경우 대장상의 소유자인 피상속인의 표시가 가족관계등록에 관한 증명서상 피상속인의 표시와 다른 경우에는 양 공부상의 명의인이 동일인임을 증명하는 별도의 서면을 첨부정보로서 제공하여야 한다(선례 2-216). 예를 들어, 종중의 족보는 상속인임을 증명하는 별도의 서면이 될 수 없다(선례 6-209).

(2) 부동산의 표시를 증명하는 정보

상속인이 보존등기를 신청하는 경우에는 토지의 표시를 증명하는 토지대장 정보나 임야대장 정보 또는 건물의 표시를 증명하는 건축물대장 정보나 그 밖의 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다.

(3) 도면

건물(구분건물)의 소유권보존등기를 신청하는 경우에는 그 대지 위에 여러 개의 건물이 있을 때에는 그 대지 위에 있는 건물의 소재도(구분건물의 경우에는 1동 건물의 소재도, 각 층의 평면도 등)를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다. 다만 건물의 표시를 증명하는 정보로서 건축물대장 정보를 등기소에 제공한 경우에는 이를 제공할 필요가 없다(규칙 제121조제3항, 제4항).

(4) 제공할 필요가 없는 첨부정보

구법상 소유권보존등기를 신청할 때에는 등기원인을 증명하는 서면, 등기의무자에 대한 등기필증(등기필정보) 등을 첨부할 필요가 없다는 규정(구법 제132조제2항 단서)을 두고 있었으나, 개정법에서는 이러한 규정을 삭제하였다. 왜냐하면, 소유권보존등기신청에서는 대장 정보가 등기원인을 증명하는 정보이고, 등기기록의 개설단계로서 등기필정보가 존재하지 않기 때문이며, 소유권보존등기에 이해관계 있는 제3자란 있을 수 없기 때문이다.

3. 등기의 실행

상속인에 의한 소유권보존등기의 신청이 있는 경우에도 등기기록을 새로 편성하여야 한다. 이에 대한 설명은 「부동산등기실무」 해당

부분을 참고한다.

4. 관련 문제

가. 대장상 피상속인의 표시 중 주소 등이 불분명한 경우에 상속인 명의로의 소유권보존등기 가부

토지대장에 피상속인 명의로 등록된 미등기 토지에 관하여 상속인이 직접 소유권보존등기를 신청하기 위하여는 그 대장등본 외에 상속을 증명하는 서면을 첨부하여야 할 것인바, 대장상의 소유자표시 중 주소기재의 일부(번지)가 누락되어 있을 뿐 아니라 피상속인(대장상 명의인)의 제적부가 소실되어 그 상속인을 확인할 수 없는 경우라면, 대장상의 소유자와 소실된 제적부상의 피상속인이 동일인임을 증명하는 보증서를 첨부하더라도 그것만으로는 상속인 명의의 소유권보존등기를 신청할 수 없다(선례 2-206).

나. 대장상 피상속인의 표시와 가족관계등록부상 피상속인의 명의를 다른 경우 보존등기절차

토지대장상 피상속인 명의로 등록된 미등기 토지에 관하여 상속인이 직접 소유권보존등기를 신청하기 위하여는 그 대장등본 외에 상속을 증명하는 서면(가족관계등록에 관한 증명서 및 제적등본 등)을 첨부하여야 하는데, 이 경우 대장상 소유자인 피상속인의 표시가 가족관계등록에 관한 증명서 등의 피상속인 명의로 다른 경우에는 위 양 공부상의 명의인이 동일인임을 증명함에 충분한 서면도 첨부하여야 한다(선례 2-216).

다. 망 갑, 을, 병 공유의 미등기토지에 대하여 병에게만 상속인이 있는 경우 보존등기절차

토지대장상 이미 사망한 갑·을·병 3인의 공유로 등록된 미등기의 토지에 관하여 갑과 을의 경우는 그들의 사망 후 그 상속인들 조차 전원이 상속인 없이 사망하였고 병의 상속인만이 생존하고 있다면, 갑과 을 상속인들의 공유지분은 병의 상속인들에게 지분비율대로 귀속되는 것이므로, 병의 상속인들은 대장등본 외에 자신들의 상속을 증명하는 서면 및 갑·을의 상속인 전원이 상속인 없이 사망하였음을 증명하는 서면 등을 첨부하여 그들 명의로 직접 소유권보존등기를 신청할 수 있다(선례 3-351).

라. 대장상 공동상속인 중 1인 명의로 소유권이전등록이 경료된 미등기부동산의 보존등기절차

대장상 최초 소유명의인의 공동상속인 중 1인 명의로 상속을 원인으로 하는 소유권이전등록이 되어 있는 미등기 건물에 대하여 소유권보존등기를 경료받으려면, 당해 건축물대장등본과 대장상 최초 소유명의인을 피상속인으로 하는 상속관계를 증명하는 서면을 첨부하여 공동상속인들을 공유자로 하고 상속지분을 공유지분으로 하는 소유권보존등기를 신청하거나, 상속관계를 증명하는 서면 외에 상속재산협의분할계약서와 공동상속인들의 인감증명을 함께 첨부하여 공동상속인 중 1인 또는 수인의 명의로 소유권보존등기를 신청하여야 하며, 당해 건축물대장등본만을 첨부하여 대장상 소유권이전등록을 경료받은 상속인 1인 명의로 소유권보존등기를 경료받을 수는 없다. 다만 대장상에 나타난 당해 상속인 명의로 상속등기가 경료된 후 등기부가 멸실되었으나 등기부상의 소유자로서 멸실회복등기 기

간 내에 회복등기를 신청하지 못한 경우에는 그와 같은 사실을 증명하는 서면을 첨부하여 대장상에 나타난 상속인 명의로 소유권보존등기를 경료받을 수 있다(선례 5-267).

마. 대장상 피상속인의 주민등록번호가 누락된 경우 상속인 명의의 소유권보존등기신청

토지대장상 소유자의 주소 기재가 누락된 미등기토지에 관하여 지적법 제24조(현행 측량·수로조사 및 지적에 관한 법률 제84조)의 규정에 따라 대장 소관청이 조사 결정하여 주소는 등록하였으나 등록명의인이 주민등록법 시행 이전에 사망하여 주민등록번호를 등록하지 못한 경우도, 위 등록명의인의 상속인은 위 토지대장, 상속인임을 증명하는 서면 및 주소를 증명하는 서면을 첨부하여 상속인 명의로 소유권보존등기를 신청할 수 있으나, 구체적인 사안에서 소유권보존등기 신청인이 대장상의 소유자로 등록된 자의 상속인과 동일인인지 여부는 당해 등기관이 판단할 사항이다(선례 8-155).

제6장 상속을 원인으로 하는 소유권이전등기

제 1 절 | 총 설

상속으로 인한 부동산물권 변동은 등기를 필요로 하지 아니하므로, 상속등기를 하지 않더라도 피상속인의 사망으로 법률상 당연히 상속인에게 이전된다. 그러나 이를 다시 처분하려면 상속으로 인한 물권의 취득을 등기하고 그 후에 처분에 따르는 등기를 하여야 한다(민법 제187조).

피상속인의 사망으로 상속이 개시된 경우 누가 상속인이 될 것인가 여부, 상속분 및 상속재산의 분할 등 상속의 일반론에 대해서는 앞에서 서술하였다. 따라서 이 장에서는 상속으로 인한 소유권이전등기의 신청절차에 관한 부분을 상세히 설명하기로 한다.

상속등기의 신청절차 중 피상속인이 외국인인 경우에는 별도의 장(외국인 등의 상속등기)에서 다루기로 하고, 이하에서는 상속으로 인한 소유권이전등기의 신청과 관련된 신청인, 신청정보 및 첨부정보에 대해 상세히 설명하기로 한다. 또한, 상속등기가 마쳐진 후의 상속등기의 경정등기에 대해서도 그 허용여부 및 등기절차를 살펴보기로 한다.

제 2 절 | 신청인

1. 상속인의 단독신청

상속으로 인한 권리의 이전등기는 상속을 증명하는 정보를 첨부하여 상속인(등기권리자)이 단독으로 그 신청을 할 수 있다(법 제23조제3항). 상속이라는 사실의 발생은 제적등·초본, 기본증명서 등 공적 장부에 의하여 쉽게 등기관이 확인할 수 있고 절차상 등기의무자에 해당하는 자가 현존하지 않기 때문이다.

이에 반해 피상속인이 원인행위를 종료한 후 등기신청을 하지 않고 사망한 경우 그 상속인이 하는 등기신청(법 제27조)은 공동신청에 의하는데, 이에 관해서는 후술한다.

2. 공동상속인 중 1인의 단독신청

상속인이 부동산을 공동상속 받는 경우, 상속에 의한 소유권이전등기는 그 공동상속인의 신청에 의하게 된다. 그러나 공동상속 받은 자 중 1인이 민법 제265조 단서에서 규정하는 이른바 공유물의 보존행위로서 상속인 모두를 위해 상속등기를 신청할 수도 있으며, 이 경우 등기신청서에는 공동상속인 전원을 표시하여야 한다(선례 5-276).

그러나 상속재산의 분할 또는 다른 상속인의 상속포기로 상속인 중 일부가 상속재산인 부동산을 취득한 경우에는 그 상속등기는 당연히 그 소유권을 취득한 상속인만이 상속관계의 증명서류를 첨부하여 신청하면 되고 상속을 포기한 다른 상속인은 신청인이 될 수 없다(선례 2-246).

3. 일부 상속등기의 불허

공동상속인 중 일부가 상속등기에 협력하지 않거나 행방불명된

경우라 하더라도 나머지 상속인의 상속지분 만에 대한 일부 상속 등기는 할 수는 없고(예규 제535호, 선례 6-200), 상속인 중 일부가 나머지 상속인들의 상속등기까지 법정상속분에 따라 신청하여야 하며 등기신청서에도 공동상속인 전원을 표시하여야 한다(선례 5-276).

4. 피상속인의 등기기록상 표시와 기본증명서상 표시가 다를 경우

피상속인의 등기기록상 표시와 기본증명서의 표시가 서로 달라 등기명의인 표시변경 또는 경정사유가 있다 하더라도(성명 상위, 창씨명 기재, 주소 상위, 주소 중 번지누락 등의 경우를 포함) 서로 동일인임을 인정할 수 있는 시·구·읍·면장의 서면 또는 이를 인정함에 충분한 서면을 첨부한 때에는 위 변경 또는 경정등기를 거치지 않고 곧바로 상속등기신청을 할 수 있다(선례 2-259, 3-396, 3-410, 4-353, 4-362, 6-207).

제 3 절 | 신청정보

신청정보에 관한 일반적인 기재사항은 「부동산등기실무」에서 설명하고 있으므로 여기에서는 상속등기에 있어서 특유한 기재사항에 대해서 설명하기로 한다. 다만 상속재산관리인은 재산상속인의 존부가 분명하지 아니한 때 일정한 자의 청구에 의하여 법원이 선임하는 자로서 일정한 권리의무가 있는 상속재산의 관리인에 불과할 뿐

이므로 재산관리인의 선임은 부동산등기법상 등기할 사항이 아니다 (선례 4-355).

1. 등기원인

상속으로 인한 등기의 원인은 “상속”이다. 그러나 구민법 시행 당시 개시된 상속에 있어서는 “호주상속” 또는 “유산상속”(호주 아닌 가족의 재산을 상속하는 경우)이라고 기재하여야 하고, 신민법 시행 후 개정민법(1991. 1. 1.) 시행 이전에 상속이 개시된 때에는 “재산상속”이라고 기재하여야 한다.

또한, 호주상속인이 없어 절가(絶家)된 가의 재산이 가족 또는 근친자나 리·동에 귀속되는 때에는 “권리귀속”이라고 기재하며, 협의분할에 의한 상속등기인 때에는 “협의분할에 의한 상속”이라고 기재한다.

2. 등기원인일자

등기원인일자는 피상속인의 사망일자를 기재한다. 상속재산을 협의분할하더라도 그것은 상속에 의한 소유권이전이므로 피상속인이 사망한 날을 등기원인일자로 하여야 한다(예규 제438호). 그러나 호주상속인이 없어 절가된 가의 재산이 가족 또는 근친자나 리·동에 귀속되는 때에는 피상속인의 사망일자가 아닌 절가된 일시를 기재한다.

하나의 상속등기사건에 2개의 등기원인이 있는 경우에 등기원인과 그 연월일 난에는 먼저 개시된 원인과 연월일을 기재하고, 후에

개시된 상속원인은 신청인 표시란에 “공동상속인 중 ○○○는 ○년 ○월 ○일 사망하였으므로 상속”이라고 기재하고 그 상속인을 표시한다(예규 제57호). 이 부분에 대해서는 상속등기의 관련 문제 부분에서 자세히 설명하기로 한다.

※ 등기기록례 (상속으로 인한 소유권이전등기)

【갑 구】 (소유권에 관한 사항)				
순위 번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
3	소유권이전	1986년 3월 5일 제3500호	1963년 2월 3일 재산상속	공유자 지분 18분의 6 이도령 500124-1056407 서울 중구 회현동 7 지분 18분의 6 이일남 530425-1056408 서울 중구 저동 8 공동상속인 중 이도남은 1965 년 5월 3일 사망하였으므로 재 산상속 지분 18분의 3 이이남 540320-1617312 서울 중구 다동 5 지분 18분의 2 이삼남 551010-1065420 서울 중구 다동 5 지분 18분의 1 이일선 600722-1066221 서울 중구 장충동 1가 5

실종선고로 인하여 상속이 개시되는 경우에 그 실종선고의 효과는 실종기간이 만료한 때에 소급하게 되므로(민법 제28조), 실종선

고일을 부기하여 “1959년 1월 5일 재산상속(1964년 1월 5일 실종선고)”로 기재한다(예규 제57호). 다만 그 실종기간이 구법시행기간 중에 만료되는 때에도 그 실종선고가 신법시행 후에 선고된 때에는 현행 민법상의 상속제도에서 설명한 바와 같이 상속순위, 상속분 등은 신법을 적용한다. 실종선고로 인한 소유권이전등기절차에 대해서는 뒤에서 설명하기로 한다.

대습상속에 있어 등기실무상 주의를 요하는 것은 등기원인과 그 연월일을 피대습자의 사망일자를 기준으로 할 것인가 아니면 피상속인의 사망일자를 기준으로 할 것인가 혼동을 일으키는 수가 있다. 그러나 대습상속은 앞에서 설명한 바와 같이 대습상속인이 피대습자의 권리를 승계하는 것이 아니고 자기 고유의 권리로서 직접 피상속인의 재산적 지위를 승계하는 것이므로 피상속인의 사망일자를 기준으로 하여야 할 것이다.

피상속인의 자(子)에 대습원인이 있으면 손(孫)이 대습자가 되고, 손에 관하여서도 대습원인이 발생하면 증손(曾孫)이 대습자가 되는데 이를 재대습상속이라고 하며, 이때에도 상속등기 원인일자는 피상속인의 사망일자를 기준으로 한다.

3. 상속지분의 표시

수인의 공동상속인을 위한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 그 상속지분을 반드시 기재하여야 하며 이는 상속분이 같을 때에도 마찬가지이다. 상속인의 지분표시는 상속지분에 대한 합을 분모로 하고 각자의 상속분을 분자로 하여 ○분의 ○으로 기재한다.

상속등기의 지분 표시는 법정상속분에 의하는 것이 원칙이므로,

법정상속분과 다른 비율로 상속등기를 신청하는 경우에는 그 지분이 법정상속분과 다르게 변동된 사실을 증명하는 정보(분할협의서, 분할심판서 정본 등)를 제공하여야 하고 이를 제공하지 아니하는 경우 등기관은 그 등기신청을 각하한다(대법원 1990. 10. 29. 자 90마772 결정).

제 4 절 | 첨부정보

1. 상속을 증명하는 정보

가. 통상의 상속인 경우

상속을 원인으로 하는 소유권이전등기신청을 할 때에는 상속을 증명하는 정보가 등기원인을 증명하는 정보가 될 것이다. 구법에서는 등기원인이 상속인 때에 신청서에 상속을 증명하는 시·구·읍·면의 장의 서면 또는 이를 증명함에 족한 서면을 첨부하여야 한다고 직접 규정하고 있었다(구법 제46조). 개정법 및 규칙에서는 구법 제46조와 같은 명시적인 규정은 없으나, 이러한 상속을 증명하는 정보는 규칙 제46조제1항제1호의 등기원인을 증명하는 정보로 볼 수 있을 것이다.

상속을 증명하는 정보로서 가장 대표적인 것이 제적등·초본 및 기본증명서, 가족관계증명서, 친양자입양관계증명서인바, 여기에는 피상속인의 사망사실과 상속인 전원을 알 수 있는 것을 첨부하여야 한다(선례 2-131).

2008. 1. 1.부터 구 호적제도가 가족관계등록제도로 변경되었는

바, 피상속인이 2008. 1. 1. 이후에 사망한 때에는 피상속인의 사망 사실과 상속인이 누구인지를 알 수 있는 가족관계등록증명정보를 첨부정보로 제공하여야 한다. 즉 피상속인의 사망사실 및 사망일자를 증명하는 정보인 기본증명서(가족관계의 등록 등에 관한 법률 제 15조제1항제2호)와 상속인임을 증명하는 피상속인의 가족관계증명서 및 친양자입양관계증명서(같은 법 제15조제1항제1호, 제5호)를 제공하여야 한다. 다만 현재의 가족관계등록부는 등록사항에 누락 사항이 존재할 수도 있으므로(2008. 1. 1. 이전에 사망 등으로 제적된 자는 가족관계증명서의 자녀란에 자녀로서 기록되지 아니함), 당분간은 구호적부의 제적등본 등을 첨부정보로 제공하여야 할 것이다.

친양자입양관계증명서가 필요한 이유는 친양자 입양으로 입양 전의 친족관계는 종료하는바(민법 제908조의3), 피상속인의 사망시점과 친양자 입양시점을 비교하여 상속인의 범위를 확정할 필요가 있기 때문이다.

2순위 이하의 상속인이 등기관리자가 되어 상속등기를 신청할 때에는 2순위 상속인(직계존속 중 친생부모 + 양부모)을 확인하기 위하여 추가로 피상속인의 입양관계증명서를 첨부하여야 한다. 이는 가족관계의 등록 등에 관한 법률의 개정으로 2010년 6월 30일부터는 자의 가족관계증명서의 부모란에 양부모만을 부모로 기록하고, 친생부모는 양부모와 함께 자의 입양관계증명서에 기록하는 것으로 변경되었기 때문이다(선례 201006-4).

피상속인이 2007. 12. 31. 이전에 사망한 경우에는 제적등·초본을 첨부정보로 제공하여야 한다. 제적등·초본을 제공하게 하는 이유는 2007. 12. 31. 이전에 사망신고된 사람은 가족관계등록부가

작성되지 아니하였을 뿐만 아니라, 피상속인의 사망 시 과거에는 대부분 호주승계(호주상속)로 인하여 호적부를 다시 편제하였는데, 피상속인의 사망사실이 피상속인이 호주였던 제적등·초본에 기재되기 때문이다. 따라서 피상속인의 제적에 관한 정보에 의하여 확인된 각 상속인에 대하여는 그의 가족관계등록증명정보(기본증명서 등)를 제공하여야 한다.

또한, 호주승계가 된 제적등·초본에는 구 호적법상 분가나 출가에 의하여 제적된 다른 상속인은 나타나지 아니하므로 상속인 전원의 범위와 그 상속인임을 소명하기 위해서 제적등·초본을 제공한다.

실무상 구 호적법상 여러 차례 전적 등으로 제적등·초본이 여러 개가 있는 경우에 피상속인의 혼인사실이 나타나고 자녀들이 혼인 등으로 법정분가 또는 타가입적할 수 있는 시기부터 현재까지의 신분변동상황이 연결되는 제적등·초본을 제공하도록 하고 있다.

다만 호주상속인을 제외한 다른 상속인의 존부를 확인할 필요가 없는 구관습상의 호주상속에 따른 재산상속등기를 신청함에 있어서는 호주상속 개시사실과 호주상속인이 기재된 제적등·초본 및 기본증명서를 첨부하면 되고 별도로 피상속인의 제적등·초본이나 다른 직계비속의 제적등·초본 또는 가족관계등록사항별증명서를 첨부할 필요는 없다(선례 4-361, 5-281). 또한, 취적허가에 의하여 새 호적이 편제된 경우에는 취적 전의 제적등·초본은 제출할 필요가 없다(선례 6-91).

나. 제적등·초본 등을 발급받을 수 없는 경우

만일 제적등·초본이 관할구청에 비치되어 있지 않아 제적등·초본을 발급받을 수 없어 상속인의 일부를 확정할 수 없는 경우에는

그 제적등·초본 등이 소실되어 비치되어 있지 않다는 관할 구청장의 증명서 및 다른 상속인이 존재하지 아니한다는 취지의 나머지 공동상속인 연서의 진술서를 제출케 하여 제적등·초본상에 다른 상속인이 있는 것으로 보이는 특별한 사유가 없는 한(특별한 사유의 유무는 결국 등기관이 판단사항이다), 그 제적등·초본을 제외한 나머지 관련 제적등·초본 및 기본증명서, 가족관계증명서, 친양자입양관계증명서 등에 의하여 상속등기를 할 수 있다(예규 제409호, 선례 5-287).

또한, 소실되어 재제한 제적등·초본에 일부 기재사항이 누락되어 있더라도 동일인임을 알 수 있다면 상속(대습)으로 인한 소유권등기를 신청할 수 있다(선례 7-195).

주민등록표는 상속을 증명하는 서면이라고 볼 수 없으므로 비록 주민등록표에 사망으로 기재되어 있다 하더라도 제적등·초본 또는 기본증명서에 사망으로 기록되어 있지 않으면 그 주민등록표를 상속을 증명하는 서면으로 하여 상속등기를 할 수 없다(선례 5-213). 이때에는 먼저 가족관계등록부에 피상속인에 대한 사망처리를 하여 기본증명서와 주민등록표를 일치시킨 후에 상속등기를 하여야 한다(선례 1-310).

피상속인의 본적이 군사분계선 이북지역에 있어 상속을 증명하는 서면을 제출할 수 없는 경우에 그 상속등기는 허용되지 않을 것이나(선례 7-177), 군사분계선 이북지역에 호적을 가졌던 자의 취적(또는 가족관계등록부의 창설)으로 그 호적(또는 가족관계등록부)에 등재(또는 등록)된 군사분계선 이북지역의 상속인 전원에 대하여 부재선고등에관한특별조치법의 규정에 의한 부재선고심판이 확정된 경우에는 다른 상속인에 의한 상속등기는 허용된다(선례 7-191).

다. 상속을 증명하는 정보를 제공할 필요가 없는 경우

갑의 증조부가 사정받은 토지를 망 조부를 거쳐 망부로 순차 단독 상속된 후 망부의 공동상속인들 간의 상속재산 협의분할을 통하여 단독상속인이 된 갑이 소유권보존등기명의인을 상대로 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기절차이행을 명하는 승소확정판결을 받은 경우와 같이, 등기관리자의 상속인이 등기부상 최종 소유자를 상대로 하여 진정명의회복을 원인으로 하는 승소판결을 받은 경우에는 상속을 증명하는 서면을 제출할 필요가 없다(선례 7-179).

이러한 경우 통상 판결주문은 “피고는 갑에게 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기절차를 이행하라.”고 기재되므로, 등기관으로서는 판결이유를 보지 않고서는 상속인의 신청(법 제27조)에 의한 등기인지를 알 수 없고, 소송 시에 제출한 서면을 등기신청 시에 다시 제출케 하는 것은 불합리하기 때문이다.

이에 반해 승소한 판결문의 이유 중에 원고들의 피상속인이 부동산을 시효취득한 사실 및 원고들이 소유권이전등기청구권을 공동상속한 사실이 기재되어 있는 경우에는 판결정본과 상속재산협의분할서(상속인 전원의 인감증명서 첨부) 등 구 부동산등기법 제46조(개정규칙 제46조) 소정의 상속을 증명하는 서면을 첨부하여 원고들 중 1인의 단독소유로 하는 소유권이전등기를 신청할 수 있다(선례 8-190). 이는 판결주문에 기재된 법정상속분대로의 등기 대신 상속인 간의 상속재산협의분할에 의한 등기신청이 가능하고, 그 상속재산분할협의를 증명하기 위해서 상속을 증명하는 서면이 필요하다는 것이므로 상속증명서면을 제출할 필요가 없다는 위 등기선례 7-179와 모순되지는 않는다.

라. 가족관계등록사항별증명서 등의 유효기간

등기신청서에 첨부하는 가족관계등록사항별증명서 및 제적등·초본의 유효기간은 발행일부터 3월 이내의 것이어야 한다(규칙 제 62조).

마. 상속을 증명하는 정보 등에 대한 등기관의 심사권

상속을 증명하는 정보 또는 이를 증명함에 족한 정보와 관계법령에 기한 상속인의 범위 및 상속지분의 인정은 등기관의 형식적 심사 권한의 범위 내이다. 따라서 위와 같은 정보와 관계법령에 의하여 인정되는 정당한 상속인의 범위 및 상속지분과 다른 내용으로 상속 등기를 신청하는 경우에 등기관으로서는 신청내용(상속분)이 그 상속재산과 관련한 소송의 확정판결의 내용과 일치하더라도 그 등기 신청을 각하하여야 한다. 왜냐하면 등기신청인이 산정한 상속분이 그 상속재산을 둘러싼 소송에서도 받아들여져 판결로써 확정되었더라도 상속등기신청에 대한 등기관의 형식적 심사권에는 위 확정판결의 기판력이 미치지 않기 때문이다(대법원 1995. 2. 22. 자 94마 2116 결정).

2. 주소를 증명하는 정보

가. 피상속인의 경우

피상속인의 주소를 증명하는 정보는 등기명의인이 피상속인임을 증명하기 위해 요구되는 경우 외에는 첨부정보로 제공할 필요가 없다(선례 3-672). 다만 기본증명서와 제적등·초본만으로 등기부상의 등기명의인과 피상속인이 동일인임이 인정된다고 볼 수 없는 경우(등

기기록상 또는 제적등·초본, 기본증명서에 주민등록번호가 기재되어 있지 않는 등)에는 그 동일성 확인을 위하여 피상속인의 주소를 증명하는 서면(말소된 주민등록표초본 등)을 제출할 필요성이 있으며(선례 4-351), 이 경우에는 실무상 피상속인의 주소를 증명하는 정보를 제공하도록 하고 있다.

위의 경우에 피상속인이 주민등록표상에 등록된 사실도 없는 경우(주민등록법이 시행되기 전에 피상속인이 사망한 경우 등)에는 시·구·읍·면장의 동일인 증명이나 그 사실을 확인하는데 상당하다고 인정되는 자의 보증서면과 그 인감증명 및 기타 보증인자격을 인정할 만한 서면(예를 들어 공무원 재직증명서, 변호사등록증서사본, 법무사자격증사본 등)을 첨부하여 상속등기를 신청할 수 있다. 구체적인 등기신청에 있어서 이러한 서면에 의한 동일인 인정 여부는 그 등기사건을 처리하는 등기관이 판단하여야 할 것이다(선례 7-176).

나. 상속인의 경우

소유권이전등기를 신청하는 경우에는 신청인의 주소를 증명하는 정보를 제공하도록 하고 있으므로(규칙 제46조제1항제6호), 등기명의인이 될 상속인의 주소증명정보로 주민등록등·초본, 재외국민거주사실증명이나 재외국민등록부등본, 기본증명서 등을 제공하여야 하지만, 등기명의인이 아닌 상속인의 주소를 증명하는 정보는 제공할 필요가 없다. 다만 상속을 증명하는 정보(제적등·초본, 기본증명서, 가족관계증명서, 친양자입양관계증명서 등)와 상속재산분할협의서 및 인감증명서상 상속인의 표시만으로 각 서면상의 상속인이 동일인임을 알 수 없는 경우에는 동일인임을 증명하는 정보를 제

출하여야 하는바, 그 동일인임을 증명하는 서면으로써 실무상 주민등록등·초본을 제공토록 하고 있다.

또한, 상속재산분할협의서에 기재한 상속인의 주소와 인감증명서의 주소가 부합하지 않는 경우에도 동일인임을 증명하는 서면을 제출하여야 한다(선례 7-76).

3. 공동상속인이 행방불명된 경우 등

공동상속인 중 일부가 행방불명으로 주민등록이 말소된 경우에는 말소된 주민등록등·초본을 첨부하여 그 최후 주소를 주소지로, 호적등본 또는 제적등본상(또는 제적등·초본이나 기본증명서상) 주민등록번호가 기재되어 있지 않고 달리 주소를 확인할 수 없어 주민등록등·초본을 발급받을 수 없는 때에는 이를 소명하여 제적등·초본상 본적지(또는 가족관계등록부상 등록기준지)를 그 주소지로 하여 상속등기를 신청할 수 있다(선례 2-94, 6-257).

공동상속인 중 일부인 재외국민이 상속등기를 기피할 목적으로 재외국민등록부등본의 교부신청에 협력하지 아니하여 현주소를 알 수 없을 때는 그 상속인의 주소를 증명하는 서면으로 말소된 주민등록등본과 재외국민의 현주소를 알 수 없다는 소명자료를 첨부하여 말소된 주민등록등본상의 최후 주소로 상속등기를 신청할 수 있다(선례 7-74).

미수복지구에 호적을 가진 자와 혼인한 사유로 제적된 사실만 나타나는 행방불명자의 경우에는 그 제적사유에 기재된 혼가(婚家)의 본적지를 주소지로 하여 상속등기를 신청할 수 있다(예규 제577호, 선례 3-394).

4. 상속재산의 분할을 증명하는 정보 및 상속포기의 경우에 가정법원의 상속포기수리증명서

상속재산에 관하여 협의분할을 하였을 경우에는 상속인 전원이 참여하여 작성한 협의분할서를 제공하여야 하고, 이 협의분할서에 날인한 상속인 전원의 인감증명을 제출하여야 한다(규칙 제60조제1항제6호). 또한, 협의분할 시 특별대리인을 선임한 경우에는 그 선임을 증명하는 정보 및 그 특별대리인의 인감증명도 제출하여야 한다. 상속재산 협의분할계약서가 여러 장인 경우에는 공동상속인 전원이 간인하여야 한다(선례 3-43). 상속인 중 상속을 포기한 자가 있는 경우에는 상속포기신고를 수리하는 뜻의 심판서정본을 첨부정보로 제공하여야 한다.

5. 특별수익자의 상속분과 기여분

공동상속인 중에 피상속인으로부터 자기의 상속분을 초과하여 증여를 받은 특별수익자(민법 제1008조)가 있는 경우, 위 특별수익자를 제외한 나머지 공동상속인들이 그들 명의로 상속등기를 신청함에 있어서는 특별수익자에게는 상속분이 없음을 증명하는 서면(판결 또는 위 특별수익자가 작성하고 그의 인감증명서를 첨부한 확인서)을 첨부하여야 한다(선례 2-291, 5-305). 피상속인의 재산 유지 또는 증가에 특별히 기여한 자(피상속인을 특별히 부양한 자 포함)가 있을 경우에는 그자의 기여분을 공동상속인의 협의로 정하거나, 협의가 되지 아니하거나 협의할 수 없을 때에는 기여자가 가정법원에 상속재산의 분할(가사소송법 제2조의 마류 사건 제10호) 및 기여분(가사소송법

제2조의 마류 사건 제9호)에 관하여 심판청구(가사소송법 제36조)를 하여 결정된 심판서에 따라 상속등기를 할 수 있다(선례 7-172).

6. 상속권을 상실(결격)한 것을 증명하는 정보

상속권을 상실한 자가 있는 경우에는 결격사유를 증명하는 서면으로 판결의 등본을 첨부하여야 하나, 대법원판결등본을 첨부하는 경우에는 확정증명원까지 첨부할 필요는 없다(선례 4-359).

제 5 절 | 상속등기 후의 소유권경정등기

1. 서 설

가. 소유권경정등기의 허용

소유권경정등기는 등기명의인의 동일성이 인정되는 범위 내에서 제한적으로 허용되어야 하나, 상속등기에서는 법정상속분대로 등기된 후 협의분할에 의하여 소유권경정등기를 신청하는 경우 또는 협의분할에 의한 상속등기 후 협의해제를 원인으로 한 법정상속분대로의 소유권경정등기 등을 폭넓게 허용하고 있다(예규 제1421호).

나. 경정등기의 허용이유

상속개시 후에 상속인 중 1인이 상속을 포기하거나 결격자가 될 수도 있고, 상속인들이 상속재산을 언제든지 협의분할을 할 수도 있다(민법 제1013조제1항). 그럼에도 공동상속인 중 1인 또는 피상속

인(또는 상속인)의 채권자의 대위에 의한 등기신청에 의하여 공동상속등기가 경료되면 이는 공동상속인의 의사에 반하거나 실체관계에 부합하지 아니하는 결과가 될 수 있으므로 이를 바로잡기 위하여 상속등기의 경정등기를 인정한다.

다시 말해서 경정등기를 허용하는 이유는 상속인들의 의사를 존중하고 등기를 실체에 합치시키기 위함이다.

다. 경정등기의 구체적 사례

(i) 상속등기 후 공동상속인 중 1인에 대하여 친생자관계부존재확인 판결이 확정되어 호적이 정리된 경우(선례 6-411), (ii) 상속등기 후 공동상속인 중 1인에게 실종선고심판이 확정된 경우(선례 6-213), (iii) 공동상속인 중 일부가 상속포기를 하였으나 이를 간과한 채 상속등기를 신청하여 상속포기 전의 공동상속인 전원 앞으로 상속등기가 잘못 경료된 경우(선례 3-460), (iv) 공동상속인 중 일부가 누락된 채 상속등기가 경료된 경우 등에는 경정등기를 신청할 수 있다.

2. 경정등기절차

가. 신청정보 및 첨부정보

상속등기 후에 협의분할을 하거나 재판에 의한 분할을 한 경우에 경정등기의 신청절차는 권리를 취득하는 자가 등기관리자, 권리를 잃는 자가 등기의무자로서 소유권의 경정등기를 신청하여야 한다(예규 제613호).

이때 등기원인은 “협의분할로 인한 (재산)상속” 또는 “○○지방법

원의 확정판결(또는 화해, 인낙)에 의한 (재산)상속"이라고 기재하고 그 등기원인일자는 "피상속인의 사망일"이 아닌 "협의분할일"로 기재한다. 상속등기 후 상속재산의 협의분할로 인한 소유권경정 등기 기록례는 다음과 같다.

【갑 구】 (소유권에 관한 사항)				
순위 번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
2	소유권이전	2010년 3월 5일 제3500호	2010년 2월 23일 상속	공유자 지분 3분의 1 아도령 500124-1056407 서울특별시 중구 화현동 7 지분 3분의 1 이일남 530425-1056408 서울특별시 중구 저동 8 지분 3분의 1 이아남 540320-1617312 서울특별시 중구 다동 5
2-1	2번소유권 경정	2010년 7월 4일 제6500호	2010년 6월 29일 협의분할로 인 한 상속	공유자 지분 2분의 1 이일남 530425-1056408 서울특별시 중구 저동 8 지분 2분의 1 이아남 540320-1617312 서울특별시 중구 다동 5

상속등기 후 경정등기를 신청하는 경우에는 상속재산협의분할이 있었다는 사실을 증명하는 정보로 상속재산분할협의서 또는 재판서 등본, 경정등기로 인한 이해관계인이 있으면 그의 승낙을 증명하는 정보 등과 권리를 취득하지 아니하는 상속인의 인감증명을 첨부정보로 제공하여야 한다.

나. 등기의 실행

이 등기의 실질은 일부말소 의미의 경정등기이지만 등기형식은 소유권경정등기의 방식으로 기록된다(위 기록례 참조). 기존등기의 원인은 이를 경정하지 아니하고 권리자에 관한 사항만 부기등기의 형식으로 경정한다. 또한, 소유권경정등기로 인하여 공유지분을 상실하는 공동상속인의 지분만을 목적으로 하는 이해관계인의 등기(근저당권등기 등)를 직권말소하고, 공유지분이 변경(감소)되는 경우에는 변경 전의 지분을 목적으로 한 근저당권등기 등을 직권경정한다. 경정등기로 인하여 소멸하는 공동상속인의 지분 및 그 이외의 지분을 목적으로 하는 등기상 이해관계인의 등기도 직권경정의 대상이다(예규 제1366호).

3. 상속등기 후 경정등기 전에 이해관계인이 발생한 경우의 처리

가. 공동상속인 중의 일부 지분이 이전된 경우

협의분할에 따른 소유권경정등기의 효력은 당초의 상속등기에 소급하여 미치게 되나 경정등기 시까지 그 부동산에 관한 권리를 가지는 제3자가 있는 때에는 그 소급효로써 제3자에게 대항할 수 없다. 따라서 상속등기 후에 그 공동상속인 중의 일부가 그 지분을 타인에게 이전한 경우에 협의분할로 인한 소유권경정등기를 하기 위해서는 먼저 상속등기 후 이루어진 소유권이전등기를 정당한 말소사유에 의하여 말소한 후 상속등기의 경정등기를 경료하여야 한다(선례 5-542).

나. 공동상속인 중 일부의 상속지분에 대하여 가압류등기가 경료된 경우

법정상속분대로 상속등기가 된 뒤 그 상속인 중 1인(갑)의 지분에 대한 가압류등기 등 이해관계인이 생긴 경우, 협의분할에 따른 경정등기의 신청 시 갑이 그 권리를 상실하거나 지분이 감소하는 때에는 이해관계 있는 제3자인 가압류권자의 승낙서 또는 이에 대항할 수 있는 재판서의 등본을 첨부하여야 한다. 이 경우 경정등기는 기존 법정상속분대로 등기된 상속인의 소유권이전등기 말소와 같은 효력을 가지기 때문이다. 만일 가압류권자의 승낙서 등이 첨부된 때에는 등기관은 위 가압류등기를 직권으로 말소하거나 경정(일부 말소의 의미로서)하여야 한다(선례 8-198).

다. 공동상속인 중 1인이 사망한 경우

피상속인의 사망으로 상속이 개시된 후 상속등기가 마쳐진 경우가 아니라면 공동상속인 중 1인이 사망한 경우에도 사망한 자의 상속인과 나머지 공동상속인이 피상속인의 재산에 대한 협의분할을 할 수 있다(선례 7-178). 예컨대, 피상속인의 사망으로 공동상속인 갑, 을, 병이 있는데, 이 중 갑이 사망하고 그 상속인으로 정과 무가 있을 때 을, 병과 정, 무는 협의분할로 상속등기를 신청할 수 있을 것이다.

그러나 피상속인의 사망으로 그 소유 부동산에 관하여 법정상속지분에 의한 등기가 마쳐진 후 공동상속인 중 1인이 사망하였다면, 그 상속등기에 대해서는 상속재산분할협의를 의한 소유권경정등기는 할 수 없다(선례 6-202). 이 경우 사망한 1인의 상속인과 나머지 공동상속인 사이에 상속재산분할협의를 원인으로 한 지분이전등기

를 명하는 조정에 갈음하는 결정이 확정된 경우에도 경정등기는 할 수 없을 것이다(선례 8-197).

4. 협의에 의한 상속재산의 분할등기 후 재협의에 의한 경정등기

상속등기의 경우 소유권경정등기를 폭넓게 허용함은 앞에서 설명하였다. 이에 따라 협의분할에 의한 상속등기 후 공동상속인 전원이 그 분할계약을 해제하고 새로이 협의분할에 의한 상속등기신청을 하는 것 또한 등기기록상 이해관계인의 동의가 있는 한 허용되어야 할 것이다.

등기선례도 상속인 전원의 협의로 상속인 중 갑, 을 공유를 갑 단독소유로 하는 소유권경정등기를 허용하고(선례 8-199) 있으므로, 갑에서 을로 경정하거나 갑과 을의 공동상속에서 병과 정을 공동상속인으로 하는 상속등기의 재협의에 의한 경정등기도 허용될 것이다. 일반적인 경정등기라면 경정 전후의 등기명의인이 달라지는 것은 허용될 수 없으나, 상속재산분할협의의 경우에는 분할계약을 해제하고 새로이 협의분할을 하는 것이 가능하므로 공동상속인 범위 내에서의 경정등기는 허용된다고 보는 것이다.

이 경우의 경정등기도 공동상속인 중 1인이 사망한 후에는 허용되지 않는다.

제7장 | 그 밖의 등기원인에 의한 상속등기

제 1 절 | 총 설

상속등기의 등기원인에 대해서는 민법 개정에 따라 그 원인을 달리했는데, 구민법상은 상속의 등기원인으로 호주상속과 유산상속, 1990년 민법개정 이전에는 호주상속과 재산상속의 두 가지가 있었다. 1990년 민법개정 이후에는 호주상속이 호주승계로 되어 상속이란 재산상속만을 의미하기 때문에 재산상속이라 하지 않고 ‘상속’이라고 한다.

피상속인의 사망으로 인한 상속등기는 일반적인 상속을 원인으로 하는 등기 외에도 다양한 등기원인이 있다. 그 밖의 등기원인으로는 실종선고, 유류분반환, 상속재산의 분리, 상속인의 부존재로 인한 특별연고자에 대한 분여 등을 들 수 있다. 이하에서는 이러한 등기원인에 의한 상속등기에 관하여 설명하기로 한다.

제 2 절 | 실종선고로 인한 소유권이전등기

1. 상속개시의 시기

실종선고에 의하여 사망한 것으로 간주되는 시기에 관하여 우리 민법은 실종기간 만료 시에 사망한 것으로 규정하고 있다(민법 제28조). 그 실종기간이 구민법(또는 개정 전 민법)시행 기간 중에 만료되

는 때에도 그 실종선고가 신민법(또는 각 개정된 민법)시행일 후에 선고된 경우에는 그 상속순위, 상속분 기타 상속에 관하여는 신민법(또는 각 개정된 민법)의 규정을 적용한다.

따라서 1955. 7. 15. 실종기간이 만료된 자에 대하여 1979. 9. 16. 실종선고가 있었다면 실종선고로 인한 재산상속의 순위, 상속분 기타 상속에 관하여는 민법 부칙(1977. 12. 31. 법률 제3051호) ⑤항 및 민법 부칙(1958. 2. 22. 법률 제471호) 제25조제2항에 의하여, 1960. 1. 1. 부터 시행된 민법(1958. 2. 22. 법률 제471호)의 규정이 적용된다(선례 8-185).

2. 등기신청절차

실종선고로 상속이 개시되는 경우에 그 실종선고의 효과는 실종기간이 만료한 때로 소급하게 되므로, 등기를 신청하는 경우 등기원인은 “상속”으로, 등기원인일자는 “실종기간만료일”을 각각 신청정보로 제공하여야 한다.

실종선고로 인하여 호주 또는 재산상속이 개시되는 경우에 그 실종기간이 구법시행 기간에 만료하는 때에도 그 실종이 신법시행일 후에 선고된 때에는 그 상속순위, 상속분 기타 상속에 관하여는 신법을 적용하게 되어 있으며(민법 부칙 제25조), 실종선고의 효과는 실종기간이 만료한 때에 소급하게 되므로(민법 제28조) 등기기록의 기재는 구법시행 기간 중의 일자를 등기원인일자로 하고 상속원인은 신법의 원인을 기재한다(예규 제57호). 예를 들어 “1959년 1월 5일 재산상속(1964년 1월 5일 실종선고)”와 같이 기재하면 될 것이다. 실종기간의 만료로 인한 상속등기의 등기기록례는 다음과 같다.

【갑 구】 (소유권에 관한 사항)				
순위 번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
3	소유권이전	2005년 3월 5일 제3500호	1959년 1월 5일 재산상속(1964 년 1월 5일 실 종선고)	공유자 지분 6분의 3 이도령 500124-1056407 서울특별시 중구 회현동 7 지분 6분의 2 이일남 530425-1056408 서울특별시 중구 저동 8 지분 6분의 1 이이남 540320-1617312 서울특별시 중구 다동 5

실종으로 인한 상속을 증명하는 정보로는 일반적인 상속을 증명하는 정보 외에 실종선고심판정본을 첨부정보로 제공하여야 한다. 다만 실종선고에 따라 가족관계등록부(구 호적부) 등이 정리되어 있을 경우에는 그 실종선고에 따른 상속등기 시 당해 실종선고심판정본을 첨부정보로 제공할 필요는 없다(선례 5-302).

제 3 절 | 유류분반환으로 인한 소유권이전등기

1. 서 설

유류분제도는 상속개시 후 상속인의 재산 중 일정 범위에 대하여 상속인에게 상속받을 권리를 보장하여 주는 제도를 말한다. 따라서 유류분의 범위에 대하여는 피상속인은 자신의 재산임에도 불구하고 처분의 자유가 일정 범위에서 제한된다.

유류분권이란 상속개시 후 일정한 범위의 상속인이 피상속인의 상속재산의 일정한 비율을 확보할 수 있는 지위 또는 권리를 말한다. 이러한 유류분권에 근거하여 상속인은 상속분을 침해하는 유증·증여의 효력을 빼앗아 수증자에게 그 반환을 청구할 수 있는 반환청구권이 생긴다.

이하에서는 유류분의 범위, 유류분반환청구권 및 유류분반환청구로 인한 소유권이전등기절차에 대해서 설명하기로 한다.

2. 유류분의 범위

가. 유류분권리자

유류분을 가지는 자는 제1순위 내지 제3순위 상속인인 피상속인의 직계비속·배우자·직계존속·형제자매이다(민법 제1112조). 유류분을 행사할 수 있는 자는 재산상속의 순위상 상속권이 있는 자이어야 한다. 따라서 제1순위 상속인인 직계비속과 배우자가 있는 경우에는 제2순위 상속인인 직계존속은 유류분권을 행사할 수 없다. 또한, 제4순위 상속인인 3촌·4촌 이내의 방계혈족에게는 유류분권이 인정되지 않는다.

대습상속인도 피대습자의 유류분의 범위 내에서 유류분권을 가진다. 태아도 살아서 출생하면 직계비속으로서 당연히 유류분권을 가진다. 그러나 유류분권은 상속을 전제로 하여 인정되는 권리이므로 상속결격자와 상속포기자는 상속권을 상실하였기 때문에 당연히 유류분권도 없다.

유류분권리자의 채권자도 채권자대위권의 행사로 유류분반환청구권을 행사할 수 있다는 것이 통설이나, 판례는 “유류분반환청구권은

그 행사 여부가 유류분권리자의 인격적 이익을 위하여 그의 자유로운 의사결정에 전적으로 맡겨진 권리로서 행사상의 일신전속성을 가진다고 보아야 하므로, 유류분권리자에게 그 권리행사의 확정적 의사가 있다고 인정되는 경우가 아니라면 채권자대위권의 목적이 될 수 없다.”고 하여 원칙적으로 채권자대위권의 객체가 될 수 없다는 입장이다(대법원 2010. 5. 27. 선고 2009다93992 판결).

나. 유류분

- ① 피상속인의 직계비속은 그 법정상속분의 2분의 1
- ② 피상속인의 배우자는 그 법정상속분의 2분의 1
- ③ 피상속인의 직계존속은 그 법정상속분의 3분의 1
- ④ 피상속인의 형제자매는 그 법정상속분의 3분의 1

3. 유류분의 산정

가. 유류분산정의 기초재산

유류분의 액수를 산출하기 위해서는 우선 산정의 기초가 되는 피상속인의 재산을 확정하여야 한다. 피상속인의 재산액은 피상속인의 상속개시 시에 있어서 가진 재산의 가액에 증여재산의 가액을 가산하고 채무의 전액을 공제하여 이를 산정한다(민법 제1113조제1항). 재산평가의 방법은 상속분의 산정과 같지만, 조건부권리 또는 존속기간이 불확정한 권리는 가정법원이 선임한 감정인의 평가에 의하여 그 가액을 정한다(민법 제1113조제2항).

나. 증여재산에 산입되는 재산

증여재산으로는 상속개시 전의 1년간에 행하여진 증여재산만이 산입된다. 다만 예외적으로 당사자 쌍방이 유류분권리자에 손해를 가할 것을 알고 증여를 한 때에는 1년 이전의 것도 포함된다(민법 제1114조).

증여라 함은 널리 모든 무상처분을 의미하며 법인설립을 위한 출연행위, 무상의 채무면제, 무상의 인적 또는 물적담보의 제공 등도 포함된다.

부담이 있는 증여는 그 목적의 가액 중에서 부담의 가액을 공제하고 산입하여야 한다. 또한, 상속인의 특별수익분은 1년보다 이전 것이라도 모두 산입한다(민법 제1118조, 제1008조).

다. 공제되어야 할 채무

공제되어야 할 채무에는 사법상의 채무뿐만 아니라 상속인의 부담이 되는 채무는 공법상의 채무, 즉 세금이나 벌금도 포함된다.

라. 유류분액의 계산

상속인 각자의 유류분의 액은 유류분산정의 기초가 되는 재산액에 그 상속인의 유류분의 비율을 곱한 금액이다.

【(적극상속재산+1년 간의 선의의 증여액+1년 이전의 악의의 증여액+상속인의 특별수익액+조건부권리의 평가액)-상속채무】×상속인의 유류분율-상속인의 수증액이나 특별수익액=유류분액이 된다.

4. 유류분반환청구권

가. 의 의

유류분권리자는 상속받은 재산이 유류분에 미치지 못하는 경우에 유증 또는 증여받은 자에 대하여 반환청구권을 행사할 수 있다(민법 제1115조제1항). 이러한 유류분반환청구권은 유류분권리자의 의사에 달려 있으며, 유류분에 대한 침해행위는 피상속인의 행위로 인한 것이어야 한다.

유류분반환청구는 유류분권리자가 유증받은 자와 증여받은 자 및 그 상속인에 대한 의사표시로 한다. 유언집행자가 있는 경우에는 유증에 대한 반환청구의 의사표시를 유언집행자에 대해서도 할 수 있다. 유류분을 침해하여 과다 상속받은 공동상속인도 상대방이 될 수 있다.

나. 반환의 범위

유류분의 보전은 유류분에 부족한 한도에서 하여야 한다(민법 제1115조제1항). 또한, 증여 유증을 받은 자가 수인인 때에는 각자가 얻은 유증가액의 비례로 반환하여야 한다(민법 제1115조제2항).

반환청구의 범위에 대해 판례는 “유류분권리자가 유류분반환청구를 함에 있어 증여 또는 유증을 받은 다른 공동상속인이 수인일 때에는 각자 증여 또는 유증을 받은 재산 등의 가액이 자기 고유의 유류분액을 초과하는 상속인에 대하여 그 유류분액을 초과한 가액의 비율에 따라서 반환을 청구할 수 있고, 공동상속인과 공동상속인 아닌 제3자가 있는 경우에는 그 제3자에게는 유류분이 없으므로 공동상속인에 대하여는 자기 고유의 유류분액을 초과한 가액을 기준으로 하여, 제3자에 대하여는 그 증여 또는 유증받은 재산의 가액을 기준으로 하여 그 각 가액의 비율에 따라 반환청구를 할 수 있다.”고 하여 각 초과부분의 비율에 따라 유류분반환청구권을 행사할 수 있

다고 한다(대법원 2006. 11. 10. 선고 2006다46346 판결).

또한, 유류분반환청구권의 행사에 의하여 반환하여야 할 유증 또는 증여의 목적이 된 재산이 타인에게 양도된 경우 그 양수인이 양도 당시 유류분권리자를 해함을 안 때에는 양수인에 대하여도 그 재산의 반환을 청구할 수 있다(대법원 2002. 4. 26. 선고 2000다8878 판결).

다. 반환청구의 순서

반환청구를 받게 되는 증여 또는 유증이 복수인 경우에 증여에 대하여는 유증을 반환받은 후가 아니면 반환을 청구할 수 없다(민법 제1116조). 사인증여도 유증에 준하는 것으로 보아 증여보다 먼저 반환을 받아야 한다(대법원 2001. 11. 30. 선고 2000다6947 판결).

라. 유류분반환청구권의 소멸

유류분반환청구권은 유류분권리자가 상속의 개시와 반환하여야 할 증여 또는 유증을 한 사실을 안 때로부터 1년 이내에 행사하지 않으면 시효가 완성되어 소멸한다(민법 제1117조 전단). 이 1년의 기간은 소멸시효라는 것이 통설 및 판례(대법원 1993. 4. 13. 선고 92다3595 판결)의 입장이다.

또한, 유류분반환청구권은 상속이 개시된 날로부터 10년을 경과하면 소멸한다(민법 제1117조 후단). 이 10년의 기간에 대해서는 다수설은 제척기간이라고 보고 있으나, 판례는 이 기간을 소멸시효기간이라고 보고 있다(대법원 1993. 4. 13. 선고 93다3595 판결). 따라서 그 권리행사의 의사표시로 소멸시효의 진행이 중단된다(대법원 2002. 4. 26. 선고 2000다8878 판결).

5. 유류분반환으로 인한 소유권이전등기절차

유류분반환으로 인한 소유권이전등기는 피상속인이 상속인 중 1인에게 유증 또는 증여함으로써 인하여 그 상속인들의 유류분에 부족이 생겨 부족한 한도에서 상속재산 중 일정 부분을 유류분으로 반환을 청구하는 절차이다.

유류분반환으로 인한 소유권이전등기신청 시 등기원인은 “유류분 반환”으로 하며, 등기원인일자는 반환청구의 의사를 표시한 날을 신청정보로 제공하여야 한다. 만약 소에 의하여 반환청구의 의사표시를 한 때에는 소장송달일이 원인일자가 될 것이다.

유류분반환으로 인한 소유권이전등기의 등기기록례는 다음과 같다.

[갑 구] (소유권에 관한 사항)				
순위 번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
3	소유권일부 이전	2010년 3월 5일 제3500호	2010년 2월 5일 유류분반환	공유자 지분 3분의 1 이도령 500124-1056407 서울특별시 중구 회현동 7

유류분반환으로 인한 등기를 신청하는 경우 유증으로 인해 유류분이 발생한 경우에는 유언증서와 유류분반환협의서, 증여로 인한 경우에는 증여계약서와 유류분반환계약서를 유류분임을 증명하는 정보로 제공하여야 한다. 유류분반환을 원인으로 하는 소유권이전등기절차의 이행을 명하는 판결 등이 있는 경우에는 판결문 등을 첨부정보로 제공하면 될 것이다.

유류분반환을 원인으로 하는 소유권이전등기절차에서는 일반 상속등기와 마찬가지로 농지취득자격증명을 첨부정보로 제공할 필요가 없다(선례 5-741). 또한, 피상속인으로부터 농지를 증여받은 피고들을 상대로 상속인인 원고들이 유류분반환청구소송을 제기하여 소송 진행 중 당사자 간에 소유권이전등기절차를 이행한다는 내용의 소송상 화해가 이루어진 경우, 설사 화해조항에 “유류분반환”이라는 등기원인이 기재되어 있지 않다 하더라도 화해조서 기재사항의 전체적 취지(청구취지 및 청구원인)에 의하여 상속인의 유류분보전을 위한 절차로서 소유권이전등기절차를 이행하는 것임이 인정되는 때에는, 그러한 화해조서를 첨부하여 농지에 대한 소유권이전등기를 신청함에 있어서는 농지취득자격증명을 첨부하지 않아도 될 것이다(선례 5-199).

제 4 절 | 상속재산의 분리

1. 서 설

상속재산의 분리란 상속개시 후에 상속채권자나 유증받은 자 또는 상속인의 채권자의 청구에 의하여 상속재산과 상속인의 고유재산을 분리시키는 가정법원의 처분을 말한다. 이 제도는 피상속인 또는 상속인의 고유재산을 믿고 거래한 채권자가 상속으로 인하여 양 재산이 혼합됨으로써 받게 될 불이익을 방지함에 그 취지가 있다.

2. 상속재산분리의 절차

가. 상속재산분리의 청구

(1) 청구권자

재산분리청구권자는 상속채권자, 유증받은 자 또는 상속인의 채권자이다(민법 제1045조). 상속인의 채권자는 상속개시 당시의 채권자에 한하지 않고 상속개시 후에 새로 채권을 취득한 채권자도 포함된다. 포괄수증자는 상속인과 동일한 지위에 있게 되므로 재산분리청구권이 없다고 보아야 할 것이다.

(2) 상대방

재산분리청구의 상대방에 대해서는 명문의 규정은 없으나, 상속인 또는 상속재산의 관리인, 파산관재인, 유언집행자 등이 될 것이다. 상속인이 수인 있으면 공동으로 상대방이 되며, 그 중 한 사람 또는 여러 사람이 한정승인을 하고 있더라도 마찬가지이다.

(3) 청구기간

재산분리청구기간은 상속이 개시된 날로부터 3월 내이다(민법 제1045조제1항). 그러나 상속인이 상속의 승인이나 포기를 하지 않은 동안은 3개월의 기간이 경과된 후라도 재산분리가 허용된다(같은 조 제2항). 상속인의 존재가 불분명한 경우에도 이 기간 내에 분리청구를 하여야 하며, 그 기간이 지나면 재산분리청구권은 소멸한다.

나. 법원의 분리명령과 그 공고

재산분리의 청구가 있으면 법원은 재산분리를 명하고, 재산분리청구권자는 법원의 분리명령이 있은 후 5일 이내에 일반상속채권자와 유증받은 자에 대하여 재산분리의 명령이 있는 사실과 2월 이상

의 기간을 정하여 그 기간 내에 채권 및 유증받은 사실을 신고할 것을 공고하여야 한다(민법 제1046조제1항).

재산분리의 공고절차에는 법인의 청산규정이 준용된다(민법 제1046조제2항). 즉 공고에는 일반상속채권자 또는 유증받은 자가 일정기간 내에 신고하지 않으면 배당변제에서 제외된다는 내용을 공고 중에 표시하여야 한다. 또한, 분리청구권자가 알고 있는 상속채권자와 유증받은 자에 대하여 각각 그 채권을 신고할 것을 최고하여야 한다(민법 제1046조제2항, 제88조제2항, 제3항, 제89조 전단).

3. 상속재산분리의 효과

가. 기본적 효과

재산분리로 인해 상속재산은 상속인의 고유재산으로부터 분리된다. 따라서 상속재산과 상속인의 고유재산이 아직 혼합되지 않은 경우에 상속인은 그 상태를 유지하여야 하며, 이미 혼합된 경우에는 양 재산을 분리하여야 한다.

상속재산에 대한 상속인의 권리와 의무는 가정법원의 상속재산분리심판 후에도 소멸하지 않는다(민법 제1050조). 즉 한정승인과 마찬가지로 재산의 분리는 상속재산과 상속인의 고유재산을 분리하되, 상속인이 피상속인에 대해서 가진 권리의무도 재산분리의 경우에 혼동으로 소멸하지 않도록 한 것이다.

상속으로 취득한 부동산은 등기할 필요가 없으나(민법 제187조), 재산이 분리된 경우에는 이를 등기하지 않으면 제3자에게 대항하지 못한다(민법 제1049조). 상속재산에 대하여 권리를 취득한 제3자의 이익을 보호하고 거래의 안전을 도모하기 위한 규정이다. 여기의 제

3자는 상속인의 채권자뿐만 아니라 모든 제3자를 포함한다. 한편 동산의 경우에는 제3자가 선의취득(민법 제249조)에 의하여 보호받을 수 있다.

나. 분리된 상속재산의 관리

법원이 재산분리를 명하는 때에는 상속재산의 관리에 필요한 처분을 명할 수 있다(민법 제1047조제1항). 여기서 “관리에 필요한 처분”이란 재산관리인의 선임, 상속재산의 목록 작성, 상속재산의 봉인, 훼손하기 쉬운 물건의 현금화 등을 말한다. 재산관리를 위해 법원이 재산관리인을 선임한 경우에는 부재자의 재산관리에 관한 제24조 내지 제26조가 준용된다(민법 제1047조제2항).

상속인이 단순승인을 한 후에도 법원으로부터 재산분리의 명령이 있는 때에는 상속재산에 대하여 자기의 재산과 동일한 주의로 관리하여야 한다(민법 제1048조제1항). 이때 상속인의 관리의무는 위임에 의한 수임인의 관리의무와 비슷하므로, 수임인의 권리의무에 관한 제683조 내지 제685조 및 제688조제1항, 제2항이 준용된다(민법 제1048조제2항).

다. 청산절차

(1) 최고기간 중의 변제거절

상속인은 상속재산의 분리청구기간(제1045조)과 상속채권자와 유증받은 자에 대한 공고기간(제1046조)이 만료하기 전에는 상속채권자와 유증받은 자에 대하여 변제를 거절할 수 있다(민법 제1051조제1항). 이러한 기간에 특정 상속채권자 또는 유증받은 자에게 일부변제를 하게 되면 나중에 변제받게 될 상속채권자 등에게 변제할 재산

이 없어 불의의 피해를 줄 수 있기 때문이다.

부당한 변제로 인하여 상속채권자 등에게 변제할 수 없게 되어 손해를 입힌 경우에는 상속인은 이를 배상할 책임이 있다(민법 제1051조제3항, 제1038조제1항).

(2) 상속재산에 의한 변제

재산분리의 청구기간과 상속채권자와 유증받은 자에 대한 공고기간이 만료한 이후에는 상속인은 상속재산으로써 재산의 분리를 청구한 상속채권자 또는 그 공고기간 내에 신고한 상속채권자, 유증받은 자에 대하여 상속재산으로 각 채권액과 수증액의 비율로 변제하여야 한다. 그러나 우선권 있는 채권자의 권리를 해하지 못한다(민법 제1052조).

변제기 전의 채권에 대한 변제는 배당변제규정에 따라 이루어져야 하며, 조건부 채권 또는 존속기간이 불확정한 채권은 법원이 선임한 감정인의 평가에 의하여 변제하여야 한다(민법 제1051조제3항, 제1035조).

상속인은 상속채권자에 대한 배당변제, 변제기 전의 상속채권, 조건부 채권에 대한 변제가 완료된 후가 아니면 유증받은 자에게 변제하지 못한다(민법 제1051조제3항, 제1036조). 즉 상속채권자가 유증받은 자보다 우선한다.

변제를 위하여 상속재산의 전부 또는 일부를 매각하여 현금화할 필요가 있는 경우에는 민사집행법에 의하여 경매하여야 한다(민법 제1051조제3항, 제1037조). 변제를 받지 못한 상속채권자 또는 유증받은 자는 그 사정을 알고 변제받은 상속채권자 또는 유증받은 자에 대하여 구상권을 행사할 수 있다(민법 제1051조제3항, 제1038조).

제2항).

(3) 고유재산에 의한 변제

재산의 분리를 청구하였거나 신고기간 내에 신고한 상속채권자와 유증받은 자는 상속재산에 의하여 채권 전부의 변제를 받을 수 없는 경우에 한하여 상속인의 고유재산으로부터 변제를 받을 수 있다(민법 제1052조제1항). 다만 이 경우에는 상속인의 채권자가 있으면 그가 상속채권자와 유증받은 자에 우선하여 상속인의 고유재산으로부터 변제받을 수 있다(민법 제1052조제2항). 상속인의 채권자의 우선권은 재산분리 당시의 고유채권자뿐만 아니라 그 후에 채권을 취득한 모든 채권자가 행사할 수 있다.

4. 상속재산분리의 등기절차

가. 의 의

상속재산의 분리는 상속재산인 부동산에 관하여 이를 등기하지 아니하면 제3자에게 대항하지 못한다(민법 제1049조). 분리명령이 있는 후에는 상속인은 상속재산의 처분행위를 할 수 없다. 이에 위반한 상속인의 처분행위는 원칙적으로 무효로 보아야 한다. 부동산에 관한 상속재산의 분리등기는 처분제한등기의 성질을 가진다.

상속재산분리에 관한 등기절차는 부동산등기법 등에 규정이 없으므로 일반적인 절차에 의하여야 할 것이다.

나. 등기신청절차

상속재산분리의 등기는 등기관리자(분리청구자)의 단독신청에 의

해 할 수 있는지에 대해 의문이 있으나, 그 성질상 법 제23조제3항의 상속에 따른 등기에 준하는 것으로 볼 수 있고, 또한 분리심판이 확정된 때에 심판의 확정을 증명하는 서면을 첨부하여 이루어지는 것이므로 단독신청을 인정하여도 부실등기가 이루어질 우려가 없다는 점에서 등기관리자가 단독으로 신청할 수 있다고 할 것이다.

등기를 신청하는 경우에는 규칙 제43조의 일반적인 신청정보 외에 등기원인은 “상속재산분리”, 등기원인일자는 “분리심판의 확정일”을 신청정보로 제공하여야 한다. 또한, 상속재산의 분리심판이 있었음을 증명하는 정보로 확정심판의 등본을 제공하여야 한다. 상속재산분리의 등기에 관한 등기기록례는 다음과 같다.

[갑 구] (소유권에 관한 사항)				
순위 번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
3	상속재산 분리	2010년 5월 4일 제3500호	2010년 2월 5일 상속재산분리	청구인 이도령 50124-1056407 서울특별시 중구 회현동 7

제 5 절 | 상속인의 부존재

1. 서 설

상속인의 부존재란 상속인의 존부가 분명하지 아니한 때를 말한다. 이 경우에 상속인을 수색하기 위하여 일정한 절차가 필요할 뿐만 아니라, 상속재산의 최후의 귀속자인 국가를 위하여 또는 상속채권자와 유증받은 자 등의 이익을 위하여 상속재산에 대한 관리와 청산을 할 필요가 있다. 이러한 필요를 위해 만들어진 것이 상속인부

존재제도이다.

상속인의 존부가 불분명한 경우뿐만 아니라 상속인이 없다는 것이 확정된 경우에도 상속재산의 청산절차가 필요하다. 따라서 “상속인의 존부가 불분명한 경우”로는 신원불명의 자가 사망한 경우, 가족관계등록부상 상속인이 없는 경우 또는 상속인 전원이 상속을 포기하여 상속인이 없는 경우 등을 들 수 있다. 다만 상속인의 존재는 분명하지만 그 행방이나 생사가 불분명한 경우에는 상속인부존재의 문제가 아니다. 이 경우에는 부재자로 보아 부재자의 재산관리문제가 발생할 뿐이다.

2. 상속재산의 관리와 청산

가. 상속재산의 관리

(1) 관리인의 선임

상속인의 존부가 분명하지 않은 경우에 가정법원은 민법 제777조 규정에 의한 피상속인의 친족 기타 이해관계인 또는 검사의 청구에 의하여 상속재산관리인을 선임하고 지체 없이 이를 공고하여야 한다(민법 제1053조제1항). 여기서 이해관계인은 상속채권자, 유증받은 자, 상속재산 위에 담보권을 가지는 자 등 상속재산에 대하여 법률상 이해관계를 가지는 자를 말한다.

선임된 상속재산관리인은 반드시 친족일 필요는 없으며(대법원 1977. 1. 11. 선고 76다184·185 판결), 공동상속인이 있는 경우에는 공동상속인 중 한 명이 관리인으로 선임되어야 한다(대법원 1979. 12. 27. 자 76그2 결정).

(2) 상속재산관리인의 지위

상속재산관리인은 원칙적으로 부재자의 재산관리인과 비슷하므로, 부재자를 위한 재산관리에 관한 규정이 준용된다(민법 제1053조제2항, 제24조부터 제26조). 상속재산관리인은 장래 나타날 상속인, 포괄수증자의 법정대리인 지위에 서게 되므로, 상속재산에 대한 소송의 정당한 당사자적격이 있다(대법원 1976. 12. 28. 선고 76다 797 판결).

상속재산관리인은 상속채권자나 유증받은 자의 청구가 있으면 언제든지 상속재산의 목록을 제시하고 그 상황을 보고하여야 한다(민법 제1054조).

상속인의 존재가 분명해진 경우에 관리인의 임무는 그 상속인이 상속의 승인을 한 때 종료한다(민법 제1055조제1항). 상속인이 승인하면 관리인은 지체 없이 그 상속인에 대하여 관리의 계산을 하여야 한다(민법 제1055조제2항).

나. 상속재산의 청산절차

(1) 청산공고

가정법원이 상속재산관리인의 선임을 공고한 날부터 3월 내에 상속인의 존부를 알 수 없는 경우에, 관리인은 지체 없이 일반상속채권자와 유증받은 자에 대하여 2월 이상의 기간을 정하여 그 기간 내에 채권 또는 유증받은 내용을 신고할 것을 공고하여야 한다(민법 제1056조제1항). 이 공고절차에는 한정승인 또는 재산분리에서와 마찬가지로 법인의 청산에 관한 규정이 준용된다(민법 제1056조제2항, 제88조제2항, 제3항, 제89조).

(2) 상속채무의 변제

상속재산관리인은 채권신고의 공고절차를 거친 후 일반상속채권자와 유증받은 자에 대하여 한정승인에 관한 변제의 순서와 방법에 따라 변제하여야 한다(민법 제1056조제2항, 제1033조부터 제1039조).

(3) 상속인수색의 공고

일반상속채권자 및 유증받은 자에 대한 채권신고를 최고하는 공고기간이 경과하여도 상속인의 존부를 알 수 없는 경우에, 법원은 상속재산관리인의 청구에 의하여 상속인이 있으면 1년 이상의 일정한 기간 내에 그 권리를 주장할 것을 공고하여야 한다(민법 제1057조). 청산결과 남은 재산이 없으면 이 공고는 할 필요가 없으며, 이 공고에서 정한 기간이 경과하여도 상속인이 나타나지 않으면 상속인의 부존재가 확정된다.

3. 상속인의 부존재로 인한 등기

가. 의 의

가정법원에 의한 상속인 수색공고의 공고기간 내에 상속권을 주장하는 자가 없고 상속인 수색의 공고기간이 경과된 후 2월이 지나도 특별연고자가 상속재산분여의 청구를 하지 않는 경우 및 재산분여의 청구에 대해 각하 또는 일부분여가 있는 후 남은 상속재산이 있으면 이는 국가에 귀속한다.

다만 민법 제267조의 “공유자가 그 지분을 포기하거나 상속인 없이 사망한 때에는 그 지분은 다른 공유자에게 각 지분의 비율로 귀속

한다.”는 규정에 따라 피상속인이 다른 사람과 공유관계로 소유하는 재산에 대한 지분은 나머지 공유자에게 귀속한다.

나. 상속인 부존재로 인한 소유권이전등기절차

상속인 부존재로 확정된 부동산이 공유관계인 경우에는 공유자 중 1인의 상속재산은 다른 공유자에게 귀속되므로, 다른 공유자는 상속인 부존재로 인한 소유권이전등기를 신청할 수 있다.

공유자 중 1인의 상속인 부존재로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우 등기원인은 “상속인부존재 확정”, 등기원인일자는 “상속인 수색공고의 공고기간의 다음 날”을 신청정보로 제공하여야 한다. 또한, 상속인 부존재의 경우 상속재산의 관리를 위한 상속재산관리인이 선임되므로 상속재산관리인에 관한 정보도 신청정보로 제공하여야 한다.

등기를 신청하는 경우 규칙 제46조의 일반적인 첨부정보 외에 상속인 부존재가 확정되었음을 증명하는 정보와 상속재산관리인선임심판서를 첨부정보로 제공하여야 한다. 이 경우 법원의 무후의 기재 허가에 의하여 말소된 제적등본만으로는 재산상속인이 없다는 공적 증명이 될 수 없고, 민법 제1053조, 제1057조 등의 규정에 의한 절차를 거쳐 재산상속인이 없음이 확정된 후에야 망 공유자의 상속재산관리인은 다른 공유자와 공동으로 지분이전등기의 방식에 의하여 공유지분귀속등기신청을 할 수 있을 것이다(선례 2-340).

공유자 중 1인의 상속인 부존재로 인한 소유권이전등기의 기록례는 다음과 같다.

【갑 구】 (소유권에 관한 사항)				
순위 번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
1	소유권보존	2005년 3월 5일 제3500호		공유자 지분 2분의 1 이일남 451220-1829716 서울특별시 중구 회현동 6 지분 2분의 1 이도령 50124-1056407 서울특별시 중구 회현동 7
2	소유권이전	2008년 5월 4일 제6500호	2010년 4월 5일 상속인부존재 확정	소유자 이도령 50124-1056407 서울특별시 중구 회현동 7

4. 특별연고자에 대한 재산분여

가. 의 의

특별연고자에 대한 상속재산의 분여란 상속인이 존재하지 않는 경우에, 사실혼배우자나 사실상의 양자와 같이 피상속인과 생계를 같이 하거나 피상속인의 요양간호를 한 자 기타 피상속인과 특별한 연고가 있는 자에 대하여 법률상 상속인이 아닌 경우에도 일정한 상속재산을 나누어 주는 제도를 말한다(민법 제1057조의2).

이 제도는 1990년 민법개정으로 도입된 것으로, 법률상 상속인이 아닌 특별연고자를 보호할 필요성과 국가에 귀속되는 상속재산의 관리 등의 번거로움 등 이해관계를 조절하기 위하여 신설한 것이다. 특별연고자가 재산분여를 받는 지위는 일종의 기대권으로 보는 것이 일반적이다.

나. 재산분여의 요건

(1) 특별연고관계

(가) 피상속인과 생계를 같이 하고 있던 자

여기에는 사실상의 배우자, 사실상의 양친 또는 양자, 인지되지 않은 혼외자, 계모자 등과 같이 피상속인과 가족적 공동생활을 누리는 자가 이에 해당한다. 이에 대해서는 추상적인 친족관계의 층수에 의해 판단할 것이 아니라 실질적·구체적으로 판단하여야 할 것이다.

(나) 피상속인을 요양·간호한 자

상속인이 아닌 친족, 가까운 지인, 이웃 등 피상속인과 생계를 같이 하지는 않았지만, 피상속인을 돌보고 그 요양이나 간호에 특별히 애쓴 자가 이에 해당한다. 요양이나 간호의 동기는 묻지 아니한다.

(다) 기타 상속인과 특별한 연고가 있던 자

이에 해당하는지는 법원이 구체적인 사정을 고려하여 실질적으로 판단할 문제인바, 정신적·물질적으로 밀접한 관계에 있던 자로 상속재산을 그에게 분여하는 것이 피상속인의 의사에 맞는 것으로 볼 수 있을 정도로 특별한 관계에 있던 자를 말한다. 만약 이러한 특별연고가 있다면 법인이나 법인 아닌 사단도 분여를 받을 수 있고, 과거에 특별한 연고가 있었더라도 특별연고자로 될 수 있다고 할 것이다.

(2) 재산분여의 청구에 상당성이 있을 것

청구자인 특별연고자의 청구가 있더라도 법원이 그의 청구가 상

당하다고 인정되는 경우에 재산분여심판을 하게 된다. 상당성 여부는 법원이 재량으로 판단할 문제인바, 연고관계의 내용이나 친밀도, 나이, 성별, 직업, 상속재산의 종류 등 일체의 구체적 사정이 고려될 수 있을 것이다.

다. 재산분여의 효과

재산분여의 청구가 인용되면 그 심판에 따라 청구인에게 청산 후 남아 있는 상속재산의 전부 또는 일부가 분여된다. 그러나 특별연고자는 상속인이 아니므로 상속채무 등의 의무는 승계되지 않는다. 또한, 특별연고자는 분여받은 재산을 원시취득하기 때문에 상속채권자나 수증자는 특별연고자에 대하여 변제청구를 할 수 없다.

라. 특별연고자에 대한 분여로 인한 이전등기절차

특별연고자가 재산분여 심판청구를 하여 법원이 재산분여심판을 한 경우에는 그 심판에 따라 청구인에게 상속재산의 전부 또는 일부가 분여되므로 특별연고자는 재산분여에 관한 등기신청을 해야 한다.

특별연고자에 대한 분여 등기를 신청하는 경우에 규칙 제43조의 일반적인 신청정보 외에 등기원인은 “민법 제1057조의2의 규정에 의한 심판”, 등기원일자는 가정법원의 심판확정일을 신청정보로 제공하여야 한다. 또한, 상속재산의 관리를 위한 상속재산관리인이 선임되므로 특별연고자에 대한 분여 등기신청 시 상속재산관리인에 관한 정보도 제공하여야 한다.

등기를 신청하는 경우에 상속인의 부존재를 증명하는 정보로서 상속을 증명하는 정보를 제공하여야 하고, 상속재산관리인선임심판

서와 특별연고자에 대한 분여가 있었음을 증명하는 것으로 확정심판 등본을 첨부정보로 제공하여야 한다.

특별연고자에 대한 분여 등기의 기록례는 다음과 같다.

[갑 구] (소유권에 관한 사항)				
순위 번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
3	소유권이전	2010년 5월 4일 제3500호	2010년 4월 5일 민법 제1057조 의2의 규정에 의한 심판	소유자 이도령 50124-1056407 서울특별시 중구 회현동 7

제 6 절 | 상속재산의 국가귀속

1. 의 의

상속권을 주장하는 자가 없고 상속채권자와 수증자에 대한 청산 절차가 종료하고 난 후, 특별연고자가 없거나 재산분여를 하였더라도 그 후 남는 재산이 있는 경우에는 그 나머지의 상속재산은 국가에 귀속된다(민법 제1058조제1항). 이 경우 관리인은 지체 없이 관리의 계산을 하여야 한다(민법 제1058조제2항, 제1055조제2항).

국가는 이때 상속인으로서 재산을 승계하는 것이 아니라, 법률의 규정에 따른 원시취득을 하는 것이다. 국가는 적극재산만을 취득하며 채무는 부담하지 않는다. 적극재산이라도 특허권이나 저작권과 같은 무체재산권은 상속인이 없이 사망하면 소멸하므로 국가에 귀속하지 않는다(특허법 제124조, 저작권법 제6조).

무주의 부동산을 국유재산으로 취득하기 위한 규정인 국유재산법 제12조제3항에서는 6월 이상의 공고기간 내에 이의가 없는 경우에 한하여 지적법(현행 측량·수로조사 및 지적에 관한 법률)에 의한 소관청에 소유자등록을 신청할 수 있다고 한 점에 비추어 이 규정은 등기되어 있지 아니한 무주의 부동산에 대한 국유재산 취득에 관한 것으로 보아야 할 것이고, 등기되어 있는 부동산에 대하여는 이 규정을 적용하기는 어려울 것으로 보이므로 이 경우에는 소유명의인의 생사여부 및 그의 상속인의 존부를 확인하여 민법 제1053조부터 제1058조에서 규정한 절차에 의하여 국가에 귀속시켜야 될 것이다(선례 4-651).

2. 국가귀속의 시기

상속재산이 국가에 귀속하는 시점에 대해서는 민법 제1059조 규정에 비추어 상속재산관리인이 잔여재산을 국가에 인계하는 때로 보자는 견해도 있으나, 상속이 개시된 때에 국가에 귀속되는 것으로 보는 것이 타당할 것이다. 한편 잔여 상속재산이 국가에 귀속된 후에는 변제받지 못한 상속채권자 또는 유증받은 자는 국가에 대하여 그 변제를 청구하지 못한다(민법 제1059조).

3. 상속재산의 국가귀속으로 인한 이전등기절차

상속재산의 국가귀속으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우 등기원인은 “권리귀속”, 등기원인일자 “전 소유자의 사망일자”를 신청정보로 제공하여야 한다. 또한, 상속인 부존재로 인한 등기신청이므로 등기신청 시 상속재산관리인에 대한 정보도 제공하여야 할

것이다.

등기를 신청하는 경우에 상속인의 부존재를 증명하는 정보로서 상속을 증명하는 정보를 제공하여야 하고, 상속재산관리인선임심판서와 상속인 수색공고로 상속인 부존재가 확정되었음을 증명하는 정보를 첨부정보로 제공하여야 한다.

상속재산의 국가귀속으로 인한 소유권이전등기 기록례는 다음과 같다.

【갑 구】 (소유권에 관한 사항)				
순위 번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
3	소유권이전	2010년 5월 4일 제3500호	2008년 4월 5일 권리귀속	소유자 국 관리청 지식경제부 221

제 7 절 | 제사용 재산의 승계에 의한 등기

1. 제사용 재산의 승계

분묘에 속한 1정보(3000평) 이내의 금양임야와 600평 이내의 묘토인 농지, 족보와 제구의 소유권은 상속재산과 구별하여 제사를 주재하는 자가 이를 승계한다(민법 제1008조의3). 제사용 재산과 제사주재자에 대해서는 제4장을 참고하기로 한다.

2. 제사용 재산에 대한 소유권이전등기

가. 의 의

제사용 재산의 소유자가 사망한 경우에 그의 권리는 상속의 법리에 의하지 않고 민법 제1008조의3에 의하여 제사를 주재하는 자가 승계하게 되므로, 분묘에 속한 1정보 이내의 금양임야와 600평 이내의 묘토인 농지에 대한 소유권이전등기는 상속에 준하여 처리해야 하는지 아니면 유증에 준하여야 하는지가 문제 된다.

등기실무는 “상속개시 당시에 이미 묘토로서 사용되고 있는 농지라면 제사를 주재하는 자가 승계하게 되며, 승계로 인한 소유권이전등기를 신청하기 위하여는 상속을 증명하는 서면과 당해 토지가 묘토인 농지이고 등기신청인이 제사를 주재하는 자임을 상속인 전원이 인정하는 서면(이 서면에는 신청인을 제외한 상속인 전원의 인감증명을 첨부하여야 함)을 첨부하여야 할 것이다.”라고 하여 상속에 준하여 처리하고 있다(선례 5-282).

제사용 재산의 권리승계자인 제사주재자는 승계의 의사표시를 할 필요나 대항요건을 갖출 필요도 없이 법률상 당연히 승계되고, 이를 포기하거나 사퇴할 수도 없다는 점에서 제사용 재산에 대한 소유권이전은 상속에 의한 등기절차에 의하여야 할 것이다.

나. 제사용 재산에 대한 이전등기절차

제사용 재산에 대해 등기신청을 하는 경우에 등기원인으로는 “민법 제1008조의3의 규정에 따른 승계”로, 등기원인일자는 “피상속인의 사망일자”를 신청정보로 제공하여야 한다.

제사용 재산에 대해 등기신청을 하는 경우에는 상속을 증명하는 서면, 당해 부동산이 묘토인 농지임을 증명하는 서면 및 등기신청인이 제사를 주재하는 자임을 상속인 전원이 인정하는 서면을 첨부정

보로 제공하여야 한다(선례 3-408, 4-59). 다만 도시계획확인원(용도가 개발제한 구역)은 금양임야임을 증명하는 서면이 될 수 없다(선례 3-391). 600평 이내의 묘토인 농지에 대한 소유권은 제사를 주재하는 상속인(제사주재자가 상속인이 아닌 경우에는 법정상속인)이 승계하게 되는 바, 이는 본질적으로 상속에 속하는 것이므로 위 농지에 대하여 소유권이전등기를 신청하는 경우 농지취득자격증명을 첨부할 필요가 없다(선례 200906-1).

제사용 재산의 승계에 따른 등기기록례는 다음과 같다.

【갑 구】 (소유권에 관한 사항)				
순위 번호	등기목적	접수	등기원인	권리자 및 기타사항
3	소유권이전	2010년 5월 4일 제3500호	2010년 4월 1일 민법 제1008조 의3의 규정에 의한 승계	소유자 이도령 50124-1056407 서울특별시중구 회현동 7

제8장 상속인에 의한 등기

제1절 총설

1. 의의

상속인에 의한 등기신청이란 등기원인은 피상속인 생존 당시에 이미 존재하고 있으나, 아직 등기신청을 하지 않고 있는 동안에 등기권리자 또는 등기의무자에 대하여 상속이 개시되어 상속인이 그 등기원인에 의한 등기신청을 하는 것을 말한다. 즉 등기원인이 발생한 후 상속이 개시된 경우에는 실체법상의 등기권리자 또는 등기의무자의 지위는 상속인에 의하여 포괄승계되므로 그 상속인은 피상속인이 생존해 있었다면 그가 신청하였을 등기신청을 할 수 있다.

예를 들어 갑 소유의 부동산에 관하여 갑과 을이 매매계약을 체결한 후 아직 소유권이전등기신청을 하지 않고 있는 동안에 매도인인 갑 또는 매수인 을이 사망하였다면, 그 매매를 원인으로 하는 소유권이전등기신청은 갑의 상속인 또는 을의 상속인이 다른 상대방과 공동으로 할 수 있다.

현행 부동산등기법은 제27조에서 이러한 상속인에 의한 등기신청에 관하여 규정하고 있으며, 판례도 “등기원인이 이미 존재하고 있으나 아직 등기신청을 하지 않고 있는 동안에 등기권리자 또는 등기의무자에 관하여 상속이 개시된 경우 피상속인이 살아 있다면 그가 신청하였을 등기를 상속인이 부동산등기법 제47조(현행 부동산등기법 제27조)의 규정에 따라 신청하는 때에는 그 등기를 무효라고 할

수 없다.”고 하여 그 유효성을 인정하고 있다(대법원 1997. 11. 28. 선고 95다51991 판결).

등기원인이 발생한 후에 상속 이외의 다른 사유로 등기당사자에게 포괄승계가 발생한 경우에도 상속과 마찬가지로 그 승계인이 등기신청을 한다. 구법에서는 상속 이외의 사유에 의해 포괄승계가 발생한 경우에는 규정이 없어 회사의 합병 등에 의한 경우에는 구법 제47조를 유추적용하였다. 반면 개정법 제27조에서는 상속 이외의 포괄승계가 있는 경우에 그 밖의 포괄승계인이 그 등기를 신청할 수 있도록 명문으로 규정하고 있다.

2. 민법 제187조와의 관계

법률행위에 의한 부동산물권의 변동에 대하여는 민법 제186조가 적용되며, 법률행위와 등기가 있어야 물권변동이 일어난다. 이와는 달리 등기를 필요로 하지 아니하는 부동산물권변동이 있는바, 이는 민법 제187조에서 규정하고 있다. 민법 제187조는 당사자의 의사에 의하여 효력이 생기지 않는 경우를 총칭하는 것으로, 등기 없이도 완전한 물권변동이 일어난다. 다만 제187조에 의하여 취득한 부동산물건의 처분에는 등기가 있어야 한다(민법 제187조 단서).

상속은 민법 제187조가 적용되는 전형적인 경우로서 상속은 피상속인의 사망으로 개시되어 상속인에게 상속된다. 따라서 상속의 경우에도 상속이 개시된 후 상속재산을 처분하기 위해서는 상속등기를 하여야 한다.

상속인에 의한 등기신청(법 제27조)은 민법 제187조와는 반대로 피상속인의 처분행위, 즉 원인행위가 있는 후 상속이 개시된 경우로

서 상속등기를 예외적으로 생략할 수 있는 특례를 규정한 것으로 볼 수 있다.

등기신청서에 기재된 등기의무자의 표시가 등기기록상의 등기명 의인의 표시와 부합하지 않은 경우에는 그 등기신청을 각하하여야 하는데(법 제29조제7호), 상속인에 의한 등기신청은 그 예외라고 할 수 있다.

3. 상속등기와의 구별

① 상속등기는 상속을 그 등기원인으로 하나, 상속인에 의한 신청은 상속 이외의 특정한 원인행위(예를 들어 매매, 증여 등)를 등기원인으로 한다. 또한, 상속등기는 등기관리자가 단독으로 등기신청을 하여야 하나(법 제23조제3항), 상속인에 의한 신청은 이러한 예외 규정이 없으므로 공동신청을 원칙으로 한다.

② 상속등기의 경우에는 등기원인을 증명하는 정보로 상속을 증명하는 서면(제적등본, 가족관계증명서 등)을 첨부하여야 하나, 상속인에 의한 등기신청은 피상속인과 상대방 사이에 있었던 상속 이외의 등기원인을 증명하는 정보를 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다.

③ 상속등기 신청의 경우에는 등기필정보를 신청정보로 제공할 필요가 없으나, 상속인에 의한 등기신청은 등기필정보를 신청정보로 제공하여야 한다.

제 2 절 | 등기신청의 적용 요건

1. 피상속인 생존에 등기원인이 존재할 것

상속인에 의한 등기신청의 경우에는 등기원인이 피상속인의 생존에 발생한 것이어야 한다. 즉 피상속인이 생존 당시에 상대방과 사이에 권리변동의 원인이 되는 법률행위 등을 하였어야 한다. 이러한 등기원인에는 당사자의 의사표시를 요건으로 하는 법률행위뿐만 아니라 시효취득 같은 법률사실도 포함될 수 있으며, 법률행위에는 채권행위뿐만 아니라 물권의 포기나 같은 물권행위도 포함된다.

피상속인에 의한 등기신청은 그 등기원인이 소유권이전등기를 전제로 한 것만이 아니고, 제한물권의 설정 등에도 적용된다. 또한, 미등기부동산에 대하여 피상속인 생존 시에 등기원인이 되는 법률사실이 존재하는 경우에는 상속인이 상속을 증명하는 서면을 첨부하여 상속인 명의로 소유권보존등기를 신청할 수 있다(선례 1-274).

피상속인의 생존 당시에 시효취득이 완성되고 시효완성일 이후에 피상속인이 사망하여 갑이 피상속인과 그 상속인을 상대로 취득시효완성을 원인으로 한 소유권이전등기절차 이행을 명하는 확정판결을 받았다면, 갑은 상속등기를 선행할 필요 없이 피상속인 명의에서 바로 자기 명의로 소유권이전등기를 경로받을 수 있다(선례 5-378). 이와는 달리 등기부상 소유 명의인인 갑의 상속인들을 상대로 을이 취득시효 완성을 원인으로 한 소유권이전등기절차 이행의 승소판결을 받았는데 그 취득시효 완성일이 갑의 사망일 이후라면, 을은 갑 명의의 부동산에 대하여 갑의 상속인인 피고들 앞으로 상속으로 인한 소유권이전등기를 마친 후에 을 앞으로 취득시효 완성을 원인으로 한 소유권이전등기를 할 수 있다(선례 4-408). 즉 취득시효 완성이라는 등기원인이 피상속인 사망 전에 발생한 경우에는 상속

등기를 할 필요 없이 피상속인으로부터 등기권리자(승소 원고) 명의로 바로 소유권이전등기를 할 수 있고, 만약 피상속인 사망 후에 취득시효가 완성된 경우에는 먼저 상속인 앞으로 상속으로 인한 소유권이전등기를 마친 후에 취득시효를 원인으로 한 소유권이전등기를 하여야 한다.

2. 등기원인이 있는 후 상속이 개시될 것

법 제27조가 적용되기 위해서는 피상속인의 생존 당시에 등기원인이 있는 후 상속이 개시되어야 한다. 이때의 상속은 등기권리자 또는 등기의무자에 관하여 상속이 개시된 경우뿐만 아니라 양자 모두에 상속이 개시된 경우도 포함된다.

등기원인이 피상속인의 사망 이후에 발생한 경우에는, 그 등기원인에 의한 등기신청은 피상속인으로부터 상속인 앞으로 상속등기를 마친 후에 하여야 한다.

제 3 절 | 등기신청인

1. 공동신청

상속인에 의한 등기는 상속인이 상속을 증명하는 정보를 첨부하여 거래 상대방과 공동으로 신청하게 된다. 예를 들어 갑이 을에게 자기 부동산을 매도하였으나 소유권이전등기 전에 갑이 사망한 경우 갑의 상속인 A가 등기의무자로서 등기신청을 하게 되고, 을이 사망한 때에는 을의 상속인 B가 등기권리자로서 등기신청을 하게 된

다. 즉 A와 을, 갑과 B 또는 A와 B의 공동신청에 의해 등기신청을 할 수 있다.

등기권리자나 등기의무자인 상속인이 여러 명인 경우에는 원칙적으로 공동상속인 전부가 등기권리자나 등기의무자로서 등기신청을 하여야 한다. 다만 등기의무자나 등기권리자인 공동상속인들 사이에 협의분할계약이 이루어진 경우에는 단독으로 상속받은 사람만이 등기의무자 또는 등기권리자가 될 수 있다(선례 5-206, 7-179).

상법상 합병으로 회사 간에 합병이 이루어진 경우 존속한 회사는 합병으로 인하여 소멸한 회사의 권리의무를 포괄승계하는 점에 있어서는 상속인의 권리의무를 포괄승계하는 것과 같으므로, 합병으로 소멸한 회사가 합병 전에 매수한 부동산에 대하여는 합병 후 존속하는 회사와 매도인의 공동신청으로 직접 존속하는 회사 명의로 소유권이 전등기를 신청할 수 있다(선례 4-374).

2. 단독신청

상속인에 의한 등기신청도 공동신청이 원칙이나, 상대방이 등기신청에 협력하지 않는 경우에는 판결을 받아 단독으로 신청할 수 있다. 즉 상속인이 등기신청에 협력하지 않는 경우에는 그 상속인 전원에게 등기신청자격이 있으므로 상속인 전원을 피고로 하여 판결을 받아야 한다.

따라서 상속인 전원을 피고로 하지 않고 그 중 일부만을 상대로 하여 판결을 받은 경우에는 그 판결에 따른 등기신청을 할 수 없다. 즉 피상속인 소유 부동산을 그 생존 시에 매매가 이루어지고 소유권이전등기가

완료되기 전에 상속이 개시된 경우, 그 후 상속인 3인 중 2인만을 상대로 그들의 상속지분 만에 관하여 이전등기를 명하는 판결을 받은 경우에는 그 판결만으로는 피상속인 명의로부터 원고 명의로 이전등기를 직접 신청할 수 없다(선례 1-194).

제 4 절 | 등기신청절차

1. 신청정보

상속인에 의한 등기신청을 하는 경우에는 규칙 제43조에 규정된 일반적 사항을 신청정보로서 등기소에 제공하면 될 것이다. 즉 등기 원인으로는 상속 이외의 사유(예를 들어 매매, 증여, 취득시효 등)를 적고, 그 원인일자를 기재하면 된다.

등기필정보에 대해서는 피상속인이 부동산에 관한 권리를 취득한 당시에 등기소로부터 교부받은 등기필정보를 신청정보로서 등기소에 제공하여야 한다.

2. 첨부정보

가. 일반적인 첨부정보

① 상속인에 의한 등기신청은 일방 또는 쌍방에 상속이 개입되어 상속등기를 생략한다는 점을 제외하고는 일반적인 등기신청절차와 같다. 따라서 첨부정보에 대해서도 그 등기원인을 증명하는 정보를 그 신청정보와 함께 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다. 매매

또는 증여에 의한 소유권이전등기의 경우에는 매매계약서 또는 증여계약서를 제공하면 되고, 기타 설정 등의 경우에는 그에 맞는 등기원인을 증명하는 정보를 제공하면 될 것이다.

② 등기원인을 증명하는 정보는 피상속인과 상대방 사이에서 작성된 것이어야 하고, 상속인 명의로 작성된 것은 등기원인을 증명하는 정보가 될 수 없다(선례 1-67).

③ 첨부정보로 제공하는 구 등기필증에 대해서는 피상속인이 부동산에 관한 권리를 취득한 당시에 등기소로부터 교부받은 등기필증을 제공하여야 한다(법 부칙 제2조).

④ 등기의무자의 인감증명이 필요한 등기신청의 경우에는 피상속인의 인감증명이 아닌 등기의무자가 된 상속인 모두의 인감증명을 첨부정보로 제공하여야 한다.

⑤ 피상속인으로부터 부동산을 매수한 자가 그 상속인과 공동으로 (또는 상속인을 상대로 하여 소유권이전등기의 승소판결을 받아) 법 제 27조에 의하여 상속등기를 거침이 없이 상속인에 의한 등기신청을 하는 경우에 등기기록상 주소와 제적등·초본상 주소가 다른 경우에는 피상속인의 주소를 증명하는 정보로 말소자등·초본을 제출하여야 한다. 하지만 등기의무자의 상속인을 상대로 소유권이전등기의 승소판결을 받아 소유권이전등기를 신청하는 경우에도 상속인의 주소를 증명하는 정보는 제공할 필요가 없지만, 제적등본 등 상속인임을 증명하는 서면은 제출하여야 한다(선례 3-307).

⑥ 상속에 의하여 농지를 취득한 경우에는 농지취득자격증명을 제공할 필요가 없으나, 상속인이 피상속인의 매수인 지위를 승계하는 상속인에 의한 등기신청의 경우에는 농지취득자격증명을 제공하여야 한다. 예를 들어 피상속인이 매수한 농지에 대하여 공동상속인

들이 매도인과 공동으로(또는 그를 상대로 소유권이전등기 승소의 확정판결을 받아) 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 등기권리자인 공동상속인 명의의 농지취득자격증명을 제공하여야 한다(선례 3-837, 5-714).

나. 상속을 증명하는 정보

상속인에 의한 등기신청은 상속 이외의 원인으로 등기원인으로 하지만 실질적으로는 상속이 전제되기 때문에 상속을 증명하는 정보를 첨부정보로서 제공하여야 한다. 예를 들어 부동산 매수인의 상속인들이 매도인을 상대로 소유권이전등기 승소 확정판결을 받아 소유권이전등기를 신청하는 때에는 상속을 증명하는 정보를 제공하여야 한다(선례 5-128). 증여자의 상속인을 상대로 하여 소유권이전등기 승소 확정판결을 받아 소유권이전등기를 신청하는 때에도 이와 같다(선례 3-307). 상속을 증명하는 정보에 대해서는 앞에서 설명한 것을 참고하기로 한다.

제 5 절 | 등기의 실행

법 제27조의 상속인에 의한 등기는 상속인이 상속을 증명하는 정보를 첨부하여 상속 이외의 원인을 등기원인으로 하여 등기를 신청하여야 하므로, 등기관은 상속 이외의 원인을 등기원인으로 기록하여야 한다.

앞에서 설명한 바와 같이 상속인에 의한 등기신청은 등기의무자에게 상속이 발생한 경우에는 등기기록의 등기명의인(피상속인)과

등기신청인(상속인)이 불일치하는 경우가 발생한다. 이러한 경우를 예상하여 법 제29조제7호 단서에서 제27조에 따라 포괄승계인이 등기신청을 하는 경우에는 각하할 수 없음을 규정하고 있으므로, 등기관은 해당 등기신청을 각하해서는 안 되고 수리하여야 한다.

제9장 유언 및 유증으로 인한 소유권이전등기

제 1 절 | 총 설

유언제도는 상속제도와 마찬가지로 재산제도와 밀접한 관계를 가지고 있다. 즉 사유재산제도하에서는 재산의 소유자가 자기 재산에 대하여 생전뿐만 아니라 사후에 있어서도 자유로이 처분할 수 있으며, 양 제도는 사후처분과 밀접한 관련이 있다. 재산의 사후처분방법으로는 자신의 의사표시에 의한 것과 의사표시와 관계없이 이루어지는 것이 있다. 유언제도는 전자에 속하며, 상속제도는 주로 후자에 속한다고 볼 수 있다.

유언제도가 상속제도 중에서 차지하는 비중은 동양보다 서양에서 더 비중이 크다고 할 수 있다. 영국법의 경우 유언상속을 원칙으로 하여 피상속인의 유언에 의하여 재산을 자유로이 처분할 수 있으며, 법정상속은 유언이 없는 경우라든지 유언이 무효인 경우에 한정되고 있다.

우리나라의 경우 조선시대의 경국대전에도 부모의 자필유서는 효력이 있는 것으로 인정하고 있었으나, 실제로는 유언에 의한 불공평한 분배가 부모의 사후에 상속인 간 분쟁의 소지가 있음을 이유로 유언의 자유를 부정하고 법정상속에 의하려는 경향이 있었다. 하지만 최근 들어 재산의 소유자가 그 재산처분에 관하여 법정상속과 같은 소극적 의사로부터 적극적인 의사표시로 이행됨에 따라 유언에 의한 재산처분이 점차 증가되고 있다.

따라서 유증에 의한 소유권이전등기를 살펴보기 위해서는 그 전

제로서 유언에 대한 일반적인 고찰과 유언에 의한 재산처분행위로서 유증에 대해서 상세히 살펴볼 필요가 있다.

제 2 절 | 유언 일반론

1. 유언의 의의 및 성질

가. 유언의 의의

유언이란 유언자가 자기의 사망과 동시에 일정한 법률효과를 발생시킬 목적으로 일정한 방식에 따라 행하는 상대방 없는 단독행위를 말한다. 유언의 대상은 주로 상속재산의 승계에 관한 것이고, 특히 포괄유증은 실질적으로 상속인의 지정에 해당한다고 볼 수 있으므로, 유언제도는 상속법과 밀접한 관련이 있다. 유언의 효력은 유언자의 사후에 발생하지만, 유언이 법률행위로서 성립하는 것은 일반 단독행위와 마찬가지로 그 표시행위가 완료되었을 때이다.

나. 유언의 법적 성질

(1) 요식행위

유언을 불요식행위로 하게 되면 피상속인의 최종적인 진의를 확인할 수 없거나 왜곡될 우려가 있다. 유언의 요식성(민법 제1060조)은 이러한 난점을 방지하기 위한 것으로 유언자로 하여금 신중하게 의사표시를 하게 하고, 타인의 위조·변조를 막는 것을 목적으로 한다. 요식성에 위반하는 유언은 무효가 된다.

(2) 상대방 없는 단독행위

유언은 상대방 없는 단독행위이므로 유증을 받을 자의 승낙은 물론 유증을 받을 자에 대하여 의사표시를 할 필요가 없다. 따라서 유증을 받을 자는 유언의 효력이 발생한 후 그 효력이 귀속되는 것을 거절할 수 있다(민법 제1074조). 이처럼 유언은 상대방이 없는 단독행위인 점에서 계약인 사인증여와 다르다.

(3) 대리유언의 불가

유언은 반드시 본인의 독립된 의사에 의하여 이루어져야 하는 일신전속적 행위이므로 대리인에 의한 대리가 허용되지 않는다. 따라서 무능력자라 할지라도 법정대리인의 동의는 필요 없다.

(4) 유언철회의 자유

유언자는 언제든지 유언을 자유롭게 철회할 수 있다(민법 제1108조부터 제1111조까지). 유언철회의 자유를 보장하는 것은 유언자의 최종의사를 존중하기 위해서 필요하다.

(5) 사후행위

유언은 사망으로 인하여 효력이 발생하는 사후행위이다. 유언에 의하여 이익을 받는 자는 유언의 효력이 발생하기까지는 아무런 법률상의 권리(조건부 권리)도 취득하지 못한다. 따라서 유언자가 유증의 목적인 부동산을 유증받을 자 이외의 사람에게 매각하거나 저당권을 설정한 경우, 유증받을 자가 매매나 저당권설정에 관하여 무효확인이나 등기말소청구의 소를 제기하더라도 이는 인정되지 않는다.

(6) 유언사항 법정주의

유언은 법정사항에 한하여 할 수 있는 행위이다. 따라서 도덕적 의미가 있는 유혼 같은 것은 민법상의 유언이 아니다. 민법이 인정하는 유언사항은 재단법인의 설립(민법 제47조제2항), 친생부인(민법 제850조), 인지(민법 제859조제2항), 후견인 지정(민법 제931조), 상속재산분할방법의 지정 또는 위탁(민법 제1012조 전단), 상속재산 분할금지(민법 제1012조 후단), 유언집행자의 지정 또는 위탁(민법 제1093조), 유증(민법 제1074조) 등이다.

다. 유언능력

(1) 유언능력자

유언도 일종의 의사표시이므로 의사능력이 없는 자가 한 유언은 설사 형식을 갖추고 있더라도 무효이다. 유언을 하기 위해서는 유언 당시 최소한 의사능력이 있어야 하며, 민법은 유언적령을 만 17세로 정하고 있다(민법 제1061조). 따라서 만 17세가 된 자는 한정치산자, 금치산자라고 하더라도 유언 당시 의사능력이 있으면 유효하게 유언할 수 있다.

(2) 유언능력의 존재시기

유언능력이 필요한 시기에 대해서는 민법이 규정하는 바가 없으나, 유언 당시에 의사능력이 있으면 충분하고 그 후 유언능력을 상실하더라도 이미 한 유언의 효력에는 영향이 없다.

2. 유언의 방식

가. 서 설

(1) 유언의 요식성

민법 제1060조는 “유언은 본법의 정한 방식에 의하지 아니하면 효력이 생하지 아니한다.”라고 하여 유언에 대하여는 일정한 방식에 의하도록 요식성을 엄격히 요구하고 있다. 이는 유언의 효력이 유언자의 사후에 발생하기 때문에 유언자의 진의를 정확하게 하기 위함이다. 따라서 이러한 방식에 위반하는 유언은 무효로 한다.

(2) 유언의 방식

민법이 인정하는 유언방식에는 다섯 가지가 있다(민법 제1065조). 즉 보통의 경우에는 자필증서, 녹음, 공정증서, 비밀증서 중에서 어느 하나의 형식을 밟아서 유언서를 작성하여야 한다. 이러한 보통방식에 의할 수 없는 경우, 즉 질병 기타의 급박한 사유로 인하여 위의 4가지 방식에 의할 수 없는 경우에는 간이한 방식에 의한 유언인 구수증서에 의한 유언을 할 수 있도록 하고 있다.

유언자는 보통의 경우 위 방식 중 어느 것이든지 자유롭게 선택할 수 있다. 그러나 구수증서에 의한 유언은 보통방식의 유언이 불가능한 경우에만 보충적으로 할 수 있다.

(3) 유언 증인의 결정

(가) 법정결격사유

자필증서에 의한 유언을 제외하고는 녹음에 의한 유언, 공정증서에 의한 유언, 비밀증서에 의한 유언, 구수증서에 의한 유언에 의한 경우 모두 증인의 참여가 필요하다. 증인은 유언성립의 진정성과 방식준수의 확실성을 증명하는 자이며, 이러한 사람의 서명 또는 기명

날인 혹은 구술(녹음에 의한 유언)은 직접적으로 유언의 유효·무효를 판단하는 자료가 될 것이다. 따라서 민법은 제1072조에서 결격자에 관하여 규정하고 있다.

① 미성년자: 미성년자는 법정대리인의 동의를 얻더라도 증인이 될 수 없는 절대적 결격자이다.

② 금치산자와 한정치산자: 금치산자는 의사능력을 회복하고 있을 때에도 증인이 될 수 없다. 한정치산자는 법정대리인의 동의를 얻은 경우라도 증인이 될 수 없다. 이들 또한 절대적 결격자이다.

③ 유언에 의하여 이익을 받을 자, 그 배우자와 직계혈족: 이러한 사람들은 유언에 의하여 이익을 얻을 자들로, 증인이 되는 것을 허용하면 자기의 이익을 꾀할 우려가 있으므로, 증인이 될 자격에서 배제한 것이다. 따라서 후순위상속인, 유언으로 이익을 잃게 될 사람, 유언집행자 등은 증인결격자가 아니므로 증인이 될 수 있다(대법원 1999. 11. 26. 선고 97다57733 판결).

④ 공정증서에 의한 유언의 경우에는 공증인법에 의한 결격자: 공증인법에 규정한 결격자는 미성년자, 시각장애인이거나 문자를 해독하지 못하는 사람, 서명할 수 없는 사람, 촉탁사항에 관하여 이해관계가 있는 사람, 촉탁사항에 관하여 대리인 또는 보조인이나 대리인 또는 보조인이었던 사람, 공증인의 친족이나 피고용인 또는 동거인, 공증인의 보조자가 있다(공증인법 제33조제3항).

(나) 사실상의 결격사유

법률규정에는 결격사유로 되어 있지 않지만, 사실상 유언의 방식에서 정한 행위를 할 수 없어 결격이 된 자들이 있다.

① 서명할 수 없는 자: 유언에 의한 증인은 녹음에 의한 경우를

제외하고는 서명 또는 기명날인이 필요한데, 서명이 필요한 유언의 경우 서명을 할 수 없는 자는 사실상 증인이 될 수 없다.

② 유언자의 구수를 이해할 수 없는 자: 구수증서의 경우에는 증인이 유언자의 구수를 필기·낭독하여야 하므로, 구수를 이해하지 못한 자는 증인이 될 수 없다. 이것은 녹음에 의한 유언의 경우에도 해당된다.

(다) 결격자가 참여한 유언의 효력

증인결격자가 유언의 증인으로서 참여한 유언은 그 유언 전체가 무효가 된다. 여러 명의 증인 중 결격자가 있는 경우 나머지 증인만으로도 법정의 증인 수에 달한 경우에 전체를 무효로 할 것인지 아니면 유효로 할 것인지가 문제가 되나, 대륙법계통은 전자로, 영미법은 후자로 해석한다.

나. 자필증서에 의한 유언

(1) 의 의

자필증서에 의한 유언이란 유언자가 유언의 전문, 작성연월일, 주소, 성명을 자필로 작성하고 날인함으로써 성립한 유언을 말한다(민법 제1066조제1항).

자필증서에 의한 유언은 유언자가 직접 유언서를 작성하면 되므로 간단하고 편리하며 비용이 거의 들지 않는 장점이 있다. 반면에 문맹자나 법률지식이 없는 자가 이용하기에는 불편한 점이 많고, 방식불비 등으로 유언서에 대해 법적 분쟁이 발생할 가능성이 크다는 단점이 있다.

(2) 요건

(가) 유언자가 전문을 자서할 것

자필증서에 의한 유언은 유언자가 자서하는 것이 절대적 요건이므로, 타인에게 구수시킨 것, 타자기나 컴퓨터를 이용한 유언은 자필증서로 인정되지 않으며, 이 경우에는 전부가 무효이다. 다만 본문 일부에 대하여 타인이 쓴 부분이 있더라도 이 부분이 부수적이거나 첨가적인 경우로 극히 사소한 부분이어서 그 부분을 제외하더라도 유언의 취지가 충분히 표현되어 있다면 유효로 보아야 할 것이다.

타인의 손에 의지하여 쓴 유언이나 어느 정도 문자를 이해하고 쓸 수 있는 자가 타인이 쓴 것을 그대로 베낀 유언은 자서로 볼 수 있다. 또한, 외국어에 의한 유언, 약자·약호를 사용한 유언, 속기문자에 의한 유언 등도 모두 유효하다.

유언의 전문이 한 장의 용지에 다 쓰여질 필요는 없으며, 용지가 여러 장인 경우에도 그것이 하나의 유언서로 확인되면 유효하다고 할 수 있다.

자필유언의 경우에는 증인이 필요하지 아니하다. 판례는 공증사무실에서 유언장에 인증을 받았으나 증인 2명의 참여가 없고, 자서된 것도 아니라면 그 유언장은 공정증서에 의한 유언도 될 수 없고, 자필증서유언도 될 수 없다고 한다(대법원 1994. 12. 22. 선고 94다13695 판결).

(나) 유언서 작성연월일을 자서할 것

자필증서에 의한 유언의 경우 유언서의 작성연월일은 반드시 기재해야 한다. 유언의 성립시기는 유언능력의 유무를 판단하는 기준

시가 될 뿐만 아니라, 내용이 서로 저촉되는 복수의 유언증서가 있는 경우에 그 우열을 결정하는 기준이 되기 때문이다. 연월일이 없는 유언은 무효이다. 판례도 “민법 제1066조제1항은 ‘자필증서에 의한 유언은 유언자가 그 전문과 연월일, 주소, 성명을 자서하고 날인하여야 한다.’고 규정하고 있으므로, 연월일의 기재가 없는 자필 유언증서는 효력이 없다. 그리고 자필유언증서의 연월일은 이를 작성한 날로서 유언능력의 유무를 판단하거나 다른 유언증서와 사이에 유언 성립의 선후를 결정하는 기준일이 되므로 그 작성일을 특정할 수 있게 기재하여야 한다. 따라서 연·월만 기재하고 일의 기재가 없는 자필유언증서는 그 작성일을 특정할 수 없으므로 효력이 없다.”라고 하여 일자가 누락된 자필유언은 무효라고 하고 있다(대법원 2009. 5. 14. 선고 2009다9768 판결).

그러나 연월일은 반드시 정확하게 기재할 필요는 없으며, 예컨대 유언서를 작성한 날이 명백하면 되는 것이므로, ‘만 70세 생일’ 이라든지 ‘조부 몇 주기일’ 등으로 기재해도 상관없다.

(다) 주소를 자서할 것

주소는 유언자의 생활 근거가 되는 곳이 되며(민법 제18조제1항), 반드시 주민등록법에 의하여 등록된 곳일 필요는 없다. 주소는 유언증서를 담은 봉투에 기재해도 무방하다(대법원 1998. 5. 29. 선고 97다38503 판결).

(라) 유언자의 성명을 자서할 것

성명의 기재는 그 유언자가 누구인가를 알 수 있는 정도이면 되며, 호나 자(字) 또는 예명 등을 기재해도 무방하다. 이름만 쓰더라도 유언서의 내용 기타에 의하여 유언자 본인의 동일성을 알 수 있는 경우

에는 성과 이름을 다 쓰지 않아도 유효라고 보아야 할 것이다.

(마) 날인할 것

날인은 반드시 본인이 해야 될 필요는 없으며, 타인이 대신해도 무방하다. 또한, 날인은 반드시 인장으로 할 필요가 없고, 무인을 찍어도 상관없다.

(3) 유언증서를 변경하는 경우

자필증서에 문자의 삽입, 삭제 또는 변경할 때에는 유언자가 이를 자서하고 날인하여야 한다(민법 제1066조제2항). 증서의 기재 자체로 보아 명백한 오기를 정정함에 지나지 않는 경우에는 그 정정 부분에 날인을 하지 않았다고 하더라도 그 효력에 영향이 없다(대법원 1998. 5. 29. 선고 97다38503 판결).

(4) 검 인

자필증서 유언자의 사망 시 상속인 등은 지체없이 가정법원에 자필유언서의 검인신청을 하여야 한다. “지체없이”는 상속인 등이 유언서를 발견한 후 “곧바로”라는 의미라고 할 것이다.

다. 녹음에 의한 유언

(1) 의 의

녹음에 의한 유언은 유언자가 직접 녹음기에 유언의 취지, 그 성명과 연월일을 구술하고 참여한 증인이 유언이 유언자의 유언임이 분명하다는 내용과 자신의 성명을 구술하여 녹음함으로써 성립하는 유언이다(민법 제1067조).

과학의 발달에 따른 문명의 이기를 사용하여 유언자의 육성을 사후에도 보존할 수 있고, 녹음기만 있으면 누구나 간편하게 할 수 있다는 장점이 있다. 반면에 녹음된 내용이 기기의 오작동으로 인해 멸실되거나, 녹음내용의 편집이나 위·변조 등이 용이하다는 단점이 있다.

(2) 요건

녹음에 의한 유언은 유언자가 유언의 취지, 그 성명과 연월일을 구술하고, 이에 참여한 증인이 유언의 정확함과 그 성명을 구술하여야 한다. 금치산자가 그 의사능력이 회복되어 녹음에 의한 유언을 할 때에는 의사가 유언자의 심신회복 상태를 확인하고 이를 구술하고 의사의 성명을 구술하는 방법으로 하여야 한다.

증인의 수에 대한 제한 규정이 없으므로 다른 유언과의 형평성을 고려하여 증인의 수는 두 명 이상이어야 한다는 견해가 있으나, 한 명 이상의 증인이 참여하여 구술하면 충분하다는 것이 다수견해이다. 따라서 증인이 없으면 그 유언은 무효이다.

라. 공정증서에 의한 유언

(1) 의 의

공정증서에 의한 유언은 유언자가 공증인의 면전에서 유언의 취지를 구술하고, 이를 공증인이 필기한 다음 유언자와 증인 앞에서 낭독하고, 유언자와 증인이 공증인의 필기가 정확함을 승인한 후 각자 서명 또는 기명날인함으로써 성립하는 유언을 말한다(민법 제1068조).

이 방식은 공증인의 면전에서 작성하는 것이기 때문에 유언서의

위조나 변조·멸실 등의 우려가 없고, 공적인 지위에 있는 공증인과 객관성을 담보하는 증인들의 참여하에 유언이 이루어지므로 유언의 존재, 내용의 명확성이 담보되고 유언자의 사후 다툼이 생길 가능성이 거의 없으며 검인 없이 바로 집행할 수 있다는 장점이 있다.

반면에 절차가 복잡하고 비용이 많이 들며, 유언 내용이 타인에게 누설될 우려가 있다는 단점이 있다.

(2) 요건

(가) 증인 2인의 참여가 있을 것

증인이 두 명 이상 참여하여야 한다. 증인이 한 명만 참여하였거나 증인의 참여가 없으면 공정증서유언의 효력이 없으므로 무효이다(대법원 1994. 12. 22. 선고 94다13695 판결).

(나) 유언자가 공증인 면전에서 유언의 취지를 구수할 것

유언자가 공증인의 면전에서 유언의 취지를 구수하여야 한다. 유언자가 말로 표시하여야 하고 거동으로 표시하여서는 아니 된다. 따라서 식물인간이라든지 뇌질환 등으로 불완전한 의식상태에서 대화할 수 없어 공증인이 친족 중의 한 사람으로부터 유언내용을 전해 듣고 이러한 유언내용의 취지를 유언자에게 말하여 주며 ‘그렇소’라고 묻고 이에 대하여 유언자가 단순히 손짓, 발짓, 고개만 끄덕끄덕 하였다면 이는 구수로 볼 수 없다(대법원 2002. 9. 24. 선고 2002다35386 판결). 그러나 유언자가 미리 작성해 놓은 서면으로써 공증인이 공정증서의 원본을 작성한 후 유언자에게 그것을 읽어준 다음 서면대로 화답을 듣고 나서 공정증서를 작성하는 것은 유효하다고 할 것이다.

또한, 판례는 “공정증서에 의한 유언에서 ‘유언취지의 구수’라 함은 말로써 유언의 내용을 상대방에게 전달하는 것을 뜻하므로 이를 엄격하게 제한하여 해석하여야 할 것이지만, 공증인이 유언자의 의사에 따라 유언의 취지를 작성하고 그 서면에 따라 유언자에게 질문을 하여 유언자의 진의를 확인한 다음 유언자에게 필기된 서면을 낭독하여 주었고, 유언자가 유언의 취지를 정확히 이해할 의사식별능력이 있고 유언의 내용이나 유언 경위로 보아 유언 자체가 유언자의 진정한 의사에 기한 것으로 인정할 수 있는 경우에는, 위와 같은 ‘유언취지의 구수’ 요건을 갖추었다고 보아야 한다.”고 한다(대법원 2008. 8. 11. 선고 2008다1712 판결).

(다) 공증인이 필기하고 낭독할 것

공증인이 유언자의 구술을 필기하고, 이것을 유언자와 증인 앞에서 낭독하여야 한다. 또한, 필기는 공증인 자신이 반드시 하여야 하는 것은 아니며 사무원에게 집필시켜도 무방할 것이다. 필기는 반드시 유언자의 면전에서 할 필요는 없으며, 내용을 정리하여 작성하여도 무방하다. 공정증서는 국어로 작성되어야 한다(공증인법 제26조). 만일 외국인이 유언할 경우에는 통역인을 참가시켜 통역하게 하여야 한다(같은 법 제28조).

(라) 유언자와 증인이 승인하고 서명 또는 기명날인할 것

공증인이 필기한 후 낭독하면 이를 들은 유언자와 증인이 필기가 정확함을 승인한 후 각각 서명 또는 기명날인하여야 한다. 서명은 부호, 예명, 호 같은 것도 상관없다. 서명은 유언자 본인이 하는 것이지만, 기명날인은 반드시 유언자나 증인 자신이 직접할 필요가 없다고 할 것이다. 증인이 찍는 도장은 반드시 인감도장이나 실인(實

印)일 필요는 없다.

(마) 공증인이 부기하고 서명날인할 것

공증인은 위와 같은 절차를 마치게 되면 위와 같은 방식에 의해 유언서가 작성되었음을 유언서에 부기하고 서명날인하여야 한다.

공정증서에 의한 유언작성의 절차 도중에 유언자가 사망하면 유언은 성립하고 있지 않으므로 효력이 생기지 않는다. 그러나 유언자가 공증인의 필기가 정확함을 승인한 후 서명 또는 기명날인한 경우에는 그 뒤의 절차가 그 장소에서 완결되었으면 유효하다고 할 것이다.

(3) 출장공증

공증인은 그 사무소에서 직무를 행하는 것이 원칙이지만(공증인법 제17조), 유언의 경우에는 그 적용이 없으므로(같은 법 제56조), 공정증서에 의한 유언을 작성할 경우에는 출장에 의할 수도 있다.

(4) 검인절차 불요

공정증서에 의한 유언은 공정력이 있으므로 나중에 집행 시 별도의 검인절차가 필요하지 않다.

(5) 유언증서의 보존의무

공증인은 공정증서유언이 성립한 경우 그 원본을 공증인사무소에 서 20년간 보관하여야 하고(공증서류의 보존에 관한 규칙 제5조제1항제2호), 그 정본이나 등본은 유언자 기타 촉탁인, 승계인 또는 이해관계인의 청구에 따라 교부하여야 한다(공증인법 제46조제1항, 제50조제1항).

마. 비밀증서에 의한 유언

(1) 의 의

비밀증서에 의한 유언이란 유언자가 유언을 하면서 그 내용을 자기의 생전에는 비밀로 하고 싶은 경우에 비밀증서의 방식으로 하는 유언의 방식을 말한다.

비밀증서에 의한 유언은 반드시 자필로 작성하지 않아도 되기 때문에 다른 사람이 대필하는 것도 무방하고, 유언자가 문자는 쓸 수 없으나 읽을 수만 있는 경우에도 자기의 이름을 서명할 수 있으면 성립할 수 있다는 장점이 있다. 반면에 비밀증서의 성립에 대하여 다툼이 일어나기 쉽고 분실·훼손의 염려가 있다는 단점이 있다.

(2) 요 건

(가) 유언자가 필자의 성명을 기재한 증서를 엄봉·날인할 것

유언자는 증서 그 자체를 자서할 필요가 없으며, 연월일·주소의 기재도 필요 없다. 다만 증서의 전문과 연월일, 주소, 성명도 자서하고 날인함으로써 자필증서의 방식에 적합한 때에는 비밀증서로서의 방식에 흠결이 있는 경우라도 자필증서로서 유효하게 된다(민법 제1071조). 증서에는 필자의 성명을 반드시 기재하여야 하나, 작성일자 기재는 없어도 무방하다. 그리고 엄봉은 본인이 해야 한다고 해석되나, 날인은 반드시 본인이 할 필요는 없다고 할 것이다.

(나) 엄봉한 날인증서를 2인 이상의 증인의 면전에 제출하여 자기의 유언서임을 표시할 것

유언자는 엄봉한 날인증서를 2인 이상의 면전에 제출하여 유언서임을 표시하여야 한다. 표시방법은 반드시 언어로써 하여야 한다고

는 해석되지 않는다. 따라서 언어를 사용하지 못하는 자는 글을 써서 표시하여도 무방하다. 다만 증인은 2인 이상이어야 하므로 한 사람밖에 참여하지 않았다면 그 유언은 비밀증서에 의한 유언으로서의 효력이 없다(민법 제1069조).

(다) 봉서표면에 유언서의 제출연월일을 기재하고 유언자와 증인이 각자 서명 또는 기명날인할 것

엄봉한 비밀증서 표면에 유언서의 제출연월일을 기재하고, 유언자와 증인이 각자 서명 또는 기명날인하여야 한다. 유언자가 금치산자인 경우에는 참여한 의사가 봉서표면에 심신회복의 상태를 부기하고 서명·날인하여야 할 것이다.

(라) 확정일자를 부여받을 것

비밀증서에 의한 유언봉서는 그 표면에 기재된 날로부터 5일 이내에 공증인 또는 법원서기에게 제출하여 그 봉인상(엄봉한 봉투에 날인한 것을 의미함)에 확정일자인을 받아야 한다(민법 제1069조제2항).

바. 구수증서에 의한 유언

(1) 의 의

구수증서에 의한 유언이란 질병 기타 급박한 사유로 인하여 보통의 유언의 방식에 의한 유언을 할 수 없는 특별한 경우에 2인 이상의 증인이 참여한 상태에서 그 중 1인에게 유언의 취지를 구수하고, 그가 구수 내용을 필기·낭독하여 유언자와 증인이 그 정확함을 승인한 후 각자가 서명 또는 기명날인하는 방식으로 이루어지는 유언

이다.

유언의 엄격성 가운데 구수증서에 의한 유언은 다른 보통방식의 유언과 실질에 있어서 다르다고 보아야 하므로, 유언요건을 완화하여 해석하는 것이 타당할 것이다(대법원 1977. 11. 8. 선고 76므15 판결).

(2) 요건

(가) 질병 기타의 사유로 인해 다른 방식에 의한 유언을 할 수 없을 것

구수증서에 의한 유언은 유언자에게 질병 기타 급박한 사유가 발생하여 보통의 방식에 의한 유언을 할 수 없어야 한다. 여기서 '기타 급박한 사유'란 부상을 당하여 생명이 위협하거나 전염병 등으로 교통이 차단된 장소에 있는 경우, 조난한 선박에 승선하고 있거나 이와 유사한 상태의 급박한 상태를 말한다.

(나) 2인 이상의 증인의 참여로 그 중 1인에게 유언의 취지를 구수하여야 할 것

2인 이상의 증인이 참여한 자리에서 그 중 1인에게 유언의 취지를 구수하여야 한다. 만일 증인이 1인밖에 참여하지 않았을 때에는 그 유언은 무효이다.

(다) 구수를 받은 자가 이를 필기·낭독하고 승인할 것

구수를 받은 자가 이를 필기·낭독하여 유언자와 증인이 그 정확함을 승인한 후, 각자가 서명 또는 기명날인하여야 한다. 증인의 서명 또는 기명날인도 유언자의 생존 중에 하여야 하지만, 그 필기가

정확함을 승인한 후 유언자가 사망한 경우에도 그 자리에서 서명 또는 기명날인한 경우에는 유언의 성립을 인정해도 무방할 것이다.

(라) 급박한 사유 종료 후 7일 이내에 가정법원에 검인을 신청할 것

구수증서에 의한 유언은 그 증인 또는 이해관계인이 급박한 사유가 종료한 날로부터 7일 이내에 가정법원에 그 검인을 신청하여 가정법원으로부터 검인을 받아야 한다. 검인신청을 기각한 심판에 대해서는 즉시항고할 수 있다(가사소송규칙 제85조제2항). 판례는 7일의 기간을 도과한 검인신청은 부적법하여 무효라고 하고 있다(대법원 1994. 11. 3. 자 94스16 결정).

(마) 금치산자의 구수증서에 의한 유언

금치산자가 구수증서에 의한 유언을 하는 경우에는 그 의사능력이 회복되어야 한다(민법 제1063조제1항). 이 경우 의사는 심신회복의 상태를 유언증서에 부기하거나 서명·날인할 필요는 없다(민법 제1070조제3항, 제1063조제2항). 구수증서에 의한 유언의 경우에는 사실상 의사의 참여가 거의 불가능한 경우가 많기 때문이다.

사. 외국인 또는 재외국민의 유언방식

국제사법은 외국인 또는 외국에 거주하는 한국인의 유언방식에 대하여 ① 유언자가 유언 당시 또는 사망 당시 국적을 가지는 국가의 법, ② 유언자의 유언 당시 또는 사망 당시 상거소지법, ③ 유언 당시 행위지법, ④ 부동산에 관한 유언방식에 대하여는 그 부동산의 소재지법에 따른 유언을 인정하고 있다(국제사법 제50조).

3. 유언의 철회

가. 유언철회의 의의

유언은 유언자의 최종의사를 존중하는 제도이므로, 유언자가 유효한 유언을 한 후에도 언제든지 특별한 이유가 없더라도 자유로이 그 전부 또는 일부를 철회할 수 있다(민법 제1108조제1항). 우리 민법은 철회의 자유를 강조하여 유언자가 철회권을 포기할 수 없도록 하고 있다(민법 제1108조제2항). 따라서 유언자가 유언을 철회하지 않는다는 계약을 체결한 경우에도 그 계약은 무효이다.

나. 유언철회의 방식

(1) 임의철회

유언자는 유언 또는 생전행위로써 유언을 철회할 수 있다(민법 제1108조). 철회는 반드시 유언으로 할 필요가 없으며 생전행위로서도 할 수 있다. 유언으로 하는 경우에도 그 방식은 전에 한 유언의 방식과 같을 필요도 없다.

유언의 철회에는 요식성을 요구하지 않는다. 따라서 철회의 의사 표시를 하지 않고 유언증서를 파훼해 버리면 유언은 철회된 것으로 본다(민법 제1110조). 다만 공정증서에 의한 유언은 유언자가 정본을 파훼하더라도 원본이 공증인사무소에 보존되고 있으므로, 정본을 없애는 것만으로는 유언의 철회가 되지 않는다. 그러므로 공정증서에 의한 유언을 철회하려면 유언이나 생전행위로써 하여야 할 것이다.

(2) 법정철회

법정철회는 유언자가 유언을 철회한다고 명시적으로 밝히지 않더라도 일정한 법정사유가 발생한 경우에는 유언이 철회된 것으로 보는 것을 말한다. 유언자의 최종의 의사를 실현하고 미리 다툼을 예방하려는 취지에서 마련된 규정이다.

(가) 전후의 유언이 저촉되는 경우

두 개 이상의 유언이 존재하고 그 전후의 유언이 상호 저촉되는 경우에는 그 저촉된 부분의 전 유언은 철회한 것으로 본다(민법 제1109조 전단). 전후의 유언이 저촉되는 경우란 동일인에 의한 전후 두 개의 유언이 있어서 그 내용이 서로 모순되며, 양립하기 어려운 사항을 포함하고 있는 경우를 말한다.

(나) 유언 후의 생전행위가 유언과 저촉되는 경우

유언 후의 생전행위가 유언과 저촉되는 경우에는 그 저촉된 부분의 전유언은 이를 철회한 것으로 본다(민법 제1109조 후단). 여기서 생전행위란 유언자가 생존 중에 유언의 목적인 특정의 물건에 대하여 한 처분을 말하며, 그것이 유상이든 무상이든 묻지 않는다.

(다) 유언자가 유언증서 또는 유증의 목적물을 파훼한 경우

유언자가 고의로 유언증서나 유증의 목적물을 파훼한 때에는 그 파훼한 부분에 관한 유언은 철회한 것으로 본다(민법 제1110조). 여기서 파훼란 물건의 형체 또는 효용을 잃게 하는 모든 행위를 말한다. 고의로 파훼한다는 것은 파훼할 의사를 가지고 파훼한다는 뜻이며, 그 이유는 묻지 않는다. 철회의 효과는 파훼 또는 말소된 부분에 한한다. 유언증서의 멸실이나 분실로서는 유언이 실효되지 아니한다(대법원 1996. 9. 20. 선고 96다21119 판결). 이 경우 이해관계인

은 유언증서의 내용을 입증하여 유언의 유효를 주장할 수 있다.

다. 유언철회의 효과

유언이 철회되었을 때에는 유언은 처음부터 없었던 것과 마찬가지로의 결과가 되어 유언자가 사망하여도 아무런 효력이 생기지 않는다.

먼저 철회한 유언을 다시 철회하여 부활시킬 수 있는가가 문제가 된다. 이에 대해서는 부활의 효력을 인정하는 입법례(독일 민법 제 2257조, 제2258조)와 그 효력의 부활을 인정하지 아니하는 입법례(일본 민법 제1025조)가 있다. 우리 민법은 이에 관하여 아무런 규정을 두고 있지 않으나, 부활시킬 수 있다고 보는 것이 일반적 견해이다.

유언의 철회가 사기 또는 강박에 의한 경우에는, 그 내용이 신분에 관한 것일 때에는 인지취소(민법 제861조)의 규정이 유추적용되는 것이 타당할 것이고, 재산에 관한 것일 때에는 민법총칙상의 일반원칙에 의하여 취소할 수 있을 것이다.

4. 유언의 효력

가. 유언의 효력발생시기

유언은 유언자가 사망한 때로부터 그 효력이 생긴다(민법 제1073조제1항). 따라서 유언에 의하여 이익을 받는 자도 유언자가 사망할 때까지는 아무런 권리도 취득하지 못한다.

(1) 유언에 의한 재단법인의 설립

유언자가 재단법인의 설립을 유언한 경우에 유언자의 출연재산은

유언자의 사망 시에 재단법인의 재산으로 된다(민법 제43조, 제44조, 제47조제2항). 그러나 재단법인은 주무관청의 설립허가를 얻은 후 설립동기를 한 때에 성립하므로(민법 제33조), 유언자가 사망하여 유언의 효력이 발생하여도 즉시 재단법인이 성립되는 것이 아니라, 유언집행자 또는 상속인이 설립허가의 신청을 하고 주무관청의 허가를 받아야만 한다. 그리하여 재단법인이 설립된 후 출연재산에 대해 이전동기를 하게 되면, 유언자가 사망한 때에 소급하여 그때부터 법인에 귀속한 것으로 본다(민법 제48조).

(2) 유언에 의한 친생부인

부(夫) 또는 처가 유언으로 친생부인의 의사를 표시한 때에는 유언집행자가 친생부인의 소를 제기하여야 한다(민법 제850조).

(3) 유언에 의한 인지

유언에 의한 인지의 경우(민법 제859조제2항 전단)에도 그 효력이 생기는 것은 유언자가 사망한 때이며, 가족관계등록 등에 관한 법률에 정한 바에 의하여 신고한 때가 아니라고 해석하여야 할 것이다. 이러한 해석에 의하면 인지신고는 보고적 신고가 된다.

(4) 조건부 또는 기한부 유언

(가) 정지조건부 유언

유언은 그 내용이 신분에 관한 행위와 같이 성질상 허용되지 않는 경우를 제외하고는 조건이나 기한을 붙여서 유언하더라도 무방하다.

민법 제1073조제2항은 “유언에 정지조건이 있는 경우에 그 조건

이 유언자의 사망 후에 성취한 때에는 그 조건성취한 때로부터 유언의 효력이 생긴다.”고 규정하고 있다. 이 규정은 정지조건부 법률행위에 대한 당연 규정으로, 같은 조 제1항과의 관계상 주의적으로 규정한 것에 불과하다.

효력의 발생은 사망한 때로 소급하지 않는 것이 원칙이나, 유언자가 유언 중에서 조건성취의 효력을 그 성취 전에 소급하게 할 의사를 표시한 때에는 사망 시에 소급하여 효력을 발생시킬 수 있다(민법 제147조제3항).

정지조건이 유언자의 사망 전에 성취된 경우에는 유언은 조건 없는 유언이 되어 유언자의 사망과 동시에 효력이 발생한다.

(나) 해제조건부 유언

해제조건부 유언에 대해서는 민법에 규정이 없으나, 유언에 해제조건을 붙이면 유언은 유언자가 사망한 때로부터 그 효력이 생기며, 그 조건이 사망 후에 성취하였을 때에는 조건이 성취한 때부터 효력을 잃는다고 보아야 한다(민법 제147조제2항).

유언자의 사망 전에 조건이 이미 성취된 경우에는 유언이 목적으로 하는 효과는 발생하지 않는다. 또한, 유언자가 조건성취의 효과를 그 이전에 소급시키는 의사를 표시하였을 때에는 그 의사에 의한다(민법 제147조제3항).

(다) 시기(始期)부 유언

유언의 효력발생에 시기가 붙어 있는 시기부 유언의 경우에는, 유언의 효력은 유언자가 사망한 때로부터 생기나 그 이행은 기한이 도래한 때에 비로소 청구할 수 있게 된다(민법 제152조제1항). 그

러나 그 시기가 유언의 효력발생을 정지시키는 취지일 때에는 유언은 그 시기가 도래한 때로부터 그 효력이 발생한다.

(라) 종기(終期)부 유언

유언에 종기가 붙어있는 경우에는, 유언은 유언자가 사망한 때로부터 그 효력이 생기며 기한의 도래에 의하여 그 효력을 잃는다(민법 제152조제2항). 상속은 재산분할에 대하여 유언으로 5년 기간 내에서 금지할 수 있도록 하고 있기 때문에 5년 내의 종기를 붙일 수 있다(민법 제1012조).

나. 유언의 무효와 취소

유언자는 그 생존 중에 유언의 효력을 잃게 하려면 무효·취소를 주장할 필요 없이 철회할 수 있으므로, 유언의 무효·취소가 문제되는 것은 주로 유언자가 사망한 이후의 경우이다.

유언의 내용 중 가족법적 의사표시를 내용으로 하는 유언에 대해서는 민법총칙규정이 적용되지 않으나, 재산법적 의사표시를 내용으로 하는 유언에는 민법총칙규정이 적용된다.

유언도 법률행위이므로 법정방식이 흠결된 유언, 유언무능력자의 유언, 수증결격자에 대한 유언, 선량한 풍속 기타 사회질서 또는 강행규정에 위반되는 것을 내용으로 하는 유언 및 법정사항 외의 사항을 내용으로 하는 유언은 무효이다.

유언 내용의 중요부분에 착오가 있거나 사기·강박에 의하여 유언이 이루어진 경우에 그 유언은 취소할 수 있다.

제 3 절 | 유 증

1. 서 설

가. 유증의 의의

유증이란 유언자가 유언에 의하여 자기 재산을 타인에게 무상으로 주는 단독행위를 말한다. 즉 유언에 의한 유산처분이다. 유증의 자유, 그 효력발생시기와 유증의 무효 또는 실효에 대해서는 유언에 관한 규정이 적용된다.

유증은 단독행위라는 점에서 계약인 사인증여와 구별되지만, 사인행위라는 점에서 그와 유사하므로 유증에 관한 규정이 사인증여에 준용된다(민법 제562조). 다만 유증에 관한 규정 중에서 능력(민법 제1061조부터 제1063조), 방식(민법 제1065조 이하), 승인과 포기(민법 제1074조부터 제1077조) 등에 관한 규정은 성질상 차이가 있기 때문에 준용되지 않고, 민법 제1078조를 제외한 유증의 효력에 관한 규정이 준용된다.

나. 유증의 종류

유증은 기본적으로 포괄적 유증과 특정적 유증으로 나눌 수 있다. 포괄적 유증과 특정적 유증으로 구별하는 이유는 그 효력에서 차이가 있기 때문이다. 즉 사안에 따라 유증이 포괄적 유증과 특정적 유증 중 어디에 속하는지가 불분명한 때도 있는데, 이때에 상속재산에 대한 비율의 의미로 해석되는 경우에는 포괄적 유증으로 보아야 할 것이다.

그 밖에 조건부 유증, 기한부 유증, 부담부 유증, 조건·기한 및

부담이 없는 단순유증으로 나누기도 한다.

다. 유증의 당사자

(1) 유증을 받는 자

유증에 의하여 이익을 받는 자, 즉 유증을 받을 자로서 수증자는 다음의 요건을 갖추어야 한다.

① 유증을 받는 자는 제한이 없으므로, 자연인뿐만 아니라 법인도 수증자가 될 수 있으며 또한 유언자의 상속인도 수증자가 될 수 있다.

② 수증자는 상속의 경우와 마찬가지로 유증이 효력을 발생하는 시기, 즉 유언자의 사망 시에 권리능력을 갖추고 있어야 한다. 이 요건은 특히 조건부 또는 기한부 유증과 관련하여 의미를 가진다. 즉 수증자가 유언자의 사망 전에 사망하였다면 유증의 효력이 발생하지 않으며, 정지조건부 유증에서 수증자가 그 조건 성취 전에 사망한 경우에도 마찬가지로 볼 수 있다.

③ 태아는 유증에 관하여 이미 출생한 것으로 보고 있으므로(민법 제1064조, 제1000조제3항), 태아도 유증을 받을 수 있다. 다만 유언자 사망 시에 포태되지 않았다면 태아가 아니므로 수증자로 되지 못한다.

④ 수증자는 상속결격자가 아니어야 한다(민법 제1064조, 제1004조).

⑤ 수증받은 자는 유증의 승인과 포기를 자유롭게 할 수 있기 때문에 결과적으로 그 의사에 반하여 유증 받기를 강요당하지 아니할 권리가 있다(민법 제1074조). 이와 관련하여 민법은 유증의무자로

하여금 상당한 기간을 정하여 승인과 포기의 확답을 하라고 유증 받은 자에게 최고할 수 있도록 하고 있다(민법 제1077조).

위의 요건을 갖추지 못하여 유증의 효력이 생기지 않거나 수증자가 이를 포기한 경우에, 유증의 목적인 재산은 상속인에게 속하지만, 유언자가 유언으로 다른 의사를 표시하였다면 그 의사에 따를 것이다(민법 제1090조).

(2) 유증의무자

유증을 실행할 의무를 지는 자를 유증의무자라고 한다. 유증에서 대상이 되는 재산의 양도 의무는 유언자의 사망 이후에 집행되기 때문에 유언자 자신이 그 의무를 이행할 수 없고, 별도의 유증의무자가 존재할 수밖에 없다. 보통은 상속인이 될 것이지만 유언집행자(민법 제1101조), 포괄적 수증자(민법 제1078조), 상속인 없는 재산의 관리인(민법 제1053조, 제1056조) 등이 유증의무자가 된다. 유증의무자인 상속인이 여러 명 있는 경우, 상속인 각자는 자기 상속분에 따라 유증의무를 부담한다고 할 것이다.

2. 포괄적 유증

가. 포괄적 유증의 의의

포괄적 유증이란 유증자의 적극·소극의 재산을 포괄하여 상속재산의 전부 또는 그 분수적 부분이나 비율에 따른 유증을 말한다. 예를 들어 전체 상속재산 중 2분의 1을 갑에게 주는 형태의 유증이다. 주로 사실혼관계에 있는 자, 후순위 상속인 또는 사회단체 등에 유증하는 경우가 이에 해당될 것이다.

나. 포괄적 유증의 효과

(1) 포괄적 수증자의 지위

포괄적 수증자는 실질적으로 상속인과 거의 동일하다. 민법 제1078조는 “포괄적 유증을 받은 자는 상속인과 동일한 권리의무가 있다.”고 규정하여 이러한 지위를 부여하고 있다.

포괄적 수증자가 있게 되면 마치 상속인이 한 명 더 늘어난 것과 같은 효과가 있다. 따라서 포괄적 수증자는 포괄적 유증을 받은 비율만큼 상속재산으로부터 권리의무를 취득하게 된다. 포괄적 수증자는 상속인과 마찬가지로 유언자의 일신전속적 권리를 제외한 나머지 권리의무를 포괄적으로 승계한다(민법 제1005조).

포괄적 수증자와 상속인이 있거나, 수인의 포괄적 수증자만 있는 경우에 이러한 자 사이의 관계는 공동상속인 사이에서의 공동상속관계와 마찬가지로 관계가 생긴다. 즉 상속재산의 공유관계가 생기며(민법 제1006조, 제1007조), 상속재산 분할의 협의를 통해 상속재산 및 유증재산을 분할하게 된다(민법 제1013조).

(2) 포괄적 유증의 효력발생시기

포괄적 유증을 받은 자는 유언자의 사망과 동시에 유증 받은 재산에 대한 포괄적 권리의무를 법률상 당연히 승계한다(민법 제1073조 제1항, 제1005조). 즉 포괄적 수증자는 유증의 효력이 발생함과 동시에 적극·소극재산을 포괄하는 상속재산의 전부 또는 일정비율에 따른 수증분을 당연히 취득하므로 포괄적 유증은 물권적 효력을 가진다는 것이 통설이다. 따라서 포괄적 유증의 목적물이 부동산인 경우에 유언자의 물권은 상속과 같이 등기 없이 법률상 당연히 수증자에게 이전한다(민법 제187조). 또한, 동산이나 채권의 승계와 관련

하여 인도, 대항요건 등을 갖추지 않더라도 물권적 권리의전이 이루어진다.

(3) 포괄적 유증의 승인과 포기

포괄적 유증을 받은 자는 유증을 승인하거나 포기할 수 있다(민법 제1076조). 포괄적 유증의 승인과 포기에는 상속의 승인 또는 포기에 관한 민법 제1019조부터 제1044조까지의 규정이 적용된다. 따라서 유증을 받은 자는 유증에 대하여 한정승인도 할 수 있다.

유증의 승인과 포기에 관한 민법 제1074조부터 제1077조까지는 특정적 유증에만 적용된다고 할 것이다. 왜냐하면, 포괄적 수증자는 유증의 효력이 발생한 것을 안 날로부터 3월내에 단순승인이나 한정승인 또는 포기를 하여야 하며, 3월내에 한정승인 또는 포기를 하지 않았을 때에는 포괄적 유증의 단순승인이 있는 것으로 보기 때문에 민법 제1074조부터 제1077조까지는 적용될 여지가 없기 때문이다.

(4) 포괄적 수증자의 권리행사

앞에서 설명한 바와 같이 포괄적 수증자의 법적 지위는 상속인과 거의 차이가 없기 때문에 포괄적 유증에 기인한 청구권은 상속회복 청구권의 제척기간이 유추적용된다(대법원 2001. 10. 12. 선고 2000다22942 판결).

(5) 포괄적 유증이 무효 또는 포기된 경우 재산의 귀속

포괄적 유증이 무효이거나 수증자가 이를 포기한 경우에, 유언자가 유언에서 다른 의사를 표시하지 않는 한 유증의 목적인 재산은 상속인에게 귀속하고(민법 제1090조), 상속인이 여러 명이면 상속

분의 비율로 귀속된다(민법 제1043조). 상속인 이외에 다른 포괄적 수증자가 있는 경우 유증의 목적인 재산이 상속인에게만 귀속될 것인지 아니면 다른 포괄적 수증자의 수증분이 증가할 것인지에 대해서는 견해가 대립된다.

다. 포괄적 수증자와 상속인의 비교

포괄적 수증자와 상속인은 채무를 포함하여 상속재산을 포괄적으로 승계한다는 점, 상속인 및(또는) 다른 포괄적 수증자가 있는 경우에 포괄 수증자는 그들과 상속재산을 공유하며 이 상태는 상속재산 협의분할로 해소된다는 점, 승인 또는 포기를 할 수 있다는 점 및 재산분리절차와 결격사유에서 공통된다.

하지만 상속능력이 인정되지 않는 법인도 수증자가 될 수 있다는 점, 상속인은 유류분권을 가지지만 포괄적 수증자는 유류분권이 없다는 점, 포괄적 유증에는 대습상속 규정이 적용되지 않으므로 포괄적 수증자가 유언자보다 먼저 사망하면 포괄적 유증이 효력을 잃는다는 점(민법 제1089조제1항), 포괄적 수증자에게는 상속분의 양수권(민법 제1011조제1항)이 없다는 점, 상속에는 조건과 기한을 붙일 수 없으나 포괄적 유증에는 이를 붙일 수 있다는 점 등에서 포괄적 수증자와 상속인은 다르다.

3. 특정적 유증

가. 특정적 유증의 의의

특정적 유증이란 유증자의 재산 중 특정재산을 구체적으로 지정하여 유증의 내용으로 하는 경우를 말한다. 예를 들어 유언자의 재

산 중에서 특정 부동산 또는 채권을 지정하여 그 재산을 수증자에게 유증하겠다고 하는 것이다.

특정적 유증은 포괄적 유증과 달리 구체적인 재산을 목적으로 하는 유증이기 때문에 특정적 유증의 수증자는 특정의 재산권에 관하여 증여계약에 있어서의 수증자와 동일한 지위에 있다. 또한, 특정적 유증의 승인과 포기는 포괄적 유증이나 상속의 포기·승인과 그 성질을 달리하기 때문에 특별규정을 두고 있다.

나. 특정적 유증의 효과

(1) 유증목적물의 귀속시기

특정적 유증의 경우에는 포괄적 유증과 달리 특정적 유증의 목적물은 일단 상속재산으로 취급되어 상속인에게 귀속하게 되며, 수증자는 상속인에 대하여 유증의 이행을 청구할 수 있는 권리(채권적 효력)를 취득하게 된다는 것이 통설이자 판례의 입장이다(대법원 2003. 5. 27. 선고 2000다73445 판결). 따라서 유증의 목적물인 특정의 재산권은 그 이행으로 비로소 수증자에게 이전된다. 다만 채무면제와 같이 의사표시만으로 효력을 발생하는 경우에는 물권적 효력이 인정된다.

특정적 유증의 채권적 효력의 근거로, 민법이 물권변동에 있어서 형식주의를 취하고 있다는 점, 상속의 한정승인과 재산분리의 경우에 상속채권자에게 먼저 변제를 완료한 후가 아니면 수증자에게 변제하지 못하도록 한 민법 제1036조와 동조를 준용하는 제1051조제3항이 채권적 효력을 전제로 한 것이라는 점 및 유증포기의 자유가 인정되는 점 등을 들 수 있다.

(2) 유증목적물의 과실취득권

특정적 유증의 수증자는 유증의무자에 대하여 유증의 내용에 따른 이행을 청구할 수 있다. 수증자는 유증의 이행을 청구할 수 있는 때로부터 그 목적물의 과실을 취득한다(민법 제1079조 본문). 유증의 이행을 청구할 수 있는 때란 단순유증의 경우에는 유언자가 사망한 때이고, 조건이 있는 유증의 경우에는 조건이 성취한 때, 시기가 있는 유증의 경우에는 기한이 도래한 때이다.

과실은 천연과실 및 법정과실 모두가 해당된다. 그러나 유언자가 유언으로 이와 다른 의사를 표시한 때에는 그 의사에 의한다(민법 제1079조 단서). 다른 의사란 예를 들어 시기가 있는 유증의 경우에 유언자가 사망한 때로부터 과실을 취득시킨다든지, 단순유증의 경우에 유증의 목적물을 점유한 때로부터 과실을 취득시킨다는 등의 별도의 의사를 표시할 때를 말한다.

(3) 유증의무자의 비용상환청구권

유증의무자는 유언자의 사망 후에 그 목적물의 과실을 수취하기 위하여 필요비를 지출한 때에는 그 과실의 가액의 한도 내에서 과실을 취득한 수증자에게 비용의 상환을 청구할 수 있다(민법 제1080조).

이 경우에는 그 목적물에 대하여 지출한 비용에 대하여는 유치권자의 비용반환청구권에 관한 민법 제325조가 준용된다(민법 제1081조). 따라서 유증의무자가 필요비를 지출한 경우에는 수증자에 대하여 그 전액을, 유익비를 지출한 경우에는 그 가액의 증가가 현존한 경우에 한하여 수증자의 선택에 좇아 지출액 또는 가치증가액 중 하나를 청구할 수 있다.

(4) 유증의무자의 담보책임

유언자가 불특정물을 유증의 목적으로 한 경우에 유증의무자는 그 목적물에 대하여 매도인과 같은 담보책임이 있다(민법 제1082조 제1항). 유증의 성질상 계약해제는 문제가 되지 않고, 손해배상과 완전물급부청구가 문제 될 것이다. 이 경우에 목적물에 하자가 있는 때에는 유증의무자는 하자 없는 물건으로 인도하여야 한다(민법 제1082조 제2항). 하자 없는 물건으로 인도할 수 없을 때에는 유증의무자는 손해배상책임이 있다.

한편 특정물을 유증의 목적으로 한 경우에는 그 물건 자체가 유증의 목적이기 때문에 유증의무자가 담보책임을 지지 않는다고 할 것이지만, 민법 제559조 제1항 단서를 유추하여 그 하자나 흠결을 알고도 이를 수증자에게 고지하지 않았다면 담보책임을 진다고 할 것이다.

(5) 유증의 물상대위성

유증자가 유증목적물의 멸실·훼손 또는 점유의 침해로 인하여 제3자에게 손해배상을 청구할 권리가 있는 때에는 그 권리를 유증의 목적으로 본다(민법 제1083조). 다만 유언자가 유언으로 다른 의사표시를 한 경우에는 그 의사에 의한다(민법 제1086조). 유증목적물의 멸실에는 목적물 자체가 멸실하거나 목적물에 대한 소유권을 상실한 경우를 포함한다. 예를 들어 유언을 한 후 그 유증의 목적물이 화재로 소실된 경우 보험회사에 대한 보험금청구권, 제3자의 침해가 있는 경우 제3자에 대한 손해배상청구권, 토지가 수용된 경우의 수용보상금청구권으로 변한 경우 그 권리 위에 유증의 효력이 미친다.

그러나 유증의 목적물이 유언 당시에 이미 멸실·훼손되어 존재하지 않은 경우에는 유증자가 제3자에 대하여 손해배상청구권을 가지고 있더라도 이 규정은 적용되지 않는다.

유언자가 물상대위권을 취득하게 되는 원인은 묻지 아니한다. 만일 유언자가 유언 후에 발생한 물상대위권에 근거한 손해배상청구권을 제3자에게 양도하거나 유언자가 직접 행사하여 손해배상을 받아 손해배상청구권이 소멸한 경우에는 유언의 철회로 보아야 하므로 수증자는 아무런 권리도 취득하지 못한다(민법 제1109조).

채권을 유증의 목적으로 한 경우에 유언자가 그 변제를 받은 물건이 상속재산 중에 있다면 그 물건을 유증의 목적으로 한 것으로 본다(민법 제1084조제1항). 또한, 유언자가 금전을 목적으로 한 경우에 그 변제받은 채권액에 상당한 금전이 상속재산 중에 없는 때에도 그 금액을 유증의 목적으로 한 것으로 본다(민법 제1084조제2항). 여기에서도 유언자가 유언으로 다른 의사표시를 한 경우에는 그 의사에 의한다(민법 제1086조).

(6) 제3자의 권리의 목적인 물건 또는 권리의 유증

유증의 목적인 물건이나 권리가 유언자의 사망 당시 제3자의 권리의 목적인 경우, 예를 들어 유증의 목적인 부동산 위에 제3자의 저당권이 설정되어 있는 경우에는 수증자는 유증의무자에 대하여 그 제3자의 권리를 소멸시킬 것을 청구하지 못한다(민법 제1085호). 다만 유언자가 유언으로 다른 의사표시를 한 경우에는 그 의사에 의한다(민법 제1086조).

(7) 상속재산에 속하지 않은 권리의 유증

특정적 유증의 내용에 관하여 유언의 목적이 된 권리가 유언자의 사망 당시에 상속재산에 속하지 아니한 때에는 유언은 그 효력이 없다. 그러나 유언자가 자기의 사망 당시에 그 목적물이 상속재산에 속하지 아니한 경우에도 유언의 효력이 있게 할 의사인 때에는 유증 의무자는 그 권리를 취득하여 수증자에게 이전할 의무가 있다. 이러한 경우에 그 권리를 취득할 수 없거나 그 취득에 과다한 비용을 요할 때에는 그 가액으로 변상할 수 있다(민법 제1087조).

다. 특정적 유증의 승인과 포기

(1) 승인과 포기의 시기 및 이해관계인의 최고

유증을 받은 자는 유언자의 사망 후에 언제든지 유증을 승인 또는 포기할 수 있고, 그 효력은 유언자가 사망한 때에 소급한다(민법 제1074조제1항). 유증은 그 자체의 요건을 갖추면 수증자의 의사와 관계없이 그 효력을 발생하지만, 수증자의 의사에 반하게 권리취득을 강제하는 것은 불합리하기 때문이다. 즉 유증에 의한 이익향수를 원하지 않는 수증자는 유증을 거절 내지 포기할 수 있다.

유증의무자나 이해관계인은 상당한 기간을 정하여 그 기간 내에 승인 또는 포기를 확답할 것을 수증자 또는 그 상속인에게 최고할 수 있고, 그 기간 내에 확답이 없으면 유증을 승인한 것으로 본다(민법 제1077조). 상당한 기간이란 수증자가 유증의무자에 대하여 하는 승인·포기의 의사표시가 도달하는 데 충분한 기간 이상이어야 한다. 최고의 방식에는 제한이 없으므로 적당한 방법에 의하여 수증자에게 도달함으로써 그 효력이 생긴다(민법 제111조). 수증자가 무능력자인 경우에는 그 법정대리인에게 최고하여야 하며, 그 법정대리인이 최고의 사실을 알지 못하는 한 최고로써 수증자에게 대항할

수 없다(민법 제112조).

(2) 유증의 승인과 포기의 방법

유증의 승인이나 포기는 수증자의 의사표시에 의한다. 특정적 유증의 내용이 가분이라면 일부만을 포기할 수 있다.

수증자가 유증을 승인 또는 포기하지 않고 사망한 경우에 그 상속인은 상속분의 한도에서 승인 또는 포기를 할 수 있다. 그러나 유언자가 유언으로 다른 의사표시를 하였다면 그 의사에 의한다(민법 제1076조).

(3) 유증의 포기와 권리의 승계

유증을 승인한 경우에 이미 발생한 유증의 효력을 확인하는 결과로 되지만, 포기한 경우에는 유언자의 사망 시에 소급하여 처음부터 유증이 없었던 것과 같이 된다. 포기된 유증의 목적물은 유언자가 유언으로 다른 의사를 표시하지 않은 한, 상속인에게 귀속된다(민법 제1090조).

(4) 유증의 승인과 포기의 취소금지

수증자가 일단 유증의 승인이나 포기를 한 후에는 이를 취소하지 못한다(민법 제1075조제1항). 일단 유효하게 표시된 유증의 승인이나 포기의 철회를 허용한다면 이해관계인의 신뢰에 반하고 예기치 못한 손해를 발생시킬 수 있기 때문이다. 다만 유증의 승인이나 포기가 사기·강박에 의하여 한 경우 또는 무능력자가 단독으로 한 경우에 이를 취소할 수 있고, 그 취소권은 추인할 수 있는 날로부터 3월, 승인 또는 포기한 날로부터 1년내에 행사하여야 한다(민법 제1075조제2항, 제1024조제2항).

4. 부담부 유증

가. 부담부 유증의 의의

부담부 유증이란 유언자가 유증을 함에 있어 수증자에게 자기, 그 상속인 또는 제3자를 위하여 일정한 의무를 이행할 부담을 과하는 유증을 말한다. 예를 들어 상속재산 중 일부를 유증하면서 유증자의 미성년자인 자를 성년이 될 때까지 양육해 달라고 부담지우는 것 같은 경우이다. 부담부 유증에서 부담은 대가가 아닐 뿐만 아니라 유증자에 대한 반대급부란 있을 수 없으므로, 부담부 유증도 무상행위이다.

부담부 유증은 수증자에게 일정한 의무를 부담시킬 뿐, 유증의 효력의 발생 또는 소멸과 관계되는 조건부 유증이 아니다. 따라서 부담의 불이행이 있다고 하더라도 유증의 효력이 당연히 소멸하는 것은 아니다.

유언자는 포괄유증, 특정유증을 구별함이 없이 부담부 유증을 할 수 있으며, 부담은 유증의 목적물과 전혀 관계가 없는 사항이라도 무방하다.

나. 부담의 내용

부담부 유증에 있어서 부담은 유증의 대가나 반대급부가 아니다. 따라서 부담의 내용이 반드시 금전적 가치를 가져야 할 필요도 없다. 그러나 도덕적 유훈 같은 것은 부담이 아니다.

부담부 유증에 있어서의 부담은 법률상의 의무라야 하며, 그 내용은 수증자의 작위일 수도 있고 부작위일 수도 있다. 부담부 유증의 부담으로 인해 유언자 자신이 이익을 얻을 수도 있고, 제3자가 이익

을 취할 수도 있다. 수익자가 특정인이든 불특정인이든 무방하다.

다. 부담부 유증의 효력

(1) 부담의 이행의무자

부담의 이행에 대한 이행의무를 부담하는 자는 수증자이다. 만일 수증자가 사망한 경우에는 수증자의 상속인도 그 유증을 승인하면 상속의 범위 내에서 이행의무자가 된다. 수증자가 부담부 유증의 승인 또는 포기를 하지 않고 사망한 때에는 그 상속인은 상속분의 한도에서 승인 또는 포기를 할 수 있다(민법 제1076조).

(2) 부담의 이행청구권자

상속인, 유언집행자는 부담부 유증의 부담인 채무의 이행을 수증자에게 청구할 수 있다. 만일 수증자가 부담을 이행하지 않을 경우에는 상속인은 이를 최고한 후 법원에 유언의 취소를 청구할 수 있다. 그러나 제3자의 이익을 해하지 못한다(민법 제1111조).

유언자가 유언에서 특히 부담의 이행을 청구할 자를 지정하였을 때에는 그 사람은 부담의 이행을 청구할 수 있다.

부담의 이익을 받을 제3자가 수증자에 대하여 부담의 이행을 청구할 수 있는가에 대하여는 이를 부정하는 견해와 긍정하는 견해가 대립하고 있다.

(3) 수증자의 책임범위

부담있는 유증을 받은 자는 유증의 목적 가액을 초과하지 않는 한도에서 부담한 의무를 이행할 책임이 있다(민법 제1088조제1항). 부담이 유증의 목적 가액을 초과한 때에는 그 초과 부분은 무효가 된

다. 수증자는 유증자의 의사에 따라 일정 재산을 유증받지만, 그보다 더 무거운 부담을 책임질 의무는 없기 때문이다. 따라서 부담있는 수증자는 그 초과부분의 이행을 거절할 수 있고, 이미 초과하여 이행한 것은 반환청구할 수 있다. 유증의 목적 가액과 부담의 가액이 동일한 때에는 유증은 수증자에게 이익이 없으므로 수증을 포기할 수 있다.

유증의 목적 가액과 부담 가액의 평가는 어느 시점을 기준으로 할 것인가 문제가 되나, 수증자의 불이익을 막기 위하여 부담의 이행시를 기준으로 하는 것이 타당할 것이다.

유증의 목적 가액이 한정승인 또는 재산분리로 인하여 감소된 때에는 수증자는 그 감소된 한도에서 부담할 의무를 면한다(민법 제1088조제2항).

부담부 유증에 있어서 부담이 불능이거나 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 사항을 목적으로 하는 것인 때에는 그 부담은 무효이다. 이 경우 원칙적으로 부담부 유증은 단순유증이 될 것이나, 그 부담 부분이 없었더라면 유증자가 유증을 하지 않았을 것으로 될 경우에는 부담부 유증 전체가 무효가 된다.

수증자가 유증을 받는 것을 포기하면 유증은 소급적으로 실효되고, 그에 따라 부담도 당연히 실효된다. 이 경우 유증의 목적인 재산은 유언자의 상속인에게 귀속된다. 다만 유언자가 다른 의사표시를 한 경우에는 그 의사에 따른다.

(4) 부담부 유증의 취소

부담부 유증을 받은 자가 유증을 받고서도 그 부담의무를 이행하지 않는 경우에는 상속인 또는 유언집행자는 상당한 기간을 정하여

이행할 것을 최고하고, 그 기간 내에 이행하지 않을 때에는 가정법원에 유언의 취소를 청구할 수 있다(민법 제1111조 본문, 가사소송법 제2조제1항). 그러나 제3자인 수익자는 유증의 당사자가 아니므로 유증의 취소청구를 할 수 없다.

가정법원의 취소심판이 있게 되면 유증은 상속개시 시에 소급하여 그 효력을 잃는다. 따라서 청구권자는 수증자에 대하여 유증의 목적 반환을 청구할 수 있다. 그러나 제3자가 이미 수증자로부터 전득한 이익을 해하지 못한다(민법 제1111조 단서).

제 4 절 | 유언의 집행

1. 유언집행의 의의

유언의 집행이란 유언의 효력이 발생한 후 유언에 표시된 유언자의 의사를 실현하는 행위 또는 절차를 말한다. 유언의 내용에는 후견인의 지정, 상속재산의 분할금지와 같이 그 실현을 위하여 특별한 행위를 요하지 않는 경우도 있지만, 친생부인, 인지와 같이 유언의 내용을 법률적으로 실현하기 위하여 집행을 필요로 하는 경우가 있는바, 이러한 유언은 집행을 필요로 한다.

2. 유언집행의 준비절차

가. 유언의 검인

유언의 검인이란 유언증서의 형식·태양 등 유언의 방식에 관한

모든 사실을 조사·확인하고, 그 위조·변조를 조사하며, 이에 대한 보존을 확실히 하려는 일종의 검증절차·증거보전절차를 말한다. 유언의 검인은 유언이 유언자의 진의에 의한 것인가 적법한가를 심사하기 위한 것이 아니며, 직접 유언의 유효여부를 판단하는 심판이 아니다(대법원 1998. 6. 12. 선고 97다38510 판결).

유언의 증서나 녹음을 보관한 자 또는 이를 발견한 자는 유언자의 사망 후 지체 없이 가정법원에 제출하여 그 검인을 청구하여야 한다(민법 제1091조제1항, 가사소송법 제2조제1항). 그러나 공정증서나 구수증서에 의한 유언의 경우에는 검인이 필요 없다(민법 제1091조제2항).

나. 유언의 개봉

유언의 개봉이란 봉인된 유언증서를 가정법원이 개봉하여 확인하는 유언의 집행 준비절차를 말한다. 가정법원이 봉인된 유언증서를 개봉할 때 유언자의 상속인, 그 대리인 기타 이해관계인을 참여시켜야 한다(민법 제1092조). 개봉에 관하여 조서를 작성하여야 하고(가사소송규칙 제87조), 출석하지 않은 상속인 기타 유언의 내용에 관계되는 자에게 그 사실을 고지하여야 하며(같은 규칙 제88조), 개봉에 관한 비용은 상속재산의 부담으로 한다(같은 규칙 제90조).

3. 유언집행자

가. 유언집행자의 의의

유언집행자란 유언의 집행절차를 담당하는 자로서, 실제로는 유언자에 같음하여 유언의 내용을 실현하는 행위를 한다. 유언 중에

특정유증, 재단법인의 설립, 신탁 등 상속인이 스스로 집행하여도 무방한 것이 있으나, 친생부인이나 인지 등은 반드시 집행자를 두어 집행하여야 한다.

나. 유언집행자의 지위

유언집행자의 지위에 관하여는 그 효과가 누구에게 귀속되느냐와 관련하여 상속인대리인설, 유언자대리인설 등의 견해 대립이 있지만, 민법은 “지정 또는 선임에 의한 유언집행자는 상속인의 대리인으로 본다.”(민법 제1103조제1항)라고 하여 상속인대리인설을 따르고 있다. 유언집행자의 관리처분권 또는 상속인과의 법률관계에 대해서는 위임의 규정 (민법 제681조부터 제685조까지 등)이 준용된다(민법 제1103조제2항).

유언집행자는 유언집행에 필요한 행위를 할 권리·의무를 가진다(민법 제1101조). 유언집행자가 재산관리를 함에 있어서는 위임규정 중 수임인에 관한 규정이 준용되므로 선량한 관리자로서의 주의의무를 다 하여야 한다. 유언집행자는 재판상의 행위 및 재판 외의 행위를 모두 할 수 있다.

다. 유언집행자의 결정

유언집행자에는 유언자의 유언에 따른 유언지정집행자, 법률에서 정한 법정유언집행자, 법원에서 선임하는 선임유언집행자가 있다.

(1) 지정유언집행자

유언자는 유언으로 유언집행자를 지정하거나 그 지정을 제3자에 위탁할 수 있다(민법 제1093조). 유언집행자 지정의 위탁을 받은 자

는 그 위탁 있음을 안 후 지체 없이 유언집행자를 지정하여 상속인에게 통지하여야 하고, 위탁을 사퇴하기 위해서도 그 사실을 상속인에게 통지하여야 한다(민법 제1094조제1항). 유언집행자의 위탁을 받은 자가 지정을 하지 않고 있다면, 상속인 기타 이해관계인은 상당한 기간을 정하여 그 기간 내에 지정할 것을 최고할 수 있고, 최고가 있음에도 최고기간 내에 유언집행자를 지정하는 통지를 최고한 자가 받지 못하면 지정을 받은 위탁자가 그 지정의 위탁을 사퇴한 것으로 본다(민법 제1094조제2항).

유언집행자로 지정된 자는 상속의 개시 후 지체 없이 그 승낙 또는 포기를 상속인에게 통지하여야 하고(민법 제1097조제1항), 지정된 자가 지정에 대한 승낙 여부를 통지하지 않으면, 상속인 기타 이해관계인은 상당한 기간을 정하여 그 기간 내에 승낙 여부를 응답하도록 지정에 의한 유언집행자에게 최고할 수 있고, 최고기간 내에 확답이 없으면 그 취임을 승낙한 것으로 본다(민법 제1097조제3항).

(2) 법정선임집행자

유언자 또는 유언자의 위탁을 받은 제3자의 지정에 의한 유언집행자가 없는 때에는 상속인이 유언집행자가 된다(민법 제1095조, 선례 5-330). 지정유언집행자가 없는 때란 유언자가 유언집행자를 지정하지 않은 경우, 지정의 위탁을 받은 제3자가 지정에 관하여 아무런 의사표시를 하지 않은 경우, 지정된 유언집행자가 이에 불응한 경우 등을 말한다.

(3) 선임유언집행자

유언집행자가 없거나 사망, 결격 기타 사유로 인하여 없게 될 때

에는 가정법원은 이해관계인의 청구에 의하여 유언집행자를 선임한다(민법 제1096조제1항). 유언집행자가 없다는 것은 상속인마저 없는 경우에 법원이 선임할 수 있다는 의미이다. 가정법원에 의하여 선임된 유언집행자는 선임통지를 받은 후 지체 없이 승낙 또는 사퇴를 가정법원에 통지하여야 한다(민법 제1097조제2항). 이 경우에도 상속인 등이 선임의 승낙 여부에 대한 확답을 최고할 수 있으며, 그 기간 내에 최고에 대한 확답을 받지 못한 때에는 유언집행자가 그 취임을 승낙한 것으로 본다(민법 제1097조제3항).

라. 유언집행자의 결격 등

무능력자와 파산자는 유언집행자가 되지 못한다(민법 제1098조). 이러한 자를 유언집행자로 지정하더라도 무효이며, 가정법원도 이러한 자를 유언집행자로서 선임할 수 없다.

일단 취임한 지정유언집행자 또는 선임유언집행자도 정당한 사유가 있으면 가정법원의 허가를 얻어 그 임무를 사퇴할 수 있다(민법 제1105조).

가정법원은 지정유언집행자 또는 선임유언집행자가 그 임무를 게을리 하거나 적당하지 않은 사유가 있는 경우에, 상속인 기타 이해관계인의 청구에 의하여 유언집행자를 해임할 수 있다(민법 제1106조).

마. 유언집행자의 임무

유언집행자가 그 취임을 승낙한 경우에는 지체 없이 그 임무를 이행하여야 한다(민법 제1099조). 유언집행자는 취임 즉시 상속재산을 조사하고 재산목록을 작성하고 상속인에게 교부하여야 한다(민

법 제1100조).

유언집행자는 수인이어도 무방하다. 유언집행자가 수인인 경우 임무의 집행은 그 과반수의 찬성으로써 결정한다(민법 제1102조 본문). 다만 보존행위는 각자가 단독으로 할 수 있다(민법 제1102조 단서).

유언집행자는 상속인의 대리인으로 보아 법정대리인이라고 할 것이지만, 그 복임권에 관하여는 임의대리인과 같이 다루어진다. 따라서 유언집행자는 부득이한 사유가 있는 경우에 한하여 복대리인을 선임할 수 있고, 제121조의 책임을 진다(민법 제1103조제2항, 제682조).

유언자가 유언으로 달리 정하지 않은 경우에 상속재산의 상황 기타 사정을 참작하여 가정법원이 유언집행자의 보수를 정할 수 있다(민법 제1104조제1항). 유언집행자는 유언집행사무가 종료한 후가 아니면 보수를 청구할 수 없으나, 사무처리 도중에 그의 귀책사유 없이 사무가 종료된 경우에는 이미 처리한 사무비율로 보수를 청구할 수 있다(민법 제1104조제2항, 제686조).

유언집행에 관한 비용은 상속재산 중에서 이를 지급한다(민법 제1107조). 이러한 비용으로는 유언증서의 검인청구비용(민법 제1091조), 상속재산목록 작성비용(민법 제1100조), 상속재산의 관리비용(민법 제1101조), 유언집행자의 보수(민법 제1104조) 및 권리이전을 위한 등기·등록비용·유언의 집행과 관련하여 발생한 소송비용 등이 있다.

바. 유언집행자의 임무종료

유언집행자의 임무종료 원인으로는 유언집행의 종료, 유언집행자

의 사망, 결격사유의 발생, 사퇴, 해임 등이 있다. 유언집행사무가 종료된 경우에 유언집행자는 상속인에게 지체 없이 그 전말을 보고 하여야 하고(민법 제1103조제2항, 제683조 후단), 급박한 사정이 있으면 유언집행자 또는 그 상속인은 유언자의 상속인이나 그 법정 대리인이 상속사무를 처리할 수 있을 때까지 계속하여 그 사무를 처리하여야 한다. 이러한 경우에 유언 집행사무가 존속하는 것과 같은 효력이 있다(민법 제1103조제2항, 제691조).

제 5 절 | 유증으로 인한 소유권이전등기

1. 신청인

가. 문제점

등기는 법률에 다른 규정이 없는 한 등기관리자와 등기의무자가 공동으로 신청하는 것이 원칙이다. 등기로 인하여 권리의 변동이 생기는 등기신청을 등기관리자와 등기의무자가 공동으로 신청케 하는 것은 등기관에게 형식적 심사권밖에 없는 현행제도하에서 등기관리자의 일방만의 등기신청에 따른 등기의무자의 불측의 손해를 방지하고, 등기의 진정을 확보하여 사권을 공시함으로써 거래의 안전을 보호하고자 하는데 그 목적이 있다. 따라서 등기의 진정이 확보될 수 있는 경우, 즉 판결 및 상속에 의한 등기신청의 경우에는 등기관리자만의 단독신청이 허용된다(법 제23조). 여기서 유증으로 인한 소유권이전등기도 상속으로 인한 등기처럼 수증자가 단독으로 신청할 수 있는지가 문제가 된다.

나. 포괄적 유증의 경우

포괄적 유증에 대해서는 ① 포괄수증자는 상속인과 동일한 권리의무를 가지고 있으므로 포괄유증은 상속에 준하여 수증자가 단독으로 신청할 수 있다는 견해와, ② 상속으로 인한 등기와는 달리 포괄유증은 등기의 진정성을 담보하기 위하여 공동신청에 의하여야 한다는 견해가 있다.

상속인의 단독신청을 허용하는 것은 상속인과 피상속인과의 신분관계에 의하여 법정된 권리의무의 승계에 대해서는 가족관계등록부 등을 통해서 쉽게 증명할 수 있으므로 단독신청을 인정하여도 등기의 진정성을 담보하는데 아무런 지장이 없기 때문이다. 이와는 달리 포괄적 유증의 경우에는 유언에 대한 공적 자료는 통상 존재하지 않으므로 상속과 같이 볼 수는 없고, 부동산등기법 제23조의 명문상 또는 입법취지에 비추어 볼 때 유증에 의한 물권변동에는 적용될 수 없을 것이므로 유증에 의한 부동산의 소유권이전등기는 판결에 의한 경우를 제외하고는 수증자와 유언집행자 또는 상속인이 공동으로 신청해야 한다는 견해가 타당하다고 본다.

다. 특정적 유증의 경우

특정적 유증의 경우에는 상속의 개시에 의하여 특정 유증의 목적물은 상속재산으로서 일단 상속인에게 귀속하고, 수증자는 유증의 무자에게 유증을 이행할 것을 청구할 수 있는 채권적 청구권을 취득한다. 따라서 특정적 유증을 원인으로 한 소유권이전등기는 수증자를 등기권리자, 유언집행자 또는 상속인을 등기의무자로 하여 공동으로 신청하여야 한다.

라. 등기실무

(1) 공동신청

유증으로 인한 소유권이전등기는 포괄유증이나 특정유증을 불문하고 수증자를 등기권리자, 유언집행자 또는 상속인을 등기의무자로 하여 공동으로 상속등기를 거치지 않고 신청하도록 하고 있다. 수증자가 유언집행자로 지정되거나 상속인인 경우에도 같다. 따라서 공정증서에 의한 유언의 경우에도 등기의무자인 유언집행자가 유증을 등기원인으로 하는 소유권이전등기를 단독으로 신청할 수는 없다(선례 6-249).

또한, 무능력자나 파산자가 아닌 한 유언집행자의 자격에 특별한 제한은 없으므로 수증자도 유언집행자도 될 수 있으며, 유언집행자와 수증자가 동일인이라 할지라도 그 자격을 달리하기 때문에 등기 신청 시에는 양자를 구분하여 기재하여야 한다(선례 5-327).

유언집행자가 수인인 경우에는 그 과반수 이상의 유언집행자들이 수증자 명의의 소유권이전등기절차에 동의하면 그 등기신청을 할 수 있다(예규 제1024호). 이 경우는 유언집행자의 지정이 없어서 수인의 상속인들이 유언집행자가 된 경우에도 같다. 따라서 유언자가 유언집행자를 지정하지도 않고 그 지정을 제3자에게 위탁하지도 않아 민법 제1095조에 의해 상속인이 유언집행자가 되었을 경우, 공동유언집행자에 관한 민법 제1102조에 의하여 과반수 이상의 상속인들이 소유권이전등기절차에 협력한다면 이에 협력하지 아니한 나머지 상속인들에 대하여 별도로 소유권이전등기절차의 이행을 명하는 판결을 받지 않더라도 수증자 명의의 소유권이전등기를 신청할 수 있다(선례 5-329).

(2) 수증자가 수인인 포괄유증의 경우

포괄유증의 수증자가 수인인 경우에는 수증자 전원이 함께 소유권이전등기를 신청할 수도 있고, 수인의 수증자가 각각 자기의 지분에 대해서만 소유권이전등기를 신청할 수도 있다(선례 5-331). 따라서 수증자 중 1인이 소유권이전등기절차에 협력하지 않는 경우 그 수증자를 제외한 나머지 수증자들의 각 지분에 대해서만 유증을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 수 있다(선례 6-249).

또한, 포괄수증자 이외에 유언자의 다른 상속인이 있는 경우에는 유증으로 인한 소유권이전등기와 상속으로 인한 소유권이전등기를 각각 신청하여야 한다(예규 제1024호).

2. 유언집행자가 선정된 경우의 등기신청

앞에서 설명한 바와 같이 유언집행자에는 지정유언집행자, 법정 유언집행자 및 선임유언집행자가 있다. 유언집행자를 상속인의 대리인으로 보는 동시에 유언집행자의 관리처분권 또는 상속인과의 법률관계에 대해서는 위임관계의 규정을 준용하고 있다(민법 제1103조제2항). 유언집행자는 유증의 목적인 재산의 관리 기타 유언의 집행에 필요한 모든 행위를 할 권리의무가 있으므로, 유언집행자가 있는 경우 그의 유언집행에 필요한 한도에서 상속인의 상속재산에 대한 처분권은 제한된다(대법원 1999. 11. 26. 선고 97다57733 판결). 따라서 유언집행자가 지정·선임되어 있는 경우, 유증을 등기원인으로 하는 소유권이전등기는 수증자를 등기관리자, 유언집행자를 등기의무자로 하여 공동으로 신청하여야 한다.

동일한 유언자가 작성한 여러 개의 유언서 중 일부에 유언집행자의

지정이 없는 경우 등기의무자를 누구로 하여야 하는지가 문제 되나, 유언자가 유언집행자를 지정하지 않거나 그 지정을 위탁하지 않아 유언집행자가 없을 경우에는 상속인이 유언집행자가 된다(민법 제1095조). 따라서 유언자 갑이 각각 별개로 이루어진 공정증서에 의한 유언을 하였는데, A부동산에 대해서는 상속인에게 유증한다는 내용과 함께 유언집행자가 지정되어 있으나, B부동산에 대해서는 상속인이 아닌 제3자에게 유증한다는 내용으로만 되어 있고 유언집행자가 지정되어 있지 않은 경우, 설사 A, B부동산에 대한 유언이 동일 시각, 동일 장소에서 이루어졌다고 하더라도 A부동산에 대한 유언집행자가 B부동산에 대한 유언집행자로서 유언을 집행할 수는 없을 것이며, 이 경우에는 상속인이 유언집행자가 되어 수증자와 공동으로 B부동산에 대한 소유권이전등기를 신청하여야 할 것이다(선례 5-330).

그밖에 상속인도 없게 된 때에는 이해관계인의 청구에 의하여 가정법원이 유언집행자를 선임하게 되고(민법 제1096조제1항), 가정법원은 지정 또는 선임에 의한 유언집행자가 그 임무를 해태하거나 적당하지 않은 사유가 있는 경우, 상속인 기타 이해관계인의 청구에 의해 유언집행자를 해임할 수 있다(민법 제1106조). 따라서 지정유언집행자가 장기간 행방불명되어 그 직무를 수행할 수 없는 경우, 상속인 기타 이해관계인이 가정법원에 유언집행자의 해임심판을 청구하여 해임심판이 확정된 후 상속인들이 유언집행자가 되어 유증으로 인한 소유권이전등기를 신청하거나, 가정법원으로부터 새로운 유언집행자를 선임 받아 유증으로 인한 등기를 신청하여야 한다(선례 5-279).

특정부동산을 갑에게 유증한다는 취지의 유언에서 유언집행자가 지정되어 있지만, 유언자에게 상속인이 없어서 상속재산관리인이

선임되어 있는 경우, 유증으로 인한 소유권이전등기의 신청인은 누구인지가 문제가 된다. 상속재산관리인의 권한은 원칙적으로 보존 행위에 한정되는데 반해(민법 제1053조제2항, 제25조), 유언집행자는 유증의 목적인 재산의 관리 그밖에 유언의 집행에 필요한 일체의 행위를 할 수 있으므로(민법 제1101조), 권한의 경합이 있는 경우에는 원칙적으로 유언집행자의 권한이 우선한다고 할 것이다. 또한, 상속인은 유언집행자의 집행을 방해하는 행위를 할 수 없으며, 유언집행자의 처분권은 상속인을 배제하고 상속재산 전부에 미친다. 즉 유언의 집행에 대해서는 유언집행자에게 전속되므로, 유언집행자와 재산관리인이 병존하는 경우에도 유언집행에 대하여는 유언집행자가 상속인의 대리인으로서 이것을 행하는 것이 타당하다고 할 수 있다. 따라서 이러한 경우에는 수증자 명의의 소유권이전등기는 수증자와 유언집행자가 공동으로 신청하여야 할 것이다.

3. 등기신청방법

가. 수증자 명의의 등기

포괄유증의 수증자는 상속의 경우와 마찬가지로 유증의 효력이 발생함과 동시에 상속재산의 전부 또는 일정비율에 따른 수증분을 당연히 취득하므로 포괄유증으로 인한 소유권이전등기는 상속등기를 거치지 아니하고 유증자로부터 직접 수증자명의로 등기를 신청하여야 한다.

유증으로 인한 소유권이전등기를 신청하기 전에 상속등기가 이미 마쳐진 경우에 상속등기를 말소하여야 하는가가 문제가 된다. 이에 대하여는 등기기록상의 소유명의인과 등기의무자의 표시가 일치하

지 아니하므로 상속등기를 말소하고 유증에 따른 소유권이전등기를 신청하여야 한다는 견해도 있지만, 상속등기를 말소하지 않고 상속인으로부터 수증자 명의로 유증을 원인으로 소유권이전등기를 신청할 수 있다고 보는 것이 등기실무의 입장이다. 즉 유증자가 그의 공동상속인 중 1인인 갑에게 특정 부동산을 유증하고 사망하였으나, 그 유증을 원인으로 한 소유권이전등기를 신청하기 이전에 이미 갑을 포함한 공동상속인들 명의로 상속으로 인한 소유권이전등기가 마쳐진 경우라면, 갑을 제외한 공동상속인들의 상속지분에 대하여 그 공동상속인들로부터 갑 명의로 유증을 원인으로 하는 공유지분 이전등기를 신청하여야 한다. 만약 이전할 지분 중 일부에 대하여 제3자 명의의 가압류등기가 마쳐진 경우라면 그 소유권이전등기시 그 제3자의 승낙은 필요하지 않으나 가압류의 제한은 인수하게 된다(선례 4-395).

또한, 이러한 경우에 유언집행자가 유언으로 지정되어 있다면 상속인들의 협력 없이 유언집행자와 수증자가 공동으로 상속등기를 말소하지 않고 유증으로 인한 소유권이전등기를 신청할 수 있을 것이다(선례 6-248).

나. 유증의 목적부동산이 미등기인 경우

(1) 유증의 목적부동산이 미등기인 경우에 직접 수증자 명의로 보존등기를 신청할 것인지 아니면 상속인 명의로 소유권보존등기를 한 다음 유증으로 인한 소유권이전등기를 신청해야 할 것인지가 문제된다.

이에 대해서는 유증의 목적부동산이 미등기인 경우에 포괄적 수증자는 상속인과 동일한 권리의무가 있지만, 유증관계는 가족관계

등록부 등 공적장부로 확인할 수 없기 때문에 직접 포괄적 수증자 명의로 소유권보존등기를 할 수 없다는 견해가 있다. 이 견해에 따르면 유증의 목적부동산이 미등기인 경우에는 직접 수증자 명의로 소유권보존등기를 신청할 수는 없고, 유언집행자가 상속인 명의로 소유권보존등기를 한 다음 유증으로 인한 소유권이전등기를 신청하여야 한다. 이 견해가 최근 전면 개정된 부동산등기법이 시행되기 이전의 등기실무 입장이었다.

하지만 최근 개정된 부동산등기법 제65조제1호에 따르면 구법 제130조제1호 및 제131조제1호와 달리 상속인 이외에 포괄승계인을 포함하고 있으므로, 포괄승계인에 해당하는 포괄수증자는 직접 자기 명의로 소유권보존등기를 신청할 수 있을 것이다.

한편 특정유증의 경우에는 상속 개시에 의하여 유증의 목적물은 상속재산으로서 일단 상속인에게 귀속하게 되므로, 직접 수증자 명의로 소유권보존등기를 신청할 수는 없고 유언집행자가 상속인 명의로 소유권보존등기를 한 다음 유증으로 인한 소유권이전등기를 신청하여야 한다.

(2) 특정유증의 목적 부동산이 미등기인 경우 상속인이 없는 경우 이미 사망한 유증자 명의의 소유권보존등기를 할 수 있는가가 문제가 된다. 이에 대하여 일본의 등기실무는 사망한 유증자 명의로 보존등기를 한 다음 유증으로 인한 소유권이전등기를 하는 것을 인정하고 있다. 하지만 상속인부존재의 경우, 사망한 자는 등기능력이 없기 때문에 사망한 유증자 명의로 보존등기를 하는 것은 우리 등기실무상 문제가 있다.

이 문제에 대해서는 미등기부동산은 일단 국가 명의로 소유권보

존등기를 한 다음 수증자 명의로 유증으로 인한 소유권이전등기를 하자는 견해도 있으나, 제도적으로 좀 더 연구가 필요한 부분이라 할 것이다.

다. 유증의 목적물이 부동산의 특정 일부인 경우

유언집행자는 유증의 목적인 재산의 관리 기타 유언의 집행에 필요한 모든 행위를 할 권리의무가 있다(민법 제1101조). 따라서 유증자의 소유 부동산 중 특정 일부만을 유증한다는 취지의 유언이 있는 경우, 유언집행자는 유증할 부분을 특정하여 분할(또는 구분)등기를 한 다음 수증자 명의로 소유권이전등기를 신청하여야 한다. 다만 어떻게 분필을 하느냐에 따라 수증자 및 상속인에게 미치는 영향이 크지만, 유언집행자는 선택채권의 채무자로서 선택권을 가지고 있으므로, 선택의 방법 또는 선택권자에 대하여 유언으로 특별한 지정이 없으면 임의로 선택하여 특정된 부분에 대하여 분할등기를 신청할 수 있을 것이다. 그 밖에 특정유증의 수증자가 유증자의 사망 후에 유증의 목적부동산 중 특정 일부에 대하여 유증포기를 한 경우에도 유언집행자는 포기한 부분에 대하여 분할(또는 구분)등기를 한 다음 포기하지 아니한 부분에 대하여 유증으로 인한 소유권이전등기를 신청하여야 한다(예규 제1024호).

4. 등기신청절차

가. 신청정보

일반적으로 등기를 신청하는 경우에는 규칙 제43조에 규정된 일반적 사항으로 부동산표시에 관한 사항, 신청인의 성명 또는 명칭과

주소 및 주민등록번호, 신청인이 법인인 경우에는 그 대표자의 성명과 주소, 대리인에 의하여 등기를 신청하는 경우에는 그 성명과 주소, 등기원인과 그 연월일, 등기의 목적, 등기필정보, 등기소의 표시, 등기신청연월일 등을 신청정보의 내용으로 등기소에 제공하여야 한다.

신청정보 중 신청인에 대해서는 “등기의무자 망 ○○○, 위 유언 집행자 ○○○, 등기관리자 ○○○를 표시하고 각 그들의 주소를 기재하여야 한다.

등기원인은 “○년 ○월 ○일 유증”으로 기재하되, 그 연월일은 유증의 효력이 발생한 날, 즉 유증자가 사망한 날을 기재한다. 다만 유증에 조건 또는 기한이 붙은 경우에는 그 조건이 성취한 날 또는 그 기한이 도래한 날을 기재한다. 그러나 유언이 상속재산분할방법의 지정으로 해석되는 경우에는 등기원인은 “상속”으로 기재하여야 할 것이다.

유증으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우 등기의무자의 등기필정보에 대한 사항을 신청정보로서 제공하여야 하는지가 문제가 된다. 이에 대해서는 포괄유증과 특정유증으로 나누어, 포괄유증은 상속으로 인한 등기신청과 동일하게 등기의무자의 등기필정보를 신청정보로 제공할 필요가 없으며, 특정유증의 경우에는 수증자가 상속인에 대하여 유증의 이행을 청구할 수 있는 권리를 취득하는 데 불과하여 상속인이 등기의무자가 되므로 상속인의 권리에 관한 등기필정보를 신청정보로 제공하여야 한다는 견해가 있다. 하지만 등기실무에서는 유증자의 권리에 관한 등기필정보를 제공하도록 하고 있으며(예규 제1024호), 이러한 등기필정보를 제공할 수 없는 경우에는 등기의무자 등이 등기소에 출석하여 등기관으로부터 등기의무

자 등임을 확인받거나 신청서에 등기의무자로 기재된 유언집행자 또는 상속인을 확인한 확인정보(서면)를 첨부정보로서 제공하여야 한다(법 제51조, 규칙 제111조).

나. 첨부정보

유증으로 인한 소유권이전등기를 신청하는 경우에는 권리취득의 등기에서의 일반적인 서면을 첨부정보로서 등기소에 제공하여야 한다. 즉 대리인에 의하여 등기를 신청하는 경우에는 대리권한을 증명하는 정보(규칙 제46조제1항제5호), 등기명의인의 주소를 증명하는 정보 및 부동산등기용등록번호를 증명하는 정보(규칙 제46조제1항제6호), 대장 정보나 그 밖에 부동산의 표시를 증명하는 정보(규칙 제46조제1항제7호) 등을 첨부정보로서 제공하여야 한다.

또한, 취득세(등록면허세) 및 지방교육세를 납부하였음을 증명하는 영수필확인서를 첨부하고, 등기신청수수료를 납부하여야 한다. 여기에서는 이러한 일반적인 첨부정보 외에 유증으로 인한 소유권이전등기신청에 특수한 첨부정보에 관하여 설명하기로 한다.

(1) 유언집행자의 자격을 증명하는 정보

유언집행자의 법적 지위에 대하여는 상속인대리인설, 유언자대리인설 등 견해대립이 있지만, 민법은 상속인의 대리인으로 규정하고 있다(민법 제1103조). 따라서 유언집행자가 등기의무자인 상속인의 대리인으로서 유증의 등기를 신청하는 경우에는 그 대리권한을 증명하는 정보를 제공하여야 한다. 유언집행자의 자격(대리권한)을 증명하는 정보로는, 유언집행자가 유언으로 지정된 경우에는 유언증서, 유언에 의해 유언집행자의 지정을 제3자에게 위탁한 경우에는

유언증서와 제3자의 지정서(그 제3자의 인감증명 첨부), 유언자가 유언집행자를 지정 또는 지정을 위탁하지 않아 상속인이 유언집행자가 된 경우에는 상속인임을 증명하는 서면과 유언증서, 유언집행자가 이해관계인의 청구로 가정법원에 의해 선임된 경우에는 유언증서 및 심판서를 각각 제출하여야 한다.

또한, 유언집행자의 인감증명, 주소를 증명하는 서면을 제출하여야 하고, 유언자의 상속인이 유언집행자인 경우에는 상속인임을 증명하는 서면과 그의 인감증명, 주소를 증명하는 서면도 같이 제출하여야 한다(선례 5-334). 유언집행자가 수인인 경우에는 그 과반수 이상으로 등기신청을 할 수 있기 때문에 예를 들어 상속인 7명 중 4명에 의해 등기신청을 하는 경우에는 신청서에 첨부할 인감증명은 등기신청인 4명의 것으로도 충분하고, 이들 4명이 모두 등기권리자인 수증자인 경우에도 같다(선례 200907-1).

(2) 유언검인조서

(가) 유언검인조서가 필요한 경우

유언증서에 검인을 청구하도록 하는 것은 유언서의 위조·변조를 방지하고 유언자의 진의를 보호하기 위해서이다. 따라서 유언의 집행 전에 유언의 증서나 녹음을 보관한 자 또는 이를 발견한 자는 유언자의 사망 후 지체 없이 가정법원에 유언서를 제출하여 그 검인을 받아 등기신청 시에 제출하여야 한다.

유언증서가 자필증서, 녹음, 비밀증서에 의한 경우에는 유언의 집행을 위해 유언자의 사망 후 지체 없이 법원에 제출하여 검인을 받아(민법 제1091조제1항), 유언검인조서 등본을 첨부하여야 한다. 공정증서나 구수증서에 의한 유언에는 검인을 청구할 필요가 없다(민

법 제1091조제2항). 즉 공정증서에 의한 유언은 공정력이 있으므로 별도로 검인을 받을 필요가 없다. 구수증서에 의한 유언인 경우에는 그 성립을 위하여 급박한 사유가 종료한 날로부터 7일 내에 법원에 검인을 신청하고(민법 제1070조제2항), 등기신청 시에는 유언검인 조서 등본이 아닌 검인신청에 대한 심판서 등본을 첨부하여야 한다.

유증에 정지조건 등이 붙은 경우에는 그 조건성취를 증명하는 서면 등을 첨부하여야 한다(선례 5-334).

(나) 유언증서에 관한 등기관원의 심사권

유언증서에 대한 가정법원의 검인은 유언의 방식에 관한 사실을 조사함으로써 위조·변조를 방지하고 그 보존을 확실하게 하기 위한 일종의 검증절차에 불과하고 유언증서의 적격성이나 유언의 내용의 진정성 또는 유언의 효력을 판단하는 것은 아니다(대법원 1998. 6. 12. 선고 97다38510 판결). 따라서 유언증서에 가정법원의 검인이 되어 있어도 등기관은 유언자의 날인이 누락되는 등 그 유언증서가 적법한 요건을 갖추지 아니한 경우에는 그 등기신청을 수리하여서는 안 될 것이다(선례 5-289).

이처럼 유언검인조서는 형식적인 것임에도 등기관이 형식적 요건만 심사하고 검인조서에 유언서의 하자 및 효력을 다투는 상속인이 있다는 사실이 기재되어 있어도 이를 수리한다면 불합리한 문제가 발생할 수 있다.

따라서 검인기일에 출석한 상속인들이 “유언자의 자필이 아니고 날인도 유언자의 사용인이 아니라고 생각한다”는 등의 다툼 있는 사실이 기재되어 있는 유언검인조서를 첨부한 경우에는 유언 내용에 따른 등기신청에 이의가 없다는 위 상속인들의 동의서(인감증명서 첨부)를

첨부하여야 할 것이다(예규 제1024호). 이는 검인조서의 기재 사실로 보아 상속인과 수증자의 다툼 있는 사실이 기재된 경우까지 등기하는 것은 타당하지 못하므로, 검인제도의 취지를 고려하고 상속인과 수증자와의 형평성을 유지하는 방안으로 검인기일에 출석한 상속인이 유언서의 효력을 다투는 경우에는 위 상속인의 동의서를 첨부하도록 하여 차후 발생할 수 있는 분쟁을 방지하고 등기의 진정성을 확보하기 위한 것이다.

(3) 기타 첨부정보

(가) 유언자의 사망을 증명하는 정보

유증은 유언자의 사망으로 효력이 발생하므로 그 사망사실을 증명하는 서면을 제출하여야 한다. 사망사실을 증명하는 서면은 가족관계등록부 중 기본증명서가 이에 해당될 것이다.

(나) 등기원인에 대하여 제3자의 동의 등이 있음을 증명하는 서면

등기원인에 대하여 제3자의 동의, 허가 또는 승낙을 요하는 경우에는 그러한 허가, 동의 또는 승낙이 있다는 것을 증명하는 서면을 제출하여야 한다. 이와 관련하여 농지법은 상속 및 상속인에게 한 유증에 의하여 농지를 취득하는 경우에는 농지취득자격증명을 발급받지 아니하고 농지를 취득할 수 있다고 규정하고 있다(농지법 제8조제1항제1호, 제6조제2항제4호).

등기실무에서는 포괄유증의 경우에는 상속인 또는 상속인 아닌 자를 구분하지 않고 모두 농지취득자격증명을 붙이지 않아도 된다고 한다(예규 제1415호). 이에 따르면 포괄유증 및 상속인에 대한 특정유증은 상속의 경우와 같이 농지취득자격증명을 첨부할 필요가

없다고 할 것이다.

5. 관련문제

가. 유류분

(1) 유류분에 관한 등기관인 심사범위

유류분이란 피상속인의 유언에 의한 재산처분의 자유를 제한함으로써 상속인에게 법정상속분에 대한 일정비율의 상속재산을 확보해주는 제도를 말한다(민법 제1115조). 이와 관련하여 유증으로 인한 소유권이전등기 신청이 있는 경우, 등기관이 상속인의 유류분을 침해하는 내용이라든가 이를 수리하여야 하는지가 문제 된다.

우선 실체적인 측면에서 보면, 유류분반환청구권의 성질에 관하여 형성권이라는 입장과 청구권이라는 입장이 있으나, 다수설과 판례는 유류분반환청구권을 형성권으로 보고 있다(대법원 1995. 6. 30. 선고 93다11715 판결). 이 입장에 따르면 유류분권리자가 유류분반환청구권을 행사하면 그 유증은 효력을 잃고, 그 유증이 아직 이행되지 않은 경우에는 그 이행의무를 면하며, 이미 이행된 경우에는 반환청구를 할 수 있게 된다. 이 유류분반환청구권의 행사 여부는 유류분권리자의 의사에 달려 있으므로, 유류분을 침해하는 피상속인의 유증이 있더라도 무효로 되는 것은 아니고, 다만 유류분권리자로부터 유류분반환청구권의 대상이 될 뿐이다.

절차적인 측면에서 보면, 유증으로 인한 소유권이전등기신청이 유류분에 관한 규정에 위반되는지를 판단하기 위해서는 당해 부동산에 대한 등기신청만을 보고 판단할 수는 없고, 상속재산을 전체적으로 보고 판단하여야 하므로 이를 판단할 수 있는 서면을 추가로

제출하여야 할 것이다. 그러나 현행법상 이를 제출하도록 할 수 있는 법적 근거는 없으며, 유증으로 인한 소유권이전등기신청을 하는 경우 유류분을 침해하는지는 등기관이 형식적 심사권의 범위 밖의 사항이라고 볼 수밖에 없다. 따라서 유증으로 인한 소유권이전등기신청이 상속인의 유류분을 침해하는 내용이더라도 등기관은 이를 수리하여야 할 것이다(선례 2-329).

(2) 유류분반환청구권의 행사에 의한 등기

특정유증은 일반적으로 채권적 효력을 가진다고 보고 있으므로 피상속인의 사망으로 유증의 목적물은 상속인에게 귀속되고, 수증자는 유증의무자에게 이행을 청구할 수 있는 채권적 청구권을 가지고 있을 뿐이다. 이때 상속인이 유류분의 침해를 이유로 유류분반환청구권을 행사하면 유증은 유류분을 침해하는 한도에서 효력을 잃고, 그 결과 목적물의 소유권이 유류분권리자에게 귀속되므로 유증이 이미 이행된 경우에는 수증자와 유류분권리자는 물권법상의 공유관계가 성립되며, 유류분권리자는 등기관리자로서 수증자를 등기의무자로 하여 유류분반환을 원인으로 한 지분이전등기를 신청할 수 있다. 그러나 유증이 아직 이행되지 않은 경우에는 상속인은 소유권 등에 의한 항변으로 수증자에게 유증의 이행을 거절할 수 있고, 상속을 원인으로 하여 단독으로 등기신청을 할 수 있을 것이다.

포괄유증의 수증자는 피상속인의 사망과 동시에 상속인과 동일한 권리의무를 취득하므로 포괄수증자는 유증의 목적부동산에 대하여 등기 없이도 직접 소유권을 취득한다. 이때 유류분권리자가 유류분 침해를 이유로 유류분반환청구권을 행사하면 그 의사표시만으로 유류분의 한도에서 포괄수증자는 권리를 잃게 되고 포괄수증자와 유류분권리자는 물권법상의 공유관계가 성립되며 그 공유관계는 공유

물분할에 의하여 해소된다. 이 경우 등기절차는 피상속인으로부터 수증자 명의로 유증을 원인으로 한 소유권이전등기를 경료한 다음 유류분권리자인 상속인 명의로 유류분반환을 원인으로 한 지분이전 등기를 신청하여야 할 것이다.

나. 청산형 유증과 등기

청산형 유증이란 유언증서에 “유언집행자는 상속재산에 속하는 모든 부동산을 매각하여 그 대금 중에서 부채를 변제하고 남은 재산을 수인에게 일정한 비율에 따라 유증한다.”고 기재된 것을 말한다. 특정 부동산의 매각대금을 상속인 중의 1인 또는 수인에게 유증한다는 내용의 유언은 특정유증을 전제로 한 청산형 유증이라고 할 수 있다. 청산형 유증의 경우 유언집행자는 당해 부동산에 대하여 청산하여 배분할 권한이 있으므로 그것을 매각하고 매수인에게 소유권이전등기를 마쳐주어야 한다. 이때 피상속인의 소유명의로부터 직접 매수인 명의로 이전등기를 할 수 있는지가 문제 된다.

청산형 유증이 행하여진 경우 수증자는 금전채권을 취득하고 상속인은 그 금전채권을 변제할 의무를 부담하며 그 변제의 방법으로 상속재산 중의 부동산을 매각하여 그 대금으로 지불할 것을 정해 놓은 것이라고 보아야 한다. 따라서 유언집행자가 매수인과 매매계약을 체결하고 매수인 명의의 소유권이전등기가 마쳐질 때까지는 상속인 전원의 공유로 남아 있으므로, 유언집행자가 단독으로 피상속인 명의로부터 상속인 명의로 상속에 의한 소유권이전등기를 한 다음 유언집행자와 매수인의 공동신청으로 상속인 명의로부터 매수인 명의로 매매를 원인으로 한 소유권이전등기를 하여야 할 것이다.

다. 유증과 가등기

(1) 유언자가 사망한 후의 유증의 가등기

포괄수증자는 유언의 효력발생과 동시에 유증의 목적부동산에 대한 소유권을 등기 없이 취득하므로(민법 제187조), 청구권을 보전하기 위하여 유증을 원인으로 한 가등기가 문제가 되지 않는다. 그러나 특정유증은 채권적 효력만을 가지고 있으므로 가등기의 필요성이 있다. 즉 유언의 효력발생 후 유언집행자를 등기의무자, 수증자를 등기권리자로 하여 공동으로 또는 유언집행자의 승낙서를 첨부하여 수증자의 단독으로 가등기를 할 수 있다. 또한, 등기의무자가 소유권이전등기절차에 협력하지 않으면 수증자는 판결을 받아 단독으로 소유권이전등기를 신청할 수 있으며, 그때까지는 가등기가처분명령을 받아 수증자 단독으로 유증을 원인으로 한 가등기를 신청하여 자기의 권리를 보전할 수 있다. 그리고 조건 있는 유증의 경우, 조건의 성부가 유언자의 사망 후에 확정될 것인 때에는 유언자의 사망 시에 수증자는 조건부 권리를 취득하는 것이 되므로(민법 제1073조제2항), 이러한 조건부 권리를 보전하기 위해서도 가등기가 인정된다.

(2) 유언자가 생존 중인 경우 유증의 가등기

유언자가 생존 중인 경우에도 유증의 가등기를 인정할 수 있는지가 문제되나, 유언자가 생존 중인 경우에는 유증의 가등기를 할 수 없다(예규 제1024호). 그 근거로 유언서에 수증자로 기재된 명의인은 가등기를 청구할 채권적 청구권도 취득하고 있지 않기 때문이라는 견해와 유언은 상대방 없는 단독행위로서 유언자의 생존 중에 수증자는 어떠한 권리도 취득할 수 없다는 견해가 있다.